

LUIS MANUEL MARCANO SALAZAR

BIBLIOTECA DE FILOSOFÍA DEL DERECHO

Lex

DERECHOS HUMANOS TEORÍAS Y DOCTRINAS



Biblioteca de
FILOSOFÍA DEL DERECHO

Carlos Alarcón Cabrera
(Director)

Carlos Antonio Agurto Gonzáles
Sonia Lidia Quequejana Mamani
Benigno Choque Cuenca
(Coordinadores Generales)

LUIS MANUEL MARCANO SALAZAR
Magistrado de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
Diplomático de carrera (R)

DERECHOS HUMANOS

TEORÍAS Y DOCTRINAS

Edición al cuidado de
Carlos Antonio Agurto Gonzáles
Sonia Lidia Quequejana Mamani
Benigno Choque Cuenca



Título: Derechos humanos. Teorías y doctrinas

© Luis Manuel Marcano Salazar

Edición: 2018

Corrección de textos Francisco Bustas Jara Asistente académico del Prof.
Luis Manuel Marcano

© Copyright de la presente edición:

Ediciones Olejnik

Huérfanos 611, Santiago-Chile

E-mail: contacto@edicionesolejnik.com

Web site: <http://www.edicionesolejnik.com>

ISBN: 978-956-392-242-4

Diseño de carátula: Ena Zuñiga

Diagramación: Hayden Méndez, yiset_mendez@hotmail.com

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de la presente edición de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico ni mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin la autorización escrita de los titulares del "Copyright".

Impreso en Argentina

2018

Printed in Argentina

“ Para mi hermana Maria Angélica Gómez Pietri cuya sangre está unida a la historia de Venezuela. Gracias por protegernos en momentos de persecución de una Dictadura corrupta y despiadada.”

ÍNDICE

Introducción.....	13
-------------------	----

Capítulo I

Teorías y Derechos Humanos

1.1- Humanismo	18
1.2. Episteme desde la perspectiva del Derecho.....	20
1.2.1.- Ius Naturalismo	20
1.2.2.- Ius Positivismo.....	26
1.2.3.- Conjugación del Ius Naturalismo y Ius Positivismo en el marco de los Derechos Humanos	29
1.3.- Otros enfoques paradigmáticos	30

Capítulo II

Definición, evolución y trascendencia de los derechos humanos

2.1- Definición de Derechos Humanos	34
2.2.- Fundamentación	36
2.3.- Historicidad de los derechos humanos.....	40
2.3.1.- Edad Antigua	41
2.3.2.- Edad Media	43
2.3.2.1- Principales características del modelo Iglesia-Institución	46
2.3.3.- Edad Moderna.....	48
2.3.4.- Características de los diferentes modelos precursores de los derechos humanos	50
2.3.4.1.- Características del modelo Inglés	50
2.3.4.1.1- Principales declaraciones inglesas:	51
2.3.4.2.- Características del modelo americano	51
2.2.5.2.1.- Principales declaraciones americanas	52
2.3.5.3.- Características de las declaraciones francesas	53
2.2.5.3.1.- Principales declaraciones francesas	53
2.3.5.4.- Las declaraciones de derechos humanos en el siglo XIX	57
2.3.5.4.1- Declaraciones del siglo XIX:.....	58
2.3.5.5.- Declaraciones de derechos humanos en el siglo XX	58

2.3.5.5. 1- Características de las declaraciones del siglo XX	58
2.3.5.6. - Las declaraciones constitucionales.....	59
2.3.6.- Características de los Derechos Humanos	59
2.3.6.1.- Universalidad.....	60
2.3.6.2. - Indivisibilidad e Interdependencia	61
2.3.6.3. - Son absolutos.....	62
2.3.6.4.- Son irrenunciables	62
2.3.6.5.- Son progresivos	63
2.3.6.6.- Son trasnacionales	64
2.3.6.7.- Son irreversibles	64
2.3.7.- Clasificación	64
2.3.7.2.-Derechos de Segunda generación. Los derechos económicos, sociales y culturales.....	65
2.3.7.3.- Tercera de generación.	65

Capítulo III

Protección jurídica internacional de la persona humana

3.1- Afrentas a la naturaleza humana que propiciaron la protección internacional de los derechos humanos	70
3.-2.- Sistemas de protección de derechos humanos.....	72
3.-2.1- Sistema Universal.....	74
3.-2.1.1- Instrumentos Jurídicos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.....	75
3.-2.2.- Sistema europeo	78
3.-2.2.1 Instrumentos Jurídicos de Protección de Derechos Humanos del Sistema Europeo.....	80
3.-2.3.- Sistema Interamericano	83
3.-2.3.1- Instrumentos Jurídicos de Protección de Derechos Humanos del Sistema Interamericano	88
3.-2.4.- Sistema africano.....	88
3.-2.4.1- Instrumentos Jurídicos de Protección de Derechos Humanos del Sistema Africano	90
3.3.- Constitucionalización de los derechos humanos en Latinoamérica .	91
3.3.1.- Constitución de Argentina	92
3.3.2.- Constitución de Bolivia.....	92
3.3.3.- Constitución de Brasil	93
3.3.4.- Constitución Política de Colombia.....	93
3.3.5.- Constitución de Costa Rica.....	93

ÍNDICE

3.3.6.- Constitución de Chile.....	94
3.3.7.- Constitución de El Salvador.....	95
3.3.8.- Constitución Política de la República de Guatemala.....	95
3.3.9.- Constitución de Honduras	96
3.3.10.- Constitución del Paraguay	96
3.3.11.- Constitución del Perú.....	96
3.3.12.- Constitución República Dominicana	98
3.3.13.- Constitución de Venezuela.....	98
3.4.- Tratamiento constitucional de las relaciones internacionales en Latinoamérica	104
3.5.- Jerarquía de los tratados en las Constituciones Latinoamericana	107

Capítulo IV

La protección de los derechos transgeneracionales

4.1 - La vida como un derecho y un deber.....	110
4.1.1.- Declaración Universal de Derechos Humanos	112
4.1.2.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).....	112
4.1.3.- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre	112
4.1.4.- Convención Americana sobre Derechos Humanos	112
4.1.5.- Convención sobre los derechos del niño	112
4.2.- ¿Las generaciones futuras tienen o no tienen derechos?	113
4.3.- Derechos de solidaridad.....	115
4.4.- Conferencias Internacionales Relacionadas con la Problemática ambiental	118
4.4.1.- Conferencia sobre el Medio Humano o Conferencia de Estocolmo (Suecia)	119
4.4.2.- Cumbre de Nairobi (Kenia).....	120
4.4.3.- Cumbre de Río (Brasil).....	122
4.4.4.- Protocolo de Kyoto (Japón)	124
4.4.5.- Cumbre de Johannesburgo (Sudáfrica)	126
4.4.5.1.- Los grandes problemas que se deben resolver.....	126
4.4.5.2.- Compromiso con el desarrollo sostenible	126
4.4.5.3.- El multilateralismo es el futuro	128
4.4.5.4.- Cómo lograrlo	128
4.4.6.- Cumbre de Copenhague	129
4.5.- Recepción en el derecho interno Latinoamericano de la protección ambiental	130
4.5.1.- Constitución Argentina.....	130

4.5.2.- Constitución de Brasil	130
4.5.3.- Constitución de Chile.....	131
4.5.4.- Constitución de Colombia.....	131
4.5.5.- Constitución de Costa Rica.....	131
4.5.6.- Constitución de Guatemala.....	131
4.5.7.- Constitución de Honduras	131
4.5.8.- Constitución de México	132
4.5.9.- Constitución de Panamá.....	132
4.5.10.- Constitución de Paraguay	132
4.5.10.- Constitución de Perú.....	132
4.5.11.- Constitución de Venezuela.....	133
4.6.- La protección ambiental en el ámbito Europeo	134
4.7.- Carta Africana sobre Derechos Humanos	138
4.8.- Protocolo de San Salvador	138
4.9.- Interrelación económica, política, social, cultural e ideológica ante el cambio climático.....	139
Conclusiones	147
Referencias bibliográficas.....	149

INTRODUCCIÓN

La protección jurídica de la dignidad de la persona¹ humana en el contexto del derecho contemporáneo ha sido un proceso “*in crescendo*”, y donde necesariamente se han imbricado el derecho constitucional y el derecho internacional; pero esto no es un hecho aislado ni obligado; la dinámica de la globalización ha intervenido en este andamiaje, lo sucedido en un extremo del mundo repercute en el otro inmediatamente, gracias a la tecnología la información fluye velozmente; por ello los actos que transgreden y en consecuencia vulneran esa dignidad, pueden conocerse.

Desde la mención de proscribir la esclavitud en el Congreso de Viena de 1815 concretizándose en el Convenio de Ginebra sobre la esclavitud de 1926, pasando por la protección de las minorías, los refugiados; se continúa abriendo el abanico de protección de los derechos humanos hasta llegar a los

1 El vocablo persona proveniente del griego *prósopon* se incorporó al vocabulario teológico como traducción del término latino *persona*, sirviendo a los Padres para fundamentar el dogma trinitario (*hipóstasis*), durante la Edad Media, los doctores latinos insistirán en esos caracteres de la *hipóstasis* que son la perfección, la incommunicabilidad, la existencia propia. S. Tomás llegará a la deseada síntesis del tema, al tiempo que da un definitivo paso adelante al considerar la P. en el orden del ser.

Entre los demás seres, la P. es el más perfecto, tanto en lo tocante al propio estatuto ontológico, la subsistencia, como por lo que se refiere a su naturaleza intelectual. Es el ser más digno entre todos los seres. Esta nota de dignidad está incluida en el término latino *persona*. «En efecto, debido a que en las comedias y tragedias se representaban algunos personajes famosos, se empleó el nombre de *persona* para designar a los que tenían alguna dignidad» (Sum. Th. 1 q29 a3 ad2). S. Tomás recoge sin reservas esta connotación de dignidad dándole casi rango de definición: «*Persona est id quod est perfectissimum in tata natura*» (ib. q29 a3; cfr. q29 a3 ad1); desde entonces pasando por Descartes, Hume hasta llegar a Kant el término *persona* no se había asociado a la moral y esta perspectiva kantiana es la escogida en la presente investigación.

Kant, reproponer el concepto de P. La realidad e inmortalidad del alma y la dignidad consiguiente del hombre que tan problemáticos se le aparecían como objeto de una consideración metafísica, como realidad moral se le impone con una especial fuerza. La P. humana es dignidad. «La humanidad misma es una dignidad, porque el hombre no puede ser tratado por ningún hombre (ni por otro, ni siquiera por sí mismo) como un simple medio, sino siempre, a la vez, como un fin, y en ello estriba precisamente su dignidad (la personalidad)» (Kant, *Metaphysik der Sitten. Tugendlehre*, 38, 111,321). La P. en Kant se define como un «alguien» en relación con otros «alguien» y con Dios. Es el hecho moral, el círculo de la moralidad, lo que nos pone delante la realidad de la P. como fin en sí, como un para sí (*für sich*). Prácticamente, el hombre puede ser despreciado o maltratado, pero nada de eso suprime su dignidad de ser capaz de una actuación moral, de ser que no debe padecer instrumentalización alguna. Consultado en: <http://www.canalsocial.net/GER>. abril 2009.

derechos transgeneracionales; el compromiso no sólo es para los de hoy sino más aún para aquellos que aún su vida es una esperanza, para el futuro; ¿Por qué?. La inmanencia de la dignidad de la persona como sello característico del hombre le confieren unas cualidades distintas a cualquier omnívoro, no se trata de tutelar unos derechos que cubran determinado espectro de la vida, *«es la vida misma de la especie humana»*.

Esos derechos tendientes a proteger el ambiente, considerado hoy día dentro de lo que se denomina derechos de solidaridad unidos al derecho a la vida etc.; conforman en su conjunto el objeto de la presente investigación desde una perspectiva holística como una apreciación integral de situaciones y hechos, haciendo énfasis en la protección de los derechos transgeneracionales con fundamento en la protección al ambiente ante la realidad apremiante e inaplazable que amenaza a la humanidad como lo es el cambio climático, de ahí que el derecho a la vida e intrínsecamente el derecho a un ambiente adecuado son los derechos que sirven de marco referencial y su constitucionalización, por cuanto estos derechos son capaces de albergar el derecho de la humanidad de sobrevivir en el único planeta donde hasta ahora puede vivir el Hombre; el derecho a la vida va más allá de su privación arbitraria.

Por ello la elección epistémica adecuada ha debido ser interdisciplinaria, relacionando desde el pasado, comprendiendo el presente y evaluando las diferentes clasificaciones de derechos protegidos, a fin de visualizar la interdependencia existente entre los derechos hacia el más importante de todos; la vida, la sobrevivencia en el planeta tierra del hombre, de la persona humana. Por ello, al considerar el episteme se debe analizar no sólo al derecho internacional desde la perspectiva de organizar a la sociedad internacional y la protección de la persona humana, sino además el deber de garantizar unos derechos que trascienden al hombre de hoy, los cuales han sido consagrados en las cartas políticas de los Estados modernos que han acogido la normativa surgida de los tratados, pactos y convenios internacionales, de allí la estrecha relación que se ha generado en esta área entre el Derecho Internacional Público y el Derecho Constitucional, por lo que es factible hablar de un Derecho Constitucional Internacional de los Derechos Humanos.

En la violación de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, las víctimas pueden ser tanto individuos como grupos, sin embargo algunos grupos sufren de forma desproporcionada, como por ejemplo personas de bajos ingresos económicos, mujeres, pueblos indígenas, poblaciones en situaciones de ocupación, personas que buscan asilo, refugiados y desplazados internos, minorías, personas mayores, niños, campesinos sin tierra, personas con discapacidad; sin embargo ante la amenaza producto del cambio climático, no sólo ellos son los vulnerables; son todos los seres vivos y en especial las generaciones futuras ante quien en muchas constituciones se ha asumido un compromiso; por lo que en orden a la investigación es insoslayable analizar diversos actores y sistemas; los problemas internos relativos a los derechos humanos transgeneracionales han dejado de ser tales para convertirse en cuestiones de mérito internacional. Originándose, consecuencias inconmensurables ante el uso indiscriminado de los recursos naturales y la expulsión de gases como el dióxido de carbono, secuelas que interesan a todos los países sin exclusión; diversos factores como

los políticos, económicos, culturales intervienen en el tema en cuestión; sin embargo en la asunción de responsabilidades los valores éticos y morales, deberán compaginarse ante un mundo global que no admite la disgregación de esfuerzos ni la segmentación de Estados ante una amenaza común; los cambios de temperaturas y los subsiguientes efectos más temprano que tarde pueden alcanzar a cualquiera.

El problema de la desertificación, contaminación, el deshielo glaciar y el agotamiento de los recursos necesarios para la subsistencia trasciende ámbitos temporales y geográficos; y la respuesta es la *solidaridad* para no sólo asumir el problema sino más aún frenarlo y solucionarlo; requiriéndose instancias nacionales e internacionales eficientes y eficaces que regulen la relación hombre-naturaleza con ese objeto específico; además capaz de imponer las sanciones pertinentes en la ordenación de la conducta del hombre para asegurar la subsistencia y bienestar de la especie humana en su entorno natural y cultural; este sistema debe ser solidario y transgeneracional, porque atañe a las generaciones presentes y futuras, además eminentemente garantista, en resguardo de una protección a la persona y al ambiente bajo los parámetros de un desarrollo integral y sustentable.

Esa construcción del derecho transgeneracional se pudo generar por el movimiento internacional, cuyo punto de partida formal es la Conferencia de Estocolmo en 1972, la Cumbre de Nairobi en 1982, continuó con la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, la Cumbre de Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002 y el Protocolo de Kyoto de 1997; además del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En cumplimiento a esos compromisos internacionales se ha desarrollado también una conciencia tendiente a proteger el ambiente por lo que en este sentido Estados Latinoamericanos, especialmente han incorporado a su derecho interno conceptos propios de la materia ambiental y por ende los derechos transgeneracionales han podido configurarse por la fuerza del derecho constitucional internacional de los derechos humanos.

Esos eventos internacionales generaron cambios constitucionales; así, en Venezuela a partir de la Constitución de 1999 en su Capítulo IX se contemplan los derechos ambientales en los artículos 127 al 129, como un derecho de la persona susceptible de protección y a su vez un deber compartido con el Estado que imperiosamente debe protegerlo e imponer la conservación del equilibrio ecológico para las generaciones futuras, en el artículo 127 se consagra específicamente:

“Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica” (...)

Sobre las anteriores variables la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y algunos Tribunales Nacionales, haciendo uso del principio de progresividad intrínseco en los

derechos humanos, han venido desarrollando una base jurisprudencial que si bien en principio se avocaba a proteger los derechos civiles y políticos, los derechos sociales emergieron con fuerza además de los derechos de los pueblos indígenas, su alcance sin duda va mucho más allá; proteger una porción de la tierra y a sus habitantes con arraigo y fundamento en un derecho ancestral, conlleva también a la protección del derecho a la vida transgeneracional, puesta en peligro por la devastación ambiental.

Sería nulo, todo el esfuerzo y empeño realizado en conformar todo un cuerpo jurídico nacional e internacional cuyo propósito ha sido proteger los derechos humanos, si se mira de reojo el inminente daño ocasionado sobre todo en los últimos años sobre el único planeta que se conoce habitable para el hombre.

De nada valdrá un alto grado de desarrollo económico y social, si es a costa de un gran deterioro ambiental; calidad de vida implica el uso equilibrado de los bienes proveídos por la naturaleza; el deber de la generación actual de proteger el ambiente para las generaciones futuras no es una paradoja; el derecho que se tiene a un ambiente adecuado, a disfrutar de un derecho ancestral sobre un determinado territorio será vacuo, sin la garantía por parte de un organismo dotado con suficiente poder para que efectiva y eficazmente ese derecho transgeneracional se mantenga incólume.

Desde los pueblos y comunidades indígenas se envía un mensaje a la comunidad internacional; no es solidaridad con ellos es defensa y adhesión en beneficio de todos.

La justicia es un valor al cual aspira el hombre por su propia naturaleza de allí que: "Una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana. Ésta representa el fin último de la sociedad, que está a ella ordenada: «El orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal, y no al contrario»² Mientras esté a tiempo corresponde al mismo Hombre protegerse; preservando, resguardando el planeta tierra de todos los agentes reconocidos como perjudiciales; los esfuerzos por ordenar las relaciones entre el Hombre y la naturaleza no será un sacrificio con resultados fallidos; el clamor no debe ser de unos pocos, las tragedias naturales no avisan ni pautan audiencias en las agendas de los Estados. El nuevo orden mundial una vez producida la escisión de la bipolaridad, también implica una nueva ética con la propia naturaleza humana y su entorno; nuevas formas de hacer justicia.

No se trata del confort y bienestar de los países ricos en detrimento de países pobres, ni de un resguardo a ultranza de la soberanía, sino mantener lo indispensable para poder lograr vivir; en un planeta apto para ello. La protección constitucional de los derechos transgeneracionales es una realidad; sin embargo ¿Es suficiente que los derechos transgeneracionales se plasmen para que sean realmente factibles?; ¿Es menester que ocurran grandes tragedias naturales para que se puedan tomar decisiones coherentes y efectivas que garanticen el derecho a la vida.?

2 Concilio Vaticano II, Const. past. *Gaudium et spes*, 26: AAS 58 (1966) 1046- 1047.

CAPITULO I

TEORÍAS Y DERECHOS HUMANOS

Según Pérez Luño citado por Peña Chacón¹

“Los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”

Partiendo de lo anterior, la Edad Contemporánea presenta sus matices particulares; entre los cuales cabe mencionar la preeminencia del Estado como el actor principal en la sociedad internacional, deslastrada de los feudos, igualmente la existencia de un *corpus juris* formado a partir del siglo XIX en el cual se coloca al individuo como centro y fundamento de su existencia, la dignidad que posee el hombre lo hace merecedor de potencias o atributos únicos. La protección de los derechos transgeneracionales al ser reconocidos subsecuentemente por el Derecho Internacional y por los distintos ordenamientos jurídicos internos, han demostrado que el ser humano tanto en su faceta de individuo como de sujeto integrante de la colectividad, requiere condiciones mínimas y necesarias para que pueda desarrollarse plenamente en el ámbito económico, social, cultural, político y jurídico; actuando en su conjunto con armonía. A diferencia de los derechos humanos de primera y segunda generación, al día de hoy, los derechos humanos de tercera generación no han sido tratados con la misma complejidad, ni en los tratados internacionales ni en las respectivas legislaciones nacionales. Se trata de derechos colectivos, pues los beneficios que derivan de ellos cubren a la colectividad y no sólo al individuo en particular. La doctrina les ha llamado derechos de solidaridad por estar concebidos para los pueblos, grupos sociales e individuos en colectivo. Otros han preferido llamarles “derechos de la humanidad” por tener por objeto bienes jurídicos que pertenecen al género humano, a la humanidad como tal, entendiendo por esta, no sólo a las generaciones presentes sino también a las generaciones futuras. Al tratarse de derechos colectivos no pueden ser monopolizados o apropiados por sujetos individuales, pues, pertenecen al género humano como un todo.

En tal sentido se trata de derechos modernos, cuyos titulares no son estrictamente personas individuales, sino más bien los pueblos, incluso

¹ Consultado en http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Derechos_Humanos_Derechos_Humanos_y_Medio_Ambiente_Julio_del_2010

la humanidad como un todo. Por lo cual, la comprensión de los cambios paradigmáticos dados en este proceso de reconocimiento del hombre como un ser dotado de derechos inherentes e immanentes a su persona, aún antes que el propio Estado; requiere un enfoque epistémico múltiple partiendo del humanismo como el modelo básico, aplicando además la holística por cuanto se estima que el objeto de estudio requiere una apreciación amplia e integral.

1.1- HUMANISMO

Siguiendo a Zagrebelsky (2007): Los derechos del humanismo laico son hijos de la tradición antiescolástica que se inició con la fractura operada por el espíritu del renacimiento. El significado de esta fractura viene expresado de la manera más clara y sintética en el célebre pasaje de la *Oratio de hominis dignitate* de Giovanni Pico della Mirandola, donde se pone de manifiesto la naturaleza definida del hombre en el orden de la creación y la tarea que se le ha encomendado en determinar con sus propias fuerzas aquello que pretende ser; citándolo así:

Al final de la creación nació en el Demiurgo el deseo de formar un ser que fuese capaz de conocer las razones de su obra y de amarla por su belleza. Pero entre los arquetipos no había ninguno que sirviese de modelo para crear la nueva prole, ni quedaba ya en el tesoro nada que legar al nuevo hijo, ni había tampoco ningún lugar disponible en todo el orbe que pudiese asignarse a ese contemplador del universo. Todo estaba ya ocupado, pues se les habían asignado sus puestos tanto a los seres del orden superior, como a los del medio, como a los del inferior... Formó, entonces, al hombre conforme a una imagen común y colocándolo justo en medio del mundo, le habló de este modo: A ti, Adán, no te asignamos ni un lugar determinado, ni una apariencia peculiar, ni un patrimonio exclusivo, a fin de que puedas tener y conservar el lugar, la apariencia, el patrimonio que elijas para ti, según tu deseo y tu voluntad. *La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las leyes que hemos establecido.*

Tú en cambio, no constreñido por ningún límite, te lo pondrás en virtud de la libre voluntad que yo te confiero... Los animales nacen trayendo consigo... del seno de la madre todo lo que tienen que tener; los espíritus superiores, desde el origen o poco después, son lo que seguirán siendo durante toda la eternidad. Al hombre, en cambio, el padre, cuando nace, le proporciona todas las semillas y gérmenes de cada género de vida. Los que cultive se desarrollarán y fructificarán en él. Si son vegetales, vegetará; si son sensuales, se embrutecerá; si son racionales, aflorará su esencia celeste; si fueren intelectuales, será ángel e hijo de Dios. (p.80)

En la Edad Media, el hombre era considerado fundamentalmente desde una perspectiva teológica, los humanistas valorarán al hombre desde una perspectiva mundana, no-divina, es decir, el hombre será visto como un ser natural e histórico dotado de razón e inmerso en un espíritu libertario; la

religión, aparte de su función redentora, pasa a ser considerada ante todo en su función civil. El humanismo vino a sustituir la visión del mundo vista bajo el prisma dogmático religioso; se enfoca una nueva perspectiva donde se refleja la racionalidad, en la que prima la idea del hombre como ser humano, verdadero e integral. Así, tanto la religión como la tolerancia religiosa son instrumentos válidos para asegurar el ideal de la paz civil.

De acuerdo al pensamiento humanista, el hombre como ser natural tiene una vida corpórea que requiere bienestar en contraste con el ascetismo medieval, aunque el humanismo aparejado al Renacimiento vuelca sus ideas a lo profundo de la Antigüedad, a su vez utiliza el quiebre paradigmático para concebir las relaciones entre los hombres de diferente manera; el súbdito se redime ante la idea de humanidad; tal como lo señala Martínez (1994) (...):

“Como la religión deja de ser el principio que otorga sentido universal a las dimensiones normativas y morales de la sociedad, será el derecho el que provea de ese sentido universal.” (56).

En este contexto formula su clásica doctrina del derecho internacional por ejemplo; Francisco de Vitoria, quien aborda principalmente dicho estudio, en la tercera parte de la primera *Relección de los Indios*, donde vierte su fundamentación del Derecho Internacional. Vitoria, señala su idea como un vínculo jurídico que, estableciendo relaciones entre los Estados, se permitiera hacerles titulares de derechos y sujetos de obligaciones, sin mengua de su soberana autonomía.

Esa proyección del rigor de la norma jurídica al consorcio de las naciones, es lo que constituye su originalidad.

En la historia de la Humanidad, jamás se habían dado circunstancias políticas y sociales que impusieran de manera tan imperiosa como ineludible, la necesidad de arbitrar medios que regularan la vida de relación de los pueblos. El surgimiento simultáneo y pujante de los Estados nacionales que integran la Europa occidental, al finalizar el medioevo, determinó una situación novedosa, que exigía correlativamente soluciones no emitidas hasta entonces. El monismo político del Imperio Romano, cuya repercusión vibraba aún en los soberanos de la Edad Media, dejaba paso a un pluralismo estatal en el que cada uno de los elementos integrantes no cesaba de afirmar su absoluta omnipotencia, a la que no eran ajenas las añoranzas del imperio universal.

La concepción vitoriana se ajustaba al nuevo orden de cosas. Aunque expuesta para resolver un problema extra europeo — la ocupación de América — sus soluciones fueron dadas sin olvidar las nuevas condiciones histórico políticas reinantes en Europa,² que despertaba (...) “tras un larguísimo período de eclipse del hombre individual en la uniformidad político-religiosa que supuso el medioevo. El Renacimiento supuso la iniciación decidida de esta concientización del hombre en el mundo.

La Reforma a su vez significó el atrevimiento humano por interpretar

2 Orestes Araujo: Las doctrinas internacionalistas de Fray Francisco de Vitoria. Montevideo 1948. p. 60-61

individualizadamente la palabra de Dios”.³ Cada momento histórico tiene sus hombres que trascienden a la posteridad; unos para defender lo que no que no se quiere perder, otros por luchar por sus ideas incluso a cuenta de su vida; con el advenimiento del Humanismo (...) “el derecho natural derivado de la propia naturaleza sustituye al derecho natural fundamentado en la razón o voluntas divinas y pasa a ser construido, desde aquella premisa, racionalmente con pretensiones maximalistas”⁴.

Partiendo del humanismo las corrientes paradigmáticas en las cuales se bifurcó el derecho son el ius naturalismo y el ius positivismo, el pensamiento jurídico posterior se enmarcará en una u otra rama teniendo sus matices distintivos cada una, sin embargo ambas fuentes se apalancarán para así lograr el auge que ha tenido el reconocimiento y protección de los derechos humanos.

1.2. EPISTEME DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO

1.2.1.- IUS NATURALISMO

El humanismo penetró todas las esferas de acción del hombre renacentista, originando una nueva manera de vivir; en el derecho nació la corriente ius naturalista, teniendo en su cúspide a Hugo Grotius a quien se le considera fundador del moderno derecho natural; quien define al derecho natural como (...) “dictamen de la recta razón indicativo de que un acto, en virtud de su conveniencia o disconveniencia con la naturaleza racional y social, está afectado moralmente de necesidad o de ignominia, y que como consecuencia, tal acto está prescrito o proscrito por Dios, autor de esa naturaleza”.⁵ Al considerar los seguidores de esta escuela al hombre como un ser racional que le permite socializar; el ser humano en su convivencia buscará a su vez los lazos que le unen a fin de lograr que esta sea en concordia; se avienen de esta manera los pactos sociales que le permitirán crear estructuras y sistemas, tales como el Estado que nace por una necesidad de conveniencia y el entramado que este genera con sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial⁶. Esta doctrina, nacida en Europa también en América tuvo un digno representante, el humanista Don Andrés Bello, quien en su obra *Principios de Derecho Internacional*, exponía:

(...) Como las naciones no dependen unas de otras, las leyes o reglas a que debe sujetarse su conducta recíproca sólo pueden serles dictadas por la razón, que a la luz de la experiencia, y consultando el bien común, las deduce del encadenamiento de causas y efectos que percibimos en el universo. El Ser Supremo, que ha establecido

3 Antonio Blanco González. Filosofía del Derecho. Las concepciones jurídicas a través de la historia. Madrid. Universidad Nacional de Educación a Distancia.1999. p.116

4 Ib. Ib.

5 Ib. 117

6 Trilogía que se va imponiendo atribuido a Charles de Secondat (Barón de Montesquieu) en su obra “El espíritu de las leyes”.

estas causas y efectos, que ha dado al hombre un irresistible conato al bien o la felicidad, y no nos permite sacrificar la ajena a la nuestra, es, por consiguiente, el verdadero autor de estas leyes, y la razón no hace más que interpretarlas. El derecho internacional o de gentes no es, pues otra cosa que el natural, que aplicado a las naciones, considera al género humano, esparcido sobre la faz de la tierra, como una gran sociedad de que cada cual de ellas es miembro, y en que las unas respecto de las otras tienen los mismos deberes que los individuos de la especie humana entre sí. (p.131).

Esta necesidad de interrelación, y de respeto mutuo en la consecución del bien común unívocamente desembocó en la necesidad a su vez de establecer normas, reglas y principios; que coadyuvarán a implementar un orden que pudiera fundamentar y sustentar esta nueva asunción; ante la aparición de los Estados y el deslumbre del yugo divino impuesto por unos pocos que ostentaban el poder. En este sentido, apunta Ross (1997) “Una vez que el conflicto entre el emperador y el Papa se atenuó, el derecho natural se fue haciendo cada vez más conservador” (p.300). Este declive paulatino y los hechos históricos políticos, sociales, económicos y culturales devenidos dieron paso irremediablemente a buscar fuentes que contribuyeran a darle forma a los tiempos que se advenían; las Guerras de las Investiduras, la Reforma, la invención de la imprenta, el avance del Islamismo son hitos que no pueden pasar inadvertidos ante las mentes lúcidas y privilegiadas que vieron en la filosofía política y jurídica el marco propicio para plasmar sus pensamientos e ir depurando el Derecho.

El humanismo reafirmador del hombre como se dijo, produjo un nuevo orden en el pensamiento como el racionalismo, que según el autor supra citado (...) “el racionalismo, más que una doctrina es un sistema de entender y vivir las realidades todas que nos rodean, entre ellas la más importante, existencialmente hablando, el hombre mismo, cuya naturaleza soporta la misma racionalidad”⁷ destacando entre sus precursores el adalid del derecho natural, Hugo Grocio quien forjó la idea del sometimiento del hombre a un orden civil o político por medio de un pacto (...) “por cuya virtud van naciendo distintos Estados, distintas formas de gobierno, y no de modo natural sino por derecho positivo”⁸. Es connatural en el hombre su naturaleza de vivir en comunidad con sus semejantes, conllevando esta convivencia intrínsecamente a una cesión de intereses para lograr unos fines comunes; estos fines originarán el ideal que representa el Estado y subsecuentemente las diversas formas de gobernar a los individuos que van a formar parte de ese Estado.

Thomas Hobbes cuarenta años antes que John Locke, escribía su obra *Leviatán o la Materia, Forma y Poder de una República, Eclesiástica y Civil*, señalando enfáticamente:

Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre, en modo alguno.

7 Ib. Ib

8 Ib. 117

Por consiguiente, a pesar de las leyes de naturaleza (que cada uno observa cuando tiene la voluntad de observarlas, cuando puede hacerlo de modo seguro) si no se ha instituido o no es suficientemente grande para nuestra seguridad, cada uno se fiará tan sólo, y podrá hacerlo legalmente, sobre su propia fuerza y maña, para protegerse contra los demás hombres.⁹

Hobbes sin ambages admite la supremacía del Estado como el único capaz de imponer autoridad, una vez conformado el pacto y superado el estado de naturaleza, donde la fuerza, la argucia individual es la reinante para sobrevivir, porque ante iguales derechos se impondrá la fuerza; por la racionalidad del hombre es posible superar el estado de naturaleza; fundamentándose el advenimiento del Estado y de las instituciones como un cauce donde convergen los diversos intereses para ser arbitrado por una autoridad y poder consensuado por los pactantes; allí estriba la racionalidad de Hobbes.

En la corriente del racionalismo también está inscrito Baruch Spinoza, quien a diferencia de Hobbes no propugnaba que el pacto social por el cual emerge el Estado se basa en la fuerza y por ende en el poder de la autoridad que se ejerza desde sus albores; "Spinoza lo fundamenta no sobre el miedo sino sobre la razón de los hombres que ven en él. el instrumento de sus libertades".¹⁰ La libertad para este autor es la fuerza motriz que impulsa al individuo a ceder parte de su libertad pero no para que lo sojuzguen ni sometan, sino para poder expresarse libremente y elegir su modo de vida; el hombre no sólo es razón sino además posee pasiones, que en muchas ocasiones dominan a la razón, siendo junto a ésta connatural en el hombre el amor, el odio, la ira... son innegables en los seres; por ello al convenir en normas comunes se conducen mejor las pasiones, la fuerza del Estado garantizará que no haya guerra de todos contra todos, el mejor garante de la paz y la libertad es el Estado.

Samuel Pufendorf y Locke también se insertan en el racionalismo con la idea del pacto societario para superar el Estado de naturaleza; Pufendorf, sin embargo, creía en las pequeñas sociedades formadas en la familia, y su gran mérito también se debió a escindir la moral y el derecho; diferenciando la moral a lo interno y el derecho a lo externo, a los actos humanos en su relación social. Locke en sus ensayos sobre el gobierno civil¹¹, a pesar de manifestar su volición pactista concebía al Estado como la mejor forma de convivencia social, sin embargo es anuente al derecho de rebelión. "El fin del gobierno es el bien del género humano, ¿qué es mejor para la humanidad: el pueblo siempre expuesto a la voluntad ilimitada de la tiranía o que los gobernantes estén sujetos a que se les resista cuando se exceden en el uso del poder y lo emplean para destruir y no para cuidar los bienes del pueblo"¹²; pudiéndose ejercitar este derecho cuando el Estado no cumple con los fines

9 Fondo de Cultura Económica. México. 2006.p.137

10 Op. Cit. p. 123

11 John Locke: Segundo Tratado del Gobierno Civil. Buenos Aires. Ediciones Grijalbo, S.A. 1975.

12 Op. Cit. 101

para los cuales fue creado, a los que le debe la existencia, no admitiendo, el poder absoluto.

“El poder absoluto arbitrario o el gobernar sin leyes fijas y establecidas, no pueden ser compatibles con los fines de la sociedad y del gobierno (...) es impensable aún si tuviesen poder para hacerlo, poner en manos de una persona, o de varias, un poder absoluto arbitrario sobre sus personas y bienes. Sería tanto como ponerse en una situación peor que la del estado de naturaleza, en la cual tenían libertad de defender su derecho contra los atropellos de los demás”. (p.98).

De donde se deduce que para él en el estado de naturaleza el hombre tiene unos derechos que le es lícito defender por la propia ley natural, no hay autoridad suprema, situación que cambia al pactar por cuanto el pueblo detentador del soberano le otorga al Estado la potestad de regir; exponiendo teóricamente en tres poderes el modo de cumplir su misión el Estado; otorgándole preponderancia al poder legislativo.¹³

Jean Jacques Rousseau junto con Locke se les considera los fundadores de la democracia moderna, buscó una explicación meta jurídica a la soberanía, al ejercicio del poder y más aún al derecho; en su obra *Discurso sobre el origen de la desigualdad* y, más aún, en *El contrato social*. Rousseau, expone sus ideas sobre la distribución del poder; entre ¿Quién? o ¿Quiénes? De acuerdo a la teoría del gobierno absoluto de Hobbes, el poder no puede ser regentado por una sola persona o individuo independiente de los demás que componen una colectividad (gobierno absoluto); ni tampoco de acuerdo a los presupuestos aportados por Locke en dividir el ejercicio del poder en forma bipartita o Montesquieu en forma tripartita. ¡No! Rousseau plantea la detentación del poder en cada uno de los individuos que componen el colectivo social y han pactado un contrato para constituir la *República*.

Una vez superado el estado de naturaleza en el que los individuos permanecían “*libres*”, en paz, autosuficientes, como producto de la aparición de la propiedad privada y al desencadenarse el desorden, la colectividad, a fin de vencer ese estado de cosas requiere imperiosamente llegar a un acuerdo para superar la caterva, para él sinónimo de desigualdad; esa etapa de pactos una vez superada origina la República. Según Strauss (2006) Rousseau “Difiere de sus predecesores o, antes bien, se une a los modernos al negar que el hombre sea político por naturaleza; rechaza la idea que el hombre es dirigido por naturaleza hacia un fin, el fin de la vida política. La ciudad o el Estado son obra puramente humana, que se originó en el deseo de la propia conservación. Como tal el hombre no es concebible sin sociedad política” (p.532), sin embargo, en esta nueva etapa republicana, soberana “Cada cual pone en común su persona y su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro es considerado como parte indivisible del todo”.¹⁴

La voluntad individual se allana ante la voluntad colectiva general, sin dilapidar la libertad que cada uno posee en lo individual. El fin no es otro que: (...) “encontrar

13 Ib. Ib

14 Jean Jacques Rousseau: *El Contrato Social*. Madrid. Editorial Libsa. 2002. p.188

*una forma de asociación que defienda y proteja, con la fuerza común, la persona y los bienes de cada asociado y por la cual cada uno, uniéndose a todos los demás, no obedezca más que a sí mismo y permanezca tan libre como antes”.*¹⁵

De acuerdo a Rousseau, este poder soberano se mantiene en cada uno de los individuos para proteger sus derechos en conjunto, quienes no delegan su libertad, sino que obedece a sí mismo a través de la voluntad general. La autoridad absoluta del todo es la garantía de la libertad de todos porque el poder absoluto está en las manos de su legítimo titular que, por principio, no puede abusar de él ¿De Quién? del *pueblo*.

Aquí se refleja el rechazo rousseaniano a la división de poderes en órganos diferentes y da primacía al legislador como órgano supremo; ya que éste se forma de la expresión de la voluntad popular quien, a su vez, garantiza la presencia permanente del pueblo en el ejercicio del poder de manera *soberana*; sujeto a la ley; gobierno de las leyes. Este gobierno según él, sin embargo sólo se considera posible en sociedades pequeñas, su aporte contribuyó a fundamentar la democracia representativa. “*Cuando se estableció el gobierno representativo, la tradición medieval y las teorías modernas del derecho natural convergieron para hacer del consentimiento y la voluntad de los gobernados la única fuente de legitimidad y obligación política*”.¹⁶ El consentimiento y la concertación se hacen presente en la distribución y ejercicio del poder; es decir en las funciones que compete a cada cuerpo integrante del gobierno, teniendo prerrogativa la libertad y la dignidad de la persona que aspira a vivir en sociedad en paz, con respeto a su persona, se pacta para convivir no para destruirse unos a otros.

El último gran representante de esta corriente fue Emmanuel Kant, quien inspiró en sus obras nuevos sistemas y métodos con los cuales le otorga una valía especial al orbe jurídico, político y social; antes del precitado autor el conocimiento tenía como centro el *objeto* de donde partía su fundamento, sin embargo él introduce una novedad, ya no es el objeto aislado, el *sujeto* adquiere relevancia ante el objeto que aprehende. La razón (racionalismo) y la experiencia empirismo) se conjugan. Los objetos tradicionales de la metafísica: alma, mundo y Dios que no pueden ser constreñidos en un marco científico, pero debido a su importancia para el hombre igualmente no pueden ser desechados.

La dignidad del hombre es el vértice al que alude en su postulado sobre la autonomía. “*La autonomía es, pues, el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional*”¹⁷. Cuando se elige hacer el bien por voluntad propia se requiere condiciones de bondad, porque el mal se produce por cualquier fallo; la razón es porque el fin nunca justifica los medios. El fin es el elemento más voluntario y especificativo del actuar humano.

15 Ib, 187

16 Bernard, Manin: Los Principios del Gobierno Representativo. Madrid. Editorial Alianza.2006. p.116

17 Emmanuel Kant: Fundamentos de la metafísica de las costumbres, crítica de la razón práctica, la paz perpetua.Sexta edición. México. Editorial Porrúa. México,1986, p. 49

Persigue Kant un objetivo ideal. El hombre no debe jamás ser utilizado como medio, es decir subordinado a un ulterior fin extraño; (...) “el hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo no como medio”¹⁸.

Así se entiende otra fórmula que propone para expresar la ley fundamental de la razón práctica: “Obra de tal suerte que siempre tomes a la humanidad como fin y jamás la utilices como simple medio, ya en tu persona, ya en la persona de cualquier otro”¹⁹; pareciera querer salvar al hombre, le otorga un valor superior, aunque fuere especulación metafísica internalizando sus propuestas no dejan de estar llena de una sublimidad especial, aspira a la plenitud.(...) “dos cosas hay que llenan el ánimo de admiración y respeto siempre nuevos y siempre crecientes cuantas más veces y con más detenimiento se consideran: “*El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí*”²⁰, escribe al cerrar la *Crítica de la razón práctica*. La vista del cielo lleno de estrellas le recuerda al hombre que es una parte de este mundo material y sensible, con cuya grandeza comparado no es más que un pequeño e insignificante fragmento. Pero la ley moral penetra invisiblemente la interioridad ensalzando infinitamente el valor del hombre dotado de inteligencia, la cual le hace tener una vida independiente.

Es menester observar como los quiebres paradigmáticos van aportando razones para explicar los avances en el discurrir de la historia; otrora el derecho a la vida que se ha concebido como el derecho absoluto sin el cual los demás derechos no pueden ejercitarse; aún no adquiría la valía actual.

Posterior al racionalismo se sitúa el *Iluminismo*, siendo su representante más señero Christian Thomasius; el iluminismo se propone orientar la corriente de su pensamiento no sólo en el poder de la razón; sino en la orientación de la razón (...) hacia metas prácticas, con la intención de mejorar la condición humana por medio de unos principios racionales, extraídos del análisis crítico de los hechos”.²¹ Lo pragmático comenzará a hundir sus raíces; la razón se une a los sentidos a la experiencia; irradiándose en lo político, social, económico y cultural.

Thomasius; deslinda la moral del derecho, no sigue a ras la corriente del derecho natural; Dios si bien es autor de la Naturaleza (Revelación natural) y del hombre su referencia se difumina; patentiza en el obrar humano la esencia de la felicidad, debiéndose vivir en forma honesta, decorosa y justamente, esquematizándolos así:

a.- Lo honesto; referido a la moral a lo ético, al accionar externo su máxima consiste en: *hazte a ti mismo lo que quieras que los demás se hagan así mismos*; el cumplimiento de esto recae únicamente en el fuero interno individual; mientras exista congruencia entre el actuar y el pensar, se cumplirá el hecho de ser honesto, logrando el solaz o regocijo espiritual a quien lo practique.

b.- Lo decoroso; dirigido al actuar político parte del adagio *haz a los*

18 Op. Cit. 44

19 Ib. 45

20 Ib. 55

21 Op. Cit. 135

demás lo que quieras que los demás hagan contigo, se requiere alteridad para poner en práctica este principio característico de las relaciones benevolentes y efébiles, estando exentas de coactividad.

c.- Lo justo; su estandarte es *no hagas a los demás lo que no quieras que hagan contigo*; igualmente esta sentencia requiere una relación bidireccional, encierra coerción por cuanto repercute en el mantenimiento de la paz externa y trasciende al orden social.²²

En sus postulados se percibe lo jurídico y lo moral inicia (...) “la concepción liberal de las relaciones entre Iglesia y Estado y se consagra la separación entre el Moral y el Derecho; aunque la libertad de pensamiento y de religión han de estar protegidas por el poder político y el eclesiástico”.²³

Comienza a vislumbrarse más la secesión entre el poder espiritual ostentado por la Iglesia y el poder político, que se transfiere a las autoridades estatales como producto del consenso en crear un Estado, la protección jurídica plasmada en diversos instrumentos continua su ascenso.

1.2.2.- IUS POSITIVISMO

Como producto del consenso social en formar el Estado y este a su vez revestido de una serie de poderes, entre ellos el poder de legislar, el Hombre hace uso de la *voluntas social*, además apalancado con el desarrollo científico plasma en leyes esas normas, la historia y la realidad le van indicando el *iter* legislador, así para los positivistas las normas son tales y tienen un valor específico en tanto sancionadas por el legislador quedan estatuidas en las distintas codificaciones; poniéndose de manifiesto en el poder que tiene el Estado al dictar leyes (*legem ponere*) de la efectividad que pueda tener el derecho; se subroga la detentación a su vez del poder de hacer cumplir la ley, controlando la acción de los ciudadanos por medio del poder coactivo. “Según la concepción positivista tradicional, en la aplicación del derecho la regla jurídica se obtiene teniendo en cuenta exclusivamente las exigencias del derecho. Exactamente eso significaban la interpretación y los criterios (o cánones)”.²⁴

El ius positivismo sienta su fundamento en esas normas jurídicas producto de la legislación, sobre ellas no impera otro poder; ante esta realidad surge en Francia la *exegética*, no dejando margen de discreción sino la aplicación de la ley, es la voluntad del legislador. “Se eliminaba así de raíz toda influencia del caso en la interpretación del derecho. La labor de la jurisprudencia se agotaba en el mero servicio al legislador y a su voluntad”.²⁵ Augusto Comte sembró las bases del positivismo, aunque no dirigido específicamente a la ciencia jurídica, sino en un programa tendiente a la política, en forma científica, al observar comunidades y su evolución (Sociología). De allí, sobreviene que en el positivismo los hechos son lo relevante y su concordancia con la ley, sin

22 Ib. 138

23 Ib. Ib

24 Op. Cit. 132

25 Ib. Ib

embargo, Millán Puelles (2004), considera que:

(...) el positivismo jurídico se gesta en la aventura del protestantismo, especialmente en lo que tiene que ver con la moral. El protestantismo establecerá aquel famoso principio: la religión es cosa privada, no pública. De ahí se pasará luego a decir: la moral es cosa privada, no pública. En el terreno de lo público, por tanto, el derecho (el derecho se refiere a lo público) no tendrá por qué tener en cuenta una dimensión privada, como sería la de la moralidad. Todo eso arranca de ahí: de un protestantismo que va a dejar la moral en el hombre, en la pura conciencia; pero de una conciencia que no está abierta a valores absolutos, y que por tanto no necesita formarse para adquirir una buena conciencia de esos valores. Una moral autónoma, una conciencia autónoma, autosuficiente, donde — naturalmente — cada cual, como dice Kierkegaard que le pasaba a Sancho Panza con los azotes, está siempre diciendo: 'bueno, yo me daré los azotes cuando yo diga', y uno no lo hace nunca.

El hombre no es visto de manera unitaria en el positivismo jurídico. Cada autor matiza su entendimiento del mismo. Para Bentham, el hombre es individuo que en su suma constituyen la sociedad.²⁶ Sociedad que es posible porque esos individuos deben obediencia a una persona o asamblea de ellas.²⁷ El fin del hombre es la mayor felicidad. La búsqueda de la mayor cantidad posible de felicidad es el principio que gobierna el mundo moral, así como las leyes descritas por Newton gobiernan el mundo físico. El individuo no tiene derechos naturales salvo algunos como la libertad, igualdad y propiedad en orden a conseguir la seguridad y, en consecuencia, la mayor felicidad. Se convierte en un férreo fanático en contra del derecho natural.

Después de la Revolución Francesa surgió el fenómeno de la codificación irradiándose en Europa; en 1814 A. Thilbaut publicó su tesis *Sobre la necesidad de un Código Civil para Alemania* y no vaciló en considerarlo "el más hermoso regalo del cielo".²⁸ Al unísono surgió la idea de Friedrich Karl von Savigny, quien no consideraba la codificación como una metodología adecuada para unificar la legislación dispersa; sino estimaba que la investigación jurídica debía centrarse en la *historia*, y esta historia es concebida como producto del *Volkgeist* (el espíritu del pueblo), los hechos y la experiencia social le proporcionan al legislativo los elementos para plasmar en las leyes el espíritu consuetudinario, aunque Savigny distingue en su mitología el Derecho del Pueblo del derecho científico; el jurista se limitará a dar forma científica al derecho consuetudinario del pueblo; expurga lo intrascendente para adaptarlo al contexto social actualizado, del *depositum legem* los juristas desarrollan la ley escrita, otorgándole el sello científico.

A Savigny le precedió Georg Friedrich Puchta, quien continuó con el legado de historicismo, al que enriqueció en su obra sobre el Derecho de Pandectas;

26 Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London. 1970. p.11-13

27 Ib. Ib

28 Op. Cit. 186

K Larenz al diferenciar el sistema de Savigny y Puchta señala: (...) Puchta es el primero en presentar el Derecho como un sistema lógico jerarquizado, que presenta más bien la forma de una pirámide (...) Tal método racional, al que sólo la terminología «organicista» de Puchta nos permite emparentar con el historicismo, se pretende «genealógico» y aspira, en palabras del propio autor, a conocer las proposiciones del Derecho en su conexión sistemática «como recíprocamente condicionadas y derivadas unas de otras» (...) Con ello la Ciencia del Derecho (Jurisprudencia) tomaba carta de naturaleza como autentica fuente del Derecho”.²⁹

Los juristas son los llamados a extraer de la realidad histórica y social el sentir del individuo, del pueblo, por cuanto a este es en definitiva a quien se le aplicará el positivismo abstraído en la letra de la norma, se convierte en dogmatismo, por lo que generó también fervientes críticas.

Otro insigne representante del ius positivismo es Hans Kelsen, fundador del Círculo de Viena, quien en su obra *La teoría del Derecho* de entrada plantea que: “La teoría pura del Derecho es una teoría del derecho positivo; es teoría general del derecho, no una exposición o interpretación de un orden jurídico particular” (p. 15). De una vez manifiesta tajantemente su objetivo, no se detendrá a divagar y concibe al derecho libre de elementos metajurídicos; el hombre está escindido entre el mundo del “ser” y del “deber ser”; el hombre sólo es capaz de conocer lo dado, escapándosele toda metafísica; pretende (...) “brindar una definición de la norma jurídica totalmente independiente de la noción de norma moral (...) al afirmar la autonomía del derecho respecto de la moral.

Sin embargo, para él, los intentos del positivismo no habían confinado totalmente la vinculación del Derecho a la justicia creada por el iusnaturalismo. “Hay muchas y muy diferentes ideas de justicia, demasiadas para que uno pueda hablar simplemente de “justicia”(…) La necesidad de una justificación racional de nuestros actos emocionales es tan grande que busquemos satisfacerla aún a riesgo de engañarnos nosotros mismos (...) la justificación racional de un postulado basado en un juicio subjetivo de valor, en un deseo, como por ejemplo, de que todos los hombres sean libres, o de que todos los hombres sean tratados igualmente, es un auto engaño, o — lo que en gran medida equivale a lo mismo — una ideología.”³⁰

La preocupación del positivismo es el derecho “real”, lejos de planteamientos del “derecho justo” o del conocimiento socio-psicológico de las causas que generan las normas; sin embargo tal como ha quedado plasmado las diferentes corrientes de pensamiento han aportado ideas al jurista de hoy, es necesario conocer el decantamiento jurídico para situarse en determinada posición, no se ha llegado a formar todo el *corpus* que existe en relación a los derechos humanos sin asirse de las semillas de los precursores del derecho.

29 Op. Cit. 192

30 Ib. 212

1.2.3.- CONJUGACIÓN DEL IUS NATURALISMO Y IUS POSITIVISMO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS

El ius naturalismo se nutre por supuesto del derecho natural al considerar este derecho como un conjunto de derechos y deberes que tienen una aplicación válida en las relaciones de los ciudadanos, dejando atrás la visión de tener sólo aplicabilidad en el aspecto o disciplina moral. Existen principios que el legislador no puede obviar al momento de sancionar la ley; el hombre tiene impregnado en sí mismo por su naturaleza unos atributos particulares que le hacen diferente a otros seres, caracterizándolo y enaltecéndole; en consecuencia, el derecho la vida y la libertad por ejemplo, no adquieren carta de ciudadanía sólo por estar plasmados en una norma o precepto que la garanticen; son faros que guían el barco a un buen resguardo.

Max Weber definió el derecho natural como: "Conjunto de normas vigentes preeminentemente frente al derecho positivo y con independencia de él, que no deben su dignidad a un establecimiento arbitrario, sino que por el contrario, legitiman la fuerza obligatoria de éste. Es decir, el conjunto de normas que valen no en virtud de provenir de un legislador legítimo, sino en virtud de cualidades puramente immanentes".³¹ Indudablemente el ilustre pensador alemán se refiere al iusnaturalismo clásico de tipo laico, un derecho válido para todos los tiempos y para todos los pueblos, intrínseco en la persona humana, concebido naturalmente, aún antes que cualquier Estado o sociedad; se percibe el elemento a-histórico en contraste con el derecho positivo; la justicia sobre todo en materia de derechos humanos no se puede condicionar; sin embargo ante la imposibilidad de encapsular todas las conductas humanas se ha hecho innegable el establecimiento de principios universales (espacio) e inmutables (tiempo).

El derecho positivo alcanza gran desarrollo y es concebido como un instrumento técnico y eficaz para regir y mejorar, gradualmente, las condiciones de la convivencia humana; actividad y experiencia autónoma e independiente de significados y sentimientos religiosos y metafísicos. Las fisuras que han surgido alrededor de las dos corrientes de pensamiento han tenido que deponerse ante la realidad. El iusnaturalismo no puede considerarse como una supervivencia anacrónica de tiempos pasados, sino como un anhelo del hombre; esto se hizo evidente en los Juicios celebrados en la ciudad Alemana de Nuremberg; el fundamento sobre la existencia de un derecho natural para impedir la impunidad, fue el argumento central y neurálgico que primó para constituir el Tribunal Militar Internacional y efectuar los diferentes procesos jurídicos de los jerarcas nazis.

Otra causa que también influyó en el renacimiento iusnaturalista fue la tensión intelectual producida en Occidente por el materialismo histórico, por las críticas y ataques radicales de Marx contra el Derecho de la sociedad capitalista; recurriéndose en defensa a criterios o argumentos axiológicos o de Derecho Natural, por cuanto el positivismo desnudo, montado en última instancia sobre la factividad de la autoridad y del poder se encontraba inerme e indefenso. Se ha visto en ocasiones como ambas corrientes han podido apoyarse mutuamente y de esta unión concebir grandes obras; así se

31 Max Weber: Economía y sociedad. México. Fondo de Cultura Económica. 1944.p. 640

tiene que los embates al predominio de la razón y como consecuencia la negación de la posibilidad de conceptos universales, constituyó una de las motivaciones determinantes del positivismo naturalista vigente en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, el racionalismo contra el cual reaccionaba dicho movimiento fue considerado por el mismo como el soporte ideológico de la Revolución Francesa; por ello el positivismo a pesar de su laicismo y de su sentido antimetafísico, fue conservador, expresión cultural de una burguesía que había alcanzado plenamente el disfrute del poder social, político y económico.

La realidad social que el derecho ordena utilizando una estructura de normas jurídicas, es compleja. Se observan tensiones políticas, económicas, culturales, ideológicas, intereses de grupos, costumbres, valores; es necesario conocer ese conjunto complicado y racionalizar en la medida de lo posible esa realidad para transformarla, al menos, en una estructura comprensible, para poder interpretar las motivaciones verdaderas de la concreta actividad humana, el hombre es el creador del orden humano de convivencia, teniendo en consecuencia en materia de derechos humanos, donde incluso el interés debe centrarse en la sobrevivencia de la propia especie humana poner en común todos el esfuerzo, bienes y recursos; colocar al servicio del mismo hombre *el poder*, la voluntad de quienes dominan.

Nada lo expresa mejor que el párrafo donde Trasímaco dirige a Sócrates:

"Y así, cada gobierno establece las leyes según su conveniencia: la democracia, leyes democráticas; la tiranía, tiránicas; y del mismo modo los demás. Al establecerlas, muestran los que mandan que es justo para los gobernados lo que a ellos conviene, y al que se sale de esto lo castigan como violador de las leyes y de la justicia. Tal es, mi buen amigo, lo que digo que en todas las ciudades es idénticamente justo: lo conveniente para el gobierno constituido. Y éste es, según creo, el que tiene el poder; de modo que, para todo hombre que discurre bien, lo justo es lo mismo en todas partes: la conveniencia del más fuerte".³²

En el marco de los derechos humanos transgeneracionales hay que deponer pasiones y apetencias; el factor determinante es el hombre; constituye el hombre el centro y punto de partida, entre doctrinas y teorías, muchas veces excluyentes y contradictorias. La posibilidad de preguntarse por el cimiento de la dignidad humana, por el origen de su dimensión ética, por la función creadora de su razón, por el sentido que tiene esa insobornable ansiedad del alma de trascender a lo fáctico, está más allá de lo estrictamente jurídico-positivo. En la actualidad el hombre se encuentra ante un panorama que rebasa su capacidad temporal de comprensión; adentrarse en interpretaciones o posiciones donde no cedan los antagonismos limitará las soluciones que a la larga acabarán con su *propia naturaleza*.

1.3.- OTROS ENFOQUES PARADIGMÁTICOS

A parte de los enfoques iusnaturalistas y iuspositivistas, es menester

32 Platón: La República. Madrid. Instituto de Estudios Políticos. 1949. Tomo 1. p. 24

en aras de la presente investigación abordar el tema elegido desde otras perspectivas como por ejemplo la ideología marxista; la cual al inmiscuirse en la problemática de los obreros; centró su atención sobre un cambio social de primerísima importancia que se produjo en el siglo XIX: el surgimiento de la conciencia política y, finalmente, el ascenso hacia el poder político, de una clase trabajadora industrial, condujo a la interpelación del pensamiento liberal, presentaba al capitalismo por primera vez en lo que podría llamarse su aspecto humano, como institución que había producido y aumentaba constantemente una clase de hombres que tiene que vivir absolutamente del salario y se relacionaba con su patrono sólo mediante un nexo monetario.³³

El marxismo presentaba una realidad en un contexto social que llevó incluso a la Iglesia a pronunciarse en la celebre encíclica *Rerum novarum* de León XIII; la lucha de clases, las condiciones infrahumanas, la desvalorización del trabajo humano, presentan un nuevo matiz que fuera de las desviaciones y radicalismo implementado por la Rusia bolchevique, pone en evidencia el surgimiento de ideólogos que darán nuevos visos a la realidad circundante. Para el marxismo el derecho es un instrumento de la clase dominante para imponer su voluntad; infiriéndose si esto es así, que el derecho sirve para que los países ricos se impongan ante los subdesarrollados, traducido en la violación de derechos humanos de los poderosos contra los oprimidos; el Estado burgués, es instrumento de dominación; para los marxistas, todas las teorías que consideran el Estado como ordenador del bien común, como el defensor del interés general, no son más que medios utilizados para camuflar su dominación y hacerla aceptar por la clase explotada. Según Lenin, es “una máquina hecha para mantener la dominación de una clase sobre la otra”.³⁴

Al investigar sobre la vulneración de los derechos transgeneracionales, habrá que afrontar esta disyuntiva; el enfrentamiento perenne de poderosos y débiles y en el orden del derecho internacional países ricos contra países pobres, ricos que no firman tratados inherentes a la protección de los derechos humanos, pero sí a través de las grandes transnacionales contaminan y depredan el ambiente no sólo en sus propios países, sino más aún en los suelos de muchos países pobres. He allí la dicotomía de los derechos humanos.

Los enfoques epistémicos aplicados a los derechos humanos están definidos están enmarcados por el reconocimiento de un derecho inmanente, universal, intransferible e inherente; que se está por encima de pareceres particulares y existe ante cualquier norma impuesta por el Estado. En el siglo XXI se debe imponer la medida ante la cruda realidad que amenaza tanto a los habitantes de los países ricos como a los de los países pobres. Uno sólo es el planeta tierra donde deben convivir *todos*.

33 George Sabine: Historia de la teoría política. México.Fondo de Cultura Económica. Séptima reimpresión 2006. p. 562

34 Ib. Ib

CAPITULO II

DEFINICIÓN, EVOLUCIÓN Y TRASCENDENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Se estima conveniente realizar un esbozo acerca de los derechos humanos; su definición, fundamento, historicidad, variables que los caracterizan clasificación; a fin de imbricarlos como prolegómenos hacia la concepción de los derechos humanos desde una perspectiva transgeneracional.

“Si bien todos los derechos son «humanos», en cuanto sólo el hombre es sujeto de derecho, la evolución de las ciencias jurídicas ha dado lugar a una categoría de derechos denominada «humanos», también conocidos como derechos del hombre, derechos naturales, derechos innatos, derechos originarios, derechos fundamentales”.¹ Esto es cierto, lo que hoy día se conoce como: derechos humanos, también han sido conocido bajo la acepción de «derechos del hombre»; así lo hace saber Truyol y Serra (2000), quien señala que esta expresión (...)“solemnemente consagrada en Francia a raíz de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por su Asamblea Nacional el 26 de agosto de 1789; «*droits de l' homme*» se siguen denominando así en los países francófonos de un modo exclusivo. También en Inglaterra y en los países anglófonos se introdujo la expresión, popularizada en el celebre libro de Thomas Paine *The Right of Man*.” (p.21).

En esta celeberrima obra Payne, expone ya una aproximación que enmarca a los derechos humanos; dice así, “Los derechos naturales son los que pertenecen al hombre por el mero hecho de existir. De este genero son todos los derechos intelectuales, o derechos de la mente, así como todos los derechos de actuar como individuo para su bienestar y felicidad propios, siempre que no vayan en contra de los derechos naturales de otros”.²

De allí, que la acepción derechos del hombre - derechos humanos, independientemente como se utilice, comprende o se refiere o a unos derechos poseídos, propios del ser humano; ninguna otra especie es capaz de aprehender o detentar tales atributos. Su inmanencia es intrínseca al género humano.

1 Embid Irujo Antonio y otros. El derecho a un medio ambiente adecuado. Gobierno de Aragón -Instituto Aragonés del Agua. 2008. p 491

2 Paine Thomas: Op. cit. p. 97

2.1- DEFINICIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Esta denominación *The Right of Man*, ha sido adoptada modernamente en el contenido que define a los derechos humanos, entendidos estos desde dos corrientes del pensamiento como lo son la iusnaturalista y la iuspositivista.

Aunque, para Nikken (1994), esta contraposición no tiene mayor trascendencia. Al efecto, este autor reivindica que:

“La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. ...Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar son los que hoy conocemos derechos humanos”. (p. 15).

En esta concepción se vislumbra dos realidades intrínsecas, en primer lugar los derechos humanos son inherentes a la persona humana, al hombre como única criatura capaz de ser susceptible de ellos y en segundo lugar, son derechos que se afirman frente al Estado, quien tiene la obligación, el deber de hacerlos efectivos.

También, en esta materia Faúndez Ledesma (1999), expresa que los derechos humanos pueden definirse como las *“Prerrogativas que, conforme al Derecho internacional, tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual, o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado, para satisfacer sus necesidades básicas, y que reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de que forma parte”* (p.28). Deja atrás la controversia entre los iuspositivistas y iusnaturalistas y se centra en fundamentar su definición en ciertos derechos elementales propios de la persona humana por su condición de *“Homini”*, por el hecho de poseer dignidad. Más, aún este autor precisa el carácter universal de estos derechos, aludiendo tanto a los derechos civiles y políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales; derechos que han sido reconocidos en sendos pactos de orden internacional. Esta definición a su vez enfatiza el carácter histórico y valorativo, sugiriendo que *“son el producto inacabado de las luchas sociales, y que reflejan el tipo de sociedad que queremos”*.³

Visto, lo anterior, se puede inferir que: *Los derechos humanos conforman un conjunto de normas y principios que se le reconocen y protegen a la persona humana, tanto como individuo o como agrupación de ellos, y a su vez determina los órganos y mecanismos de protección de los mismos contra las posibles violaciones por parte del Estado.* De esta manera se tiene lo siguiente:

- Reconocen y resguardan los derechos del ser humano, como individuo o como agrupación de ellos, con independencia de su nacionalidad;
- Conjunto de principios y normas de Derecho, las cuales pueden ser de orden nacional contenidos a su vez hoy día mayoritariamente en instrumentos internacionales sobre esta materia de orden declarativo y convencional;
- Y establecen los órganos y mecanismos de protección de dichos derechos frente a las posibles violaciones por parte del Estado.

3 Ib. Ib

Históricamente, la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano, no puede ser empleado encubierto bajo el manto de la legalidad o legitimidad para ofender atributos inherentes a la persona.

Human rights are commonly understood as being those rights which are inherent to the human being. The concept of human rights acknowledges that every single human being is entitled to enjoy his or her human rights without distinction as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status” (Basic Handbook For UN Staff)⁴.

La responsabilidad del Estado es tal, que no sólo por medio de sus agentes transgrede, vulnera los derechos humanos, sino además cuando no impide que otras personas lesionen la dignidad humana que está obligado a respetar y garantizar en su goce y ejercicio que le corresponden. En este sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Ximenes López contra Brasil*: “La Corte, además, ha establecido que la responsabilidad estatal también puede generarse por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado. Las obligaciones *erga omnes* que tienen los Estados de respetar y garantizar las normas de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos, proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales”⁵. (Párr. 85). El Estado puede ser imputado de violar derechos humanos cuando concede autorización, a terceros que bien pueden ser personas físicas o jurídicas para desempeñar actividades estatales; y estas personas entren en la esfera de las conductas descritas conforme a la “Resolución de la Comisión de Derecho Internacional,⁶ que describe las conductas que puede asumir una persona o entidad, que si bien no es un órgano estatal, está autorizada por la legislación del Estado para ejercer atribuciones de autoridad gubernamental. Dicha conducta, ya sea de persona física o jurídica, debe ser considerada un acto del Estado, siempre y cuando estuviere actuando en dicha capacidad” (párr. 86).

La protección de los derechos humanos corresponden a los Estados, a quien le compete el deber de fiscalización, vigilancia y control cuando delega en terceros la realización de alguna actividad propia de su competencia. El

4 www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf

5 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 113; Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 21, párr. 111; y Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 140.

6 Cfr. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Comisión de Derecho Internacional 53º sesión, 2001. Documento de la ONU A/56/10. Texto introducido en el anexo de la Resolución 56/83 de 28 de enero de 2002, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

deudor por la vulneración de los derechos humanos es el Estado y no los particulares, (...) aspecto al que la doctrina se ha referido como '*efecto vertical*' de los derechos humanos; igualmente se produce el llamado '*efecto horizontal*', ante las relaciones con otros individuos, por cuanto es el obligado a garantizar su ejercicio.⁷

El catálogo de derechos humanos, si bien es cierto que están vertidos en las Constituciones y en diversos tratados, pactos y convenios a nivel internacional, esto no basta para su protección real y efectiva; el resguardo, salvaguarda de los derechos humanos va mucho más allá de la letra, la violación, vulneración, quebrantamiento de los derechos humanos, comporta transgresión hacia unos ideales que aspiran a transformar una realidad y no volver a errores del pasado.⁸

2.2.- FUNDAMENTACIÓN

La fundamentación de los derechos de la persona humana se ha centrado en buscar una justificación racional de esos derechos. En el plano de las doctrinas filosóficas puede afirmarse, sin simplificar demasiado, que existen dos posiciones opuestas:

- 1.El Derecho Natural; y la
- 2.Histórico-positivista.

Para los primeros el fundamento de los derechos de la persona humana se sustenta sobre la base de la doctrina filosófica aristotélica. (...) "Al aplicar a las formaciones humanas su concepción finalista de la naturaleza; llegó a erigir como principio que los individuos buscan el estado social y civil por su mismo título de hombre. Y puesto que la naturaleza es la que los incita a dicho estado, vio enseguida que a ella le corresponde proporcionarle las reglas fundamentales del mismo.

Y de ahí su idea de derecho natural, de ese derecho que es invariable y que tiene por doquier la misma fuerza. Y un derecho que trasciende los compartimientos políticos, que es universal y puede regir a todos los hombres".⁹

Este sustento filosófico posteriormente se convirtió en filosófico-teológico, con Tomás de Aquino; a quien se le atribuye la cristianización de los postulados del Estagirita; viendo en el hombre creado a imagen y semejanza de Dios «*Imago Dei*» una criatura poseedora de unas cualidades o potencias únicas como lo son la voluntad, la inteligencia y la memoria; la imagen de Dios reflejada en cada hombre. Es menester, señalar también al filósofo y orador romano Cicerón, por cuanto es indudable su aporte a lo que se ha sostenido como derecho natural e inalienable del hombre; a pesar de haberse extraviado durante mucho tiempo el texto de la *República* y no fue recuperado sino hasta el XIX, sus pasajes más importantes habían sido reproducidos en los libros de

7 Ib.29

8 Cfr. Max Weber: El político y el Científico. Madrid Alianza Editorial. p.84

9 Lachance, Louis: El Derecho y los Derechos del Hombre. Madrid. Ediciones. Rial, S.A.1979. p. 208

San Agustín y de Lactancio y llegaron por ello a ser del conocimiento común. El estandarte de la igualdad sellará el pensamiento cristiano a posterior, con esta idea:

La verdadera ley consiste en la recta razón conforme a la naturaleza, de validez para todos los tiempos, invariable e imperecedera, que llame al cumplimiento del deber con sus órdenes y aparte del delito con sus prohibiciones; una ley, no obstante, que lo mismo que sus órdenes y prohibiciones no resultan ignoradas por los honrados, tampoco logra que los honrados la obedezcan en aquello que les mande o prohíba. Sustituir esta ley por otra es un sacrilegio, y tampoco es lícito derogarla en alguna de sus partes, ni es posible anularla en su totalidad; ni, por otra, tampoco podemos sustraernos de esta ley por medio del Senado o del pueblo, ni hay necesidad de buscar a un Sexto Elio para que la explique e interprete; ni será una ley en Roma y otra en Atenas, una ahora y otra después, será una sola y única ley, imperecedera e inmutable, regirá a todas las naciones y en todas las épocas, y será un dios solo y común para todos, un jefe y comandante supremo de todas las cosas: tal es el descubrimiento de esta ley, su administrador y promotor; quien no la obedezca se verá obligado a huir de sí mismo y de su naturaleza humana sufrirá los más graves castigos, aunque haya logrado escapar a los demás suplicios considerados como tales¹⁰.

La igualdad de los hombres no la sostiene Cicerón como una tabla rasante en cuanto a la posesión de riqueza o capacidad intelectual, sino por la propia conformación del hombre como raza, como único ser dotado de razón para distinguir lo bueno de lo malo, lo lícito de lo ilícito. Cicerón refleja en sus pensamientos la innegable influencia de Hipias, quien enseñaba que: “Todos los hombres son iguales, y que sólo por virtud de las leyes hechas por el hombre se introdujeron la desigualdad y la esclavitud”; por esto los sofistas fueron considerados “inmorales”, por cuanto iban en contra de una idea consustanciada con el mundo griego, la existencia de la esclavitud, a la que no se opusieron Platón ni Aristóteles.¹¹

San Agustín, y Santo Tomás, se convirtieron en paladines con sus bastas obras doctrinales de la unidad del género humano que lleva consigo la igualdad entre los hombres proveniente del Dios Padre Creador.

Señala Bidart Campos (1991). “Nos gusta recalcar el aporte iusnaturalista de Grocio, cuando con frase atrevida — y muchas veces mal interpretada — sostiene que el derecho natural existiría aunque Dios no existiera (...) lo que él pretende señalar es que el derecho natural con tanto vigor en la naturaleza humana, que aunque Dios no fuera el origen y la causa de ella, el derecho natural lo mismo sería lo que es, porque es el propio de aquella naturaleza” (p.88). Esto pareciera una contradicción por cuanto quienes sustentan la existencia del derecho natural, se fundamentan en un derecho devenido de Dios, entonces si se tiene «que el derecho natural existiría aunque Dios no existiera», es negar

10 Cicerón: La república y las leyes. Madrid. Ediciones Akal/Clásica. 1989. II, 22. p.141-142

11 Op.cit. 145

la existencia de la Creación por parte de Dios (...) el hombre, en efecto, tiene el poder de producir o crear. Y, entre otras cosas, él produce, a partir de ciertas causas o principios originarios, sus hechos y acciones.

¿Por qué tiene este poder? La acción es algo que no se puede atribuir a ninguna sustancia inanimada, ni siquiera a ninguna existencia animada, excepción hecha del hombre".¹² El hombre hecho a imagen de Dios "*Imago Dei*", (Gn. 1,26) por su infinita bondad, posee facultades, potencias (Inteligencia y voluntad) que lo hacen capaz de aprehender de su entorno, se enseña sobre las demás criaturas, como consecuencia de esa semejanza con Dios "*Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya*" (Gn. 1,27), es al hombre a quien se le revela, es al hombre a quien le ofrece la inmensa belleza de la Creación visible y es al hombre a quien le confiere el don de la fe.

El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento; pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor; y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. (Concilio Vaticano II, *Gaudium et spes*, 19, 1)

El Hombre es un ser dotado de razón y libre voluntad, que posee un fin propio. Estos caracteres son los que le dan la dignidad de que goza. En consecuencia, la verdadera filosofía de los derechos de la persona descansa en la dignidad y en el fin trascendente de ella. Los derechos humanos son inherentes a la propia naturaleza humana y por ende anteriores a la existencia del propio Estado, quien se limita a reconocerlos. En conclusión, para Peces-Barba (1999), la expresión «derechos naturales» supone:

1. Unos derechos previos al Poder y al Derecho positivo, que como el Derecho Natural es Derecho, tienen una dimensión jurídica.
2. Se descubren por la razón en la naturaleza humana.
3. Se imponen a todas las normas del Derecho creado por el Soberano y son un límite a su acción. (p.26)

Para los positivistas, el hombre, en razón del desarrollo histórico de la sociedad, se encuentra revestido de derechos variables y sometidos al flujo del devenir que impone la convivencia social, consideran que estos derechos son únicamente aquellos reconocidos expresamente en el texto constitucional por el propio Estado, teniendo por ello un carácter constitutivo su consagración.

En este ínterin resultan primordiales los aportes del constitucionalismo. (...) a través de aportaciones plurales, desde los monarcómacos a los ilustrados, pasando por el juez Coke y los demás impulsores del constitucionalismo inglés, por los iusnaturalistas racionalistas, por los autores de las sectas minoritarias, por los libertinos, por Locke, por Montesquieu y por Voltaire, entre otros, se elaborará una teoría coherente sobre el origen, el ejercicio,

12 Aristóteles, "*Ética*", (Obras Selectas). Madrid. Edimat Libros, S.A. 2001, pág. 338

los límites y los fines del poder, de la que serán una parte importante” [los derechos humanos].¹³

No puede dudarse que después del trance de la barbarie a la civilización, la expresión más notoria de esta conquista es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternamente los unos con los otros”.

Al transcurrir el tiempo la hegemonía del cristianismo que contribuyó a enraizar el derecho natural, fue en declive; bien sea por oposición dentro de la misma Iglesia al poder absoluto de los papas, el alto costo que implicó el sufragio de las cruzadas, la expansión del Islamismo etc. Pero, el despertar de la humanidad hacia rumbos libertarios generaron gestas revolucionarias que signaron sus tiempos. Los siglos XVII y XVIII se presentan como la era del racionalismo y del iluminismo, sin embargo, aún la filosofía del derecho natural ejercía gran dominio en la intelectualidad del momento; es plausible mencionar la Declaración de Derechos de Virginia el 12 de junio de 1776; como base y fundamento de su gobierno expresa lo siguiente en el artículo 1:

“Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los que, cuando entran en estado de sociedad, no pueden privar o desposeer a su posteridad por ningún pacto, a saber: el goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y poseer la propiedad y de buscar y obtener la felicidad y la seguridad”; y

en el artículo 16:

*“(…) Que la religión, o las obligaciones que tenemos con nuestro Creador, y la manera de cumplirlas, sólo pueden estar dirigidas por la razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia; y, por tanto, todos los hombres tienen idéntico derecho al libre ejercicio de la religión, según los dictados de la conciencia; que es deber mutuo de todos el practicar la indulgencia, al amor y la caridad cristiana” (...)*¹⁴

Además, la Declaración de independencia del 04 de Julio; también señala:

*(…) todos los hombres han sido creados iguales, que han sido dotados por el Creador de ciertos derechos innatos; que entre esos derechos debe colocarse en primer lugar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; y que para garantizar el goce de esos derechos los hombres han establecido entre ellos gobiernos cuya justa autoridad emana del consentimiento de los gobernados”*¹⁵.

13 Op.cit. Peces-Barba; acoge el termino Derechos Fundamentales por las siguientes razones: a) Es más precisa que la expresión derechos humanos y carece del lastre de la ambigüedad que ésta supone. b) Puede abarcar las dos dimensiones en las que aparecen los derechos humanos, sin incurrir en los reduccionismos iusnaturalistas o positivista (p. 37)

14 <http://www2.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-hist-Virginia.html>

15 <http://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html>

Los Derechos del Hombre y del Ciudadano paridos de los revolucionarios franceses, del mismo modo recogieron en su declaración ideas concebidas bajo el amparo «de la gracia de Dios», a pesar de su marcado carácter laico; la iglesia atesoró el conocimiento e impulso la creación de las universidades, las bibliotecas, las bellas artes, en fin la cultura; por lo que las ideologías, vinieran de donde vinieran no podían evadir el componente religioso. Así, tenemos desde 1789, esta hermosa declaración:

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre, son las principales causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre...con el objeto de toda institución política y sea respetados; para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora sobre principios simples e incontestables, tiendan siempre al mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del ser supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano.

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternamente los unos con los otros.

En la misma dirección posteriormente, el párrafo primero (común) de los Preámbulos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresa: (...) conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”.

Asimismo, los Preámbulos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen: (...) los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana (...).

Por su parte, el Preámbulo de la Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos, expresamente reconoce:(...) por una parte, que los derechos fundamentales del ser humano se fundamentan sobre los atributos de la persona humana, lo que justifica su protección internacional; y por otra parte, que la realidad y el respeto a los derechos del pueblo deben necesariamente garantizar los derechos humanos (...).

2.3.- HISTORICIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS

La idea de que existen derechos intrínsecos en el hombre por su dignidad de persona humana, trasciende por el testimonio escrito desde la antigüedad; y por obras vertidas de contenidos primigeniamente filosóficos y teológicos, obras que legaron un ideario que luego fue recogido por otros pensadores,

delineándose los fundamentos sobre los cuales se ha arraigado la inmanencia de los derechos humanos como aquellos que se afirman más allá de toda ley, orden o autoridad, sin embargo (...) la conciencia clara y universal de estos derechos es propia de los tiempos modernos., donde se han consagrado jurídicamente. Ello, no supone evidentemente que el hombre medieval no tuviera tales derechos. Lo que ocurre es que la Edad Media, e incluso la Edad Moderna durante el llamado «Antiguo Régimen» (que en determinadas zonas, movimientos y corrientes se prolongó hasta bien entrado el siglo XIX, en espera de intentar resurgir bajo nuevas formas en el siglo XX), conoce «derechos estamentales», derechos propios de los estamentos, de los «estados» u «órdenes» en que aparece estratificada la sociedad feudal.¹⁶

En la recopilación realizada por el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA)¹⁷, señalada por Raúl Cubas (2004) en: “Proyecto de Capacitación de Jueces en Derechos Humanos (Manual de Participantes)”, se puede resumir el desarrollo evolutivo de los derechos humanos con sus hitos más importantes de la siguiente manera.

2.3.1.- EDAD ANTIGUA

El concepto de persona y de derechos que le son inherentes es desconocido por el Hombre de la Antigüedad o Edad Antigua¹⁸. Las prerrogativas y privilegios, en la concepción primitiva, “mágica,” era autoritaria; venía de los dioses y se dirigía a los hombres a través de otros hombres, pero desconociendo siempre el diálogo. Sin embargo, puede afirmarse que hay algunos datos que permiten afirmar el comienzo, aún en grado muy incipiente, del reconocimiento de la dignidad de la persona humana.

Cubas, citando a Bonilla San Martín (2004), ejemplifica lo anterior aludiendo el prefacio del Código de Hammurabi el cual dice: “Entonces [los dioses] ANU Y BEL complacieron a la carne de los hombres llamándome a mí, el dios tenido Hammurabi, para establecer justicia en la tierra, para destruir lo ilegítimo y los males y para contener al poderoso en su opresión del débil”. (p. 47).¹⁹

Igualmente, el filósofo Chino contemporáneo Chun-Shu-lo (1973), señala que la idea de los derechos humanos se desarrolló muy pronto en China, y desde muy temprano se estableció el derecho del pueblo a rebelarse contra los emperadores tiránicos. El término “revolución” no se consideraba peligroso, sino que a él se asociaban altos ideales, y se le usó constantemente para referirse al justificable derecho que el pueblo tiene de derrocar a los malos soberanos. En la antigua China el emperador tiene un deber para con el cielo:

16 Op.cit. p.23

17 <http://www.iepala.es/ddhh>

18 “Todavía hoy se discute la cuestión de cuanto duró la Edad Media. Sólo en el siglo XVII se hizo habitual en Europa la división << Edad Antigua >>, << Edad Media >>, << Edad Moderna >>” Küng, Hans, “El cristianismo (esencia e historia)”, Colección Estructuras y Procesos, serie religión, Madrid 4ta. Edición. Editorial Trotta, 1997. p. 295

19 <http://biblioteca.universia.net/irARecurso.do?page=http%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F2027%2Fuc1.b4184989&id=49696021>

tiene que cuidar de los intereses de su pueblo. Amando a su pueblo es como el emperador acata la voluntad del cielo. Por eso se dice en el Libro de la Historia (que es una antigua obra clásica) que: "(...) El cielo ama a su pueblo, y el soberano debe obedecer al cielo". Cuando el soberano no gobierna ya para el bien del pueblo, este tiene derecho a rebelarse contra él y destronarlo²⁰. Mencio (372-289 a.C), discípulo de Confucio, sostuvo con firmeza que un gobierno tiene que actuar por la voluntad del pueblo. "El pueblo es de primera importancia. El Estado es de menor importancia. El soberano es el de mayor importancia".²¹

Durante el mandato del emperador Trajano (98-117) se encomendó al "Curator Civitatis" la protección de los niños y de las clases más humildes contra los poderosos, aunque éstos estuvieran investidos de autoridad. El emperador Valentiniano (364-375) se constituyó como el "Defensor Plebis" o "Defensor Civitatis" con el fin de simplificar la administración de justicia y acabar con los abusos de los poderosos²².

El estoicismo influyó enormemente en la vida pretérita, y fue Cicerón quien al aprehender la doctrina de la ley natural y la igualdad de los hombres con una visión filosófica, que a su vez sería aceptada por los apologetas cristianos con el fin de asentar las bases del cristianismo, concibió el derecho natural como aquel basado en la razón inherente en el hombre, idéntica a la razón divina que se aplica a todos los seres vivos; este pensamiento se entrelazó con el *jus civile* y el *jus Gentium*.

El pasaje comprendido en el Libro I, 29-30 de *Las leyes*, lo recalca de esta manera:

"No existe una sola cosa tan semejante ni tan igual a otra como lo somos todos nosotros comparados con nosotros mismos [...] en efecto, las mismas cosas son percibidas por los sentidos de todos los hombres, los estímulos de los sentidos son los mismos para todos, los gérmenes del conocimiento impresos en las almas, se imprimen de manera semejante en todas; y el interprete del pensamiento, el lenguaje, se diferencia por las palabras, pero es el mismo desde el punto de vista del significado. Y no hay nadie, sea de la raza que sea, que tomando como guía a la naturaleza no sea capaz de alcanzar la virtud".

La iglesia cristiana al apropiarse de estos aportes ocasionó una incisión infranqueable con el paganismo; aunque esto no se hubiese logrado sin la denodada actitud espiritual de personajes que son emblemáticos, no sólo del cristianismo sino de la historia misma. Conocidos con el nombre de Padres de la Iglesia, los cuales conforman la Patrística.²³

20 Op.cit. 280

21 Op.cit. 48

22 Pacheco Máximo: Los derechos fundamentales de la persona humana. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Estudios Básicos de Derechos Humanos N° 02. Costa Rica. 1995.

23 La patrística: es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana que abarca desde el fin del cristianismo primitivo, con la consolidación del canon neotestamentario,

Un ejemplo clásico en el mundo occidental respecto a la historicidad de los derechos humanos, que impretermiteblemente no puede soslayarse es la respuesta de Antígona al reproche de Creón por haber enterrado a su hermano en contra de su prohibición. Responde, esta de la manera más sublime en la conocida obra de Sófocles:

Porque esas leyes no las promulgó Zeus. Tampoco la justicia que tiene su trono entre los dioses del Averno. No, ellos no han impuesto leyes tales a los hombres. No podía yo pensar que tus normas fueran de tal calidad que yo por ellas dejara de cumplir otras leyes, aunque no escritas, fijas siempre, inmutables, divinas. No son leyes de hoy, no son leyes de ayer... son leyes eternas y nadie sabe cuándo comenzaron a vigir. ¿Iba yo a pisotear esas leyes venerables, impuestas por los dioses, ante la antojadiza voluntad de un hombre, fuera el que fuera? "(...) Morir, morir ahora no me será tormento. Tormento hubiera sido dejar el cuerpo de mi hermano, un hijo de mi misma madre, allí tendido al aire, sin sepulcro.²⁴

2.3.2.- EDAD MEDIA

Hasta la Edad Media no se encuentra realmente antecedentes precisos y claros fundamentados en relación a los derechos humanos, sin embargo la doctrina prácticamente ha adoptado una serie de derechos recogidos o expuestos en diversas referencias, las cuales tienen como características comunes desde la perspectiva de la historia de los derechos humanos, las siguientes:

- Se producen como consecuencia del paso del régimen feudal al régimen estamental.
- Constituyen una garantía y un límite frente al poder real de unos derechos reconocidos.
- Se constituyen como punto de partida para el reconocimiento posterior de nuevos derechos y nuevas reivindicaciones extendidas a sectores cada vez más amplios de la población.
- Son un fenómeno común al territorio europeo, que a ulterior de expandió a América.
- Presuponen los antecedentes modernos del constitucionalismo, cimentados a su vez en el inicio del principio de legalidad como garantía de los derechos reconocidos.
- Son derechos pactados entre el soberano, los barones y hombres libres,

hasta alrededor del siglo VIII. Además de la elucidación progresiva del dogma cristiano, la patrística se ocupó

sobre todo de la apología o defensa del cristianismo frente a las religiones paganas primero y las sucesivas interpretaciones heterodoxas que darían lugar a las herejías luego. Su nombre deriva de los Padres de la Iglesia, los teólogos y filósofos cuya interpretación dominaría la historia del dogma.

24 Sófocles: Las siete tragedias. Editorial Porrúa. México. 2007. p.260

los súbditos quedan aún privados de toda defensa jurídica contra los gobernantes .

- Son concesiones que los nobles logran del poder real, como consecuencia de la lucha el rey y la nobleza.

Aunque se trata del reconocimiento formal y escrito de derechos preexistentes de carácter consuetudinario, se pretendía garantizarlos con miras al futuro, mediante su formulación y reconocimiento solemne por parte del rey. Se va originando un reconocimiento paulatino de los derechos colectivos, en la medida en que se empieza a reconocer la libertad de entidades sociales sobre las cuales el gobernante reconocía no tener poder.

Así en la Carta Magna inglesa del 15 de junio de 1215 se proclama la libertad de la Iglesia de Inglaterra (cláusula 1), de la ciudad de Londres y de otras ciudades y Villas (cláusula 13); igualmente emergen someramente unas pocas garantías de los derechos, como la prohibición de arrestos arbitrarios (...) ningún hombre libre podía ser arrestado, expulsado, o privado de sus propiedades, sino mediante juicio de sus pares y por la ley de la tierra.²⁵

Fue así como se otorgó al hombre libre la garantía de legalidad, de audiencia y de legitimidad ante los cuerpos judiciales; aunque sólo fue a una casta (los barones).

La cláusula 60 de la Carta Magna de 1215 lo menciona explícitamente (...) en apaciguamiento de la querella que ha surgido entre Nos y nuestros barones, hemos otorgados estas concesiones (...).²⁶

Sin embargo, El modelo²⁷ Iglesia- Institución perduró durante casi quince siglos, el gran poder político y económico alcanzado al ser legitimada como ofrenda de su triunfo por el Emperador Constantino; quien de acuerdo a lo expuesto por Herling (1996); en su obra Historia de la Iglesia, cuando se “Aprestaba para la lucha decisiva contra Majencio, estaba convencido de haber tenido una visión o una revelación”, supuestamente vio una cruz y oyó una voz que le dijo: «Por esta cruz vencerás» (p.173) así, “La tolerancia y el reconocimiento fueron preparados por un edicto del emperador Galerio, antes de su muerte en el 311”; este edicto es atribuido a Constantino por su ejecútese, pero ya el camino estaba allanado y lo proclama junto con Licinio, corregente oriental; este edicto concedía libertad religiosa ilimitada.

La iglesia pasó de ser una Iglesia de Catacumbas, perseguida, martirizada, a ser una iglesia protegida. Fue convirtiendo a todas las regiones del imperio; progresivamente, transformando sus organizaciones en una estructura

25 <http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2698/17>.

26 Ib.Ib

27 Andrés Argibay, (SDB), en su ensayo *Eclesiología del Vaticano II y la Opción eclesiológica Latinoamericana* en Medellín, Puebla y Santo Domingo lo define señala que “Es el modo en que la realidad de la Iglesia, en un determinado momento histórico cultural, es pensada, sentida, percibida, vivida y expresada por sus miembros. ¿Cuál es el objetivo del modelo eclesiológico?; Pretende abarcar toda la realidad eclesial en unidad y coherencia, a la vez que la describe desde un determinado punto de vista. En este sentido el modelo eclesiológico puede ser definido como un modo, global y selectiva, de acceso de lo que es la Iglesia. (p.3) 7 Op.cit 191

consumada de considerable importancia política y administrativa. Los emperadores, tanto por sus ideas cristianas como por prudencia política, aprobaron y favorecieron este modo de vida, por un lado apartándose del paganismo y restándole su apoyo moral y material y por otro prestándole cada vez más apoyo al cristianismo. La iglesia Cristiana se proclamó como religión del Imperio Romano.

Esta evolución, fue acompañada de una creciente represión legal contra el paganismo, el punto culminante del Cesaropapismo lo completó Justiniano, el emperador del derecho quien declara a los no bautizados fuera de la ley y a los herejes inhábiles para desempeñar cualquier cargo. Con ello está ya básicamente expresada la concepción medieval de que sólo el cristiano es un ser completo, y que todo ataque a la fe o a la Iglesia significa asimismo un ataque al Estado. Esta idea se fue poco a poco condensando en la extensa legislación contra los herejes (*Codex Theodosianus*, 428).

También, la unción de Pipino (el Breve) contribuyó a fortalecer la imagen de la Iglesia – institución; convirtiéndose en una instancia terrena que promulgaba derechos considerados divinos; la legitimación de emperadores y reyes se afianzó cuando León III ungió a Carlomagno; quien siguió la tradición de su padre al ser proclamado rey en nombre del Papa San Bonifacio; desde entonces las relaciones entre la Iglesia y los Emperadores se convirtió en una especie de alianza, Carlomagno se convirtió en el defensor de la Iglesia, entrometiéndose libremente en los asuntos eclesiásticos, esto contribuyó a la expansión del Sacro Imperio Romano.²⁸

Tras la muerte de Carlomagno, la influencia de la Iglesia en los asuntos de la nobleza no decayó; para gozar de legitimidad política se requería la aquiescencia de la Santa Sede. La Iglesia era considerada como “Sociedad Perfecta”, apuntalada con la triste celebre Bula “Unam Sanctam”, proclamada por Bonifacio VIII, quien defendió la soberanía suprema y universal de la Santa Sede, explicando la antigua doctrina de “las dos espadas” (Inocencio III y Gelasio I). “La espada espiritual debe estar en manos de la Iglesia, y la temporal debe manejarse en servicio de la Iglesia” la bula culmina con la frase: “Declaramos y definimos que a todo hombre es necesario para la salvación estar sometido (*subesse*) al papa”²⁹

Aún, en la Edad Media no se habían originados los Estados, tal como se conocen hoy día, existían feudos, principados; sucedieron innumerables pugnas bélicas por un trozo de tierra, la iglesia se convirtió en protectora de la realeza, pero a su vez se apoyaba en esta; concedía privilegios o excomulgaba a quien se rebelara. Imperaba el sacro Imperio Romano. “Este paradigma medieval alcanzó luego en los siglos XII-XIII su punto culminante y finalmente su punto de inflexión, de forma que ya en los siglos XIV –XV se encontraba en plena crisis concretándose a comienzos del siglo XVII con la Reforma de Martín Lutero”.³⁰ La pugna por unos derechos inherentes al hombre se enmarcaron en la libertad de conciencia y de religión, aunque la

28 Op.cit. 219-262

29 (Ib, Ib).

30 Op.cit. 296

opresión social y política era evidente, lo religioso dominaba el espectro. Aún, los visos de protección de los derechos humanos no se vislumbraban.

En este contexto las variables que caracterizaron el modelo Iglesia-Institución contribuyeron a esta concepción por lo que al respecto se precisa analizarlas debido a su repercusión en lo social, cultural, político, económico e ideológico.

2.3.2.1- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MODELO IGLESIA-INSTITUCIÓN

1.- Se resaltaban los aspectos visibles, sociales, institucionales y organizativos, existía una autocomprensión en el que predominaba lo jurídico, la dimensión de la Iglesia como *misterio* se mitiga; no ejerce gran influencia este aspecto.

2.- Se concebía a la Iglesia como la sucesora de Cristo en la tierra; en el orden espiritual, moral, se marca una estrecha relación con el poder-autoridad; la Iglesia tiene la potestad de enseñar, santificar y regir; la Iglesia profética, crítica, denunciante, queda soslayada ante la realidad circundante. Era tal el poder ejercido sobre todo por los papas (Unos más que otros) que eminentes teólogos medievales como Marsilio de Padua, quien en su obra *Defensor Pacis*, criticaba el poder absoluto ejercido por los papas y Guillermo de Ockham; a quien se le atribuye junto con Marsilio ser adversarios de la supremacía (*plenitudo potestatis*) pontificia. A ellos, suele atribuírseles la primera derivación de la legitimidad gubernamental del consenso con base en el derecho natural; en este orden siguen Juan de Salisbury, entre otros, quienes se enfrentaron y sentaron las bases para limitar las potestades del poder.

3.- La Iglesia es considerada como el único lugar de refugio donde se podía lograr la salvación; predomina lo espiritual ante lo material, lo individual frente a lo comunitario, lo ultraterreno ante lo terreno.

4.- Existe coincidencia entre la relación de la iglesia y el Reino, es una percepción reductiva de la salvación (fuera de la iglesia no hay salvación), es una actitud triunfalista; la Iglesia se considera la única portadora de la salvación de las almas, consecuentemente el ecumenismo, diálogo con otras religiones es prácticamente nulo, todo aquel que formulara alguna hipótesis doctrinaria que no contara con su aprobación era considerado hereje.

5.- Se refuerza una estructura piramidal de la jerarquía eclesiástica, existía un esquema lineal en la comprensión de los ministerios (Cristo — Apóstoles — Iglesia); se divide a la Iglesia entre, clero y laicado, clase dominante y clase dirigida; autoridad y súbditos; la clave es la *obediencia*; la Iglesia se reduce a sus ministros en detrimento de los laicos; se realza la individualidad y no la comunidad.

6.- Se observa un integrismo eclesiológico, se subestima el valor de otras confesiones fuera de la Iglesia Católica. Prevalece la polémica.

7.- Se visualiza al mundo como una sociedad paralela a la Iglesia (dualismo), como amenaza, origina posiciones de condena, el mundo es pecaminoso. En consecuencia, no existe sintonía entre las autoridades eclesiásticas que gozaban y resguardaban sus privilegios y los problemas de los más desvalidos.

8.- La Iglesia se orienta bajo una posición apologética; la Iglesia fundada por

Cristo es la católica-romana; es la que tiene una cabeza visible dotada de una jurisdicción universal impregnada por la infalibilidad papal; prevaleciendo este modelo durante casi quince siglos.

Resaltando Argibay (2008) la Encíclica “Vehementer nos” de 1906 en la cual Pío X, la refleja aún pasados los años esta perspectiva:

La Iglesia es el Cuerpo místico de Cristo, regido por pastores y doctores: sociedad por consiguiente, humana, en cuyo seno existen jefes con pleno y perfecto poder para gobernar, enseñar y juzgar. De lo que resulta que esta sociedad es esencialmente una sociedad desigual, una sociedad compuesta de distintas categorías de personas: los pastores y el rebaño, los que tienen un puesto en los diferentes grados de la jerarquía y la muchedumbre de los fieles. Y las categorías son de tal modo distintas unas de otras, que sólo en la pastoral residen la autoridad y el derecho necesarios para mover y dirigir a los miembros hacia el fin de la sociedad, mientras que la multitud no tiene otro deber sino el dejarse conducir y, como dócil rebaño, seguir a sus pastores. (p.12)

A pesar, del ejercicio desmedido del poder que originó el estado absolutista defendido por Hobbes y Bossuet, el cristianismo medieval a pesar sus postulados doctrinarios comenzó a dar muestras de la solidaridad, protección que de suyo se encuentra en los derechos humanos, a través de las *caritas opus* «obras de caridad».

Como su tarea especial tenía, la preocupación por los que sufren y por los pobres. (...) Y en la Edad Media el cuidado de los enfermos se desarrolla por doquier a través de los monasterios, en especial desde la reforma cluniacense, pero también a través de las órdenes hospitalarias de caballería y civiles (...)

Tampoco hay que olvidar la preocupación por la paz en un tiempo sin ella: usos arcaicos muy extendido en la temprana Edad Media, tales como la venganza de sangre y el tomarse la justicia por su mano (a veces durante años), consecuencia de un derecho germánico de imponer su justicia sin recurrir a las autoridades, fueron combatidos en la alta Edad Media por un movimiento cristiano a favor de la paz, primero en el sur de Francia, y finalmente restringidos de forma notable por doquier en Europa, por Obispos que proclamaban la *tregua Dei*, la «paz de Dios»: para todos los tiempos «*tiempos sagrados*», para el tiempo de Adviento y de Navidad, de Cuaresma y de Pascua y para los días de la semana de viernes a domingo. Una «paz de Dios» del obispo que luego el rey convirtió en la «paz del país». La brutalidad desaparecía, las costumbres se refinaban, los caballeros bandidos de otros tiempos se convirtieron en [...] trovadores. Desaparece ahora de forma creciente el desprecio del mundo y el arte gira hacia el realismo.³¹

No sólo en el arte se advertía el advenimiento de una nueva época, sino en todos el ámbito; cultural, social, político.(...) que más tarde la Ilustración generalizará con el término histórico-artístico de la *Renaissance* como un

31 Op.cit. 447

concepto histórico para los siglos XV y XVI que se considerará como un preludio de la Era «moderna»: ya aquí se reconoce el individuo en el espejo de la Antigüedad su propio valor como personalidad histórica y tiene lugar el descubrimiento del hombre natural y del ciudadano libre *Renaissance* y humanismo se convierten ahora en conceptos paralelos, análogos.

Se iniciaba una nueva época, según Etienne Gilson (2009). “Por no haber sabido mantener la unidad orgánica de una filosofía verdaderamente racional y verdaderamente cristiana, la escolástica y la cristiandad se hundieron simultáneamente bajo su propio peso.” (p.368). Se abrió paso un nuevo paradigma, como protesta contra la imagen cíclica, ligada a la Antigüedad.

2.3.3.- EDAD MODERNA

Siguiendo a Peces Barba. “Cuando la mentalidad del mundo moderno y la reflexión sobre la organización del poder, frente al Estado absoluto — que producirá el primer constitucionalismo — alcance éxito social, estaremos en los albores del estado liberal y en los primeros modelos cristalizados en la historia de los derechos fundamentales, es decir una moralidad recibida por el Derecho positivo.

Desde el siglo XVII se podrá hablar de modelo inglés y desde el siglo XVIII de modelos americano y francés”. (p.146). De acuerdo a lo anterior es en la Edad Moderna donde comienza la historia de los derechos humanos. Así, lo señalan las corrientes historiográficas; historiadores y filósofos del derecho que propugnaban acerca de los derechos humanos proponen la existencia de tres modelos históricos de aparición de derechos humanos, que tendrían lugar a partir del siglo XVII. Las principales declaraciones de esta época se pueden clasificar en tres grandes bloques, que comprenden a los tres grandes modelos reconocidos en la tradición de los derechos humanos, configurándose a su vez en tres líneas de evolución alusiva a estos derechos; son estas las declaraciones inglesas, las declaraciones angloamericanas y las declaraciones francesas. Teniendo como inspiración lograr la limitación del poder absoluto del soberano, monarca.

Conteste con la idea expuesta del autor anterior, Truyol y Serra se expresa también al respecto: “En la Europa de los siglos XVII y XVIII, el tema de la tolerancia y la libertad religiosa y de conciencia siguió en un primer plano de las controversias, desde una perspectiva más filosófica que teológica y en el marco ya de los derechos civiles y políticos en general. Es patente en esta fase la influencia del nuevo espíritu crítico de la Ilustración, del deísmo. Son representativos de la misma en el plano doctrinal Locke, Bayle, Thomasius y Wolf, los enciclopedistas franceses, Voltaire [...] La reivindicación de éstos se desarrolla, en efecto con la ascensión de la burguesía, que reclama la supresión de los privilegios de la nobleza y la igualdad ante la ley”. (p.27). Igualmente, ambos autores entre otros, también coinciden en estimar la influencia vanguardista de Inglaterra en la propagación del constitucionalismo fundamentado en la filosofía jurídica ius naturalista-racionalista de Jhon Locke. (...) en el siglo XVIII lo único que se ansía en Alemania es «un buen monarca» según el espíritu del absolutismo ilustrado que, en virtud de su responsabilidad patriarcal y de su inteligencia garantice el bien del Estado

y de los ciudadanos [...] En cambio en Francia se exige ya una constitución, una monarquía constitucional y al mismo tiempo, según el modelo inglés, una separación de los poderes como requisito previo de la libertad política”³².

Sin embargo cada modelo tendrá sus características peculiares; las declaraciones inglesas se distinguen por irrumpir en la concepción de los derechos fundamentales, emprendiendo un camino evolutivo; (...) pero ¿Por qué? Se dio en Inglaterra este gran salto (...) todas las autoridades entran en crisis tradicionales sea — Aristóteles, la Escolástica, el papa, o la Biblia — entran en crisis de su legitimación. ¿Qué es razonable, que es útil? Sólo lo que es razonable es tenido en el futuro como verdadero, útil y vinculante...

Pero lo razonable — y de esto tienen una idea muy clara sobre todo en Inglaterra — no es otra cosa que lo natural, la naturaleza del hombre.

No, no es sobre lo devenido históricamente, lo tradicional, lo causal, sobre lo que hay que construir el derecho y la constitución, la economía y la cultura, la moral y la religión, sino sobre *la naturaleza humana común a todos*, que por supuesto, permitiría también reformar las condiciones en determinadas circunstancias. En vez de en lo oral, especial, local, condicionado por el tiempo, se ponía ahora el acento en lo escrito, general, global, atemporal. En vez de en la ley y mandamiento de Dios, el interés se concentra ahora en un derecho natural autónomo. (...) comienza la élite intelectual a pensar mirando hacia adelante, segura de sí misma, independiente de la autoridad y abierta, contra el Renacimiento, en un progresismo característico de la modernidad que se basa no ya en la Antigüedad (Re-nacimiento) o en la Biblia (Re-forma) sino en la razón autárquica del hombre (...). Sólo ahora se llega a la nueva acuñación lingüística «progreso», que emerge al mismo tiempo que el término «la historia » (...). En lugar de un orden mundial eterno, ordenado de forma jerárquica, inmutablemente estático (*ordo* en el mundo platónico-agustiniano-tomista), en vez de la reformada doctrina de los dos reinos, en el reino de Dios y el reino del mundo, vige ahora una nueva concepción unitaria del mundo y de la historia en el sentido de un progreso duradero: principio de acción moderno.

Este debe traer ya en esta vida a la humanidad una mejora de su situación, un dominio de la naturaleza, y al individuo bienestar y felicidad. Los filósofos de la historia de la modernidad — Hegel, Marx y Comte — configuran bajo la idea directriz del progreso una nueva visión del mundo³³.

Las declaraciones americanas estarán impregnadas de una perceptible *devotio* religiosa³⁴ esto es evidente por el origen religioso de los padres

32 Op.cit. 681

33 Op.cit. p.682-685

34 <http://www.allabouthistory.org/spanish/pacto-del-mayflower.htm> Edmund Burke (1729-1794), destacado orador, autor, y líder de Gran Bretaña, defendió las colonias en el Parlamento. "Hay sólo una ley para todos, a saber, es la ley que gobierna toda ley, la ley

fundadores emigrantes; desplazados, expatriados, ingleses protestantes que huían del acoso religioso de la metrópoli a bordo del Mayflower; las ideas vanguardistas de prosperidad, riqueza; de la fe no sólo en Dios sino también en el hombre comenzarán a germinar, no sólo para los hombres de esa época sino para los venideros; dejándolo saber explícitamente en su preámbulo: *"Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América"*³⁵.

Los postulados de las declaraciones francesas se desprenden de todo vestigio religioso diferenciándose del sistema americano; los revolucionarios franceses estaban imbuidos por los proponentes de la Ilustración quienes asumieron como estandarte lo racional y útil para todo hombre, no sólo para una élite. Si bien como se observará a continuación en las variables características de los diferentes modelos, aún no había referencia a los derechos transgeneracionales en específico de una u otra forma se puede afirmar que el germen de su proliferación estaba fecundándose, paulatinamente hasta que las condiciones históricas se articularan y confluyeran en su nacimiento.

Estos modelos son ineludibles por la relevancia histórica que alcanzaron, siendo el primero y precursor de ellos el inglés.

2.3.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES MODELOS PRECURSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

2.3.4.1.- CARACTERÍSTICAS DEL MODELO INGLÉS

- Se trata de auténticas normas jurídico positivas y no meras declaraciones de derechos en sentido estricto.
- Se trata de normas de derecho constitucional consuetudinario, que se convirtieron en referente de interpretación y de aplicación de cualquier otra norma.
- Se trata de textos legales que receptan derechos que proceden del derecho consuetudinario inglés, remontándose su origen a textos medievales (como la Carta Magna de 1215).
- Se reconocen derechos que en un principio (Edad Media) amparaban

de nuestro Creador." Patrick Henry (1736-1799), gobernador de Virginia por cinco veces, cuyo discurso de "Dadme libertad o dadme muerte" que lo inmortalizó, dijo: "No puede enfatizarse lo suficiente, ni demasiado, que esta gran nación fue fundada no por religiosos, sino por cristianos; no sobre religiones, sino sobre el evangelio de Jesucristo..." Thomas Jefferson (1743-1826), tercer Presidente de los Estados Unidos, elegido para redactar la Declaración de la Independencia, dijo: "No me cabe duda de que todo el país pronto se reunirá en la unidad de nuestro Creador, y, espero que también en las doctrinas puras de Jesús." Él proclamó en su discurso inaugural de 1805 que fue el Dios de la Biblia el que fundó América: "Voy a necesitar, también, el favor de ese Ser en cuyas manos estamos, quien guió a nuestros antepasados, como al Israel antiguo, desde su tierra natal y los plantó en este país."

35 <http://www.lexjuris.com/lexuscon.htm>

a determinados sectores de la nobleza, se extiende a un mayor número de súbditos.

- Representan el triunfo del Parlamento sobre la Corona, en adelante los demás poderes, incluido el poder regio deberá someterse a a ley sancionada por el Parlamento.
- Reconocen una gama de garantías, entre las cuáles resaltan la garantía del *Habeas Corpus*.
- La independencia del poder judicial se reconoce en procura de la protección de los derechos fundamentales.

2.3.4.1.1- PRINCIPALES DECLARACIONES INGLESAS:

- La **Petition of Rights**, de 1628, protege los derechos personales y patrimoniales.
- El **Habeas Corpus Act**, de 1679, que tiene una significación trascendental, por cuanto establecía que la detención de una persona no podía ser realizada sin un previo mandamiento judicial y obligaba a someter a la persona detenida al juez ordinario dentro del plazo de veinte días.
- La **Declaration of Rights**, de 1689, que confirmaba los derechos ya consagrados en los textos anteriores.

2.3.4.2.- CARACTERÍSTICAS DEL MODELO AMERICANO

- Resulta evidente la influencia de las declaraciones inglesas, el iusnaturalismo racionalista con un claro matiz progresista, signará los textos declarativos de derechos humanos, como hombres libres dispuestos a fundar una nación propia.
- La invocación a lo sagrado será el sello distintivo en cada pacto; los pioneros ingleses (puritanos y cuáqueros), tenían en común ser perseguidos por sus creencias religiosas cristianas. Desde el Mayflower se visualizan las líneas a seguir en los futuros pactos³⁶ que originaron la unión de las incipientes colonias. Jellinek (2009) muestra la importancia y teleología de la costumbre pactista americana, señalando: “Conocido es el pacto que los padres peregrinos congregacionistas, perseguidos y desterrados, celebraron el 02 de noviembre de 1620, antes de fundar a Nueva Plymouth, a bordo de la nave *Flor de Mayo*. Cuarenta y una personas suscribieron entonces un Acta, en la cual declaraban, para gloria de Dios y la para extensión de la fe cristiana, y en honor del Rey y de la Patria, fundar una colonia- Prometían allí asociarse en un cuerpo político y civil todo con el objeto de mantener el orden y alcanzar el fin perseguido” (p.80).

36 Al crear el Pacto del Mayflower, los firmantes creían que los pactos no solamente debían ser honrados entre Dios y el hombre, sino también entre ellos mismos. Ellos siempre habían respetado pactos como parte de su integridad y con el Pacto acordaron atenerse a este mismo principio. John Adams y muchos historiadores se han referido al Pacto del Mayflower como el fundamento de la Constitución de los Estados Unidos, escrita más de 150 años más tarde. (Op.cit. Ib).

- La filosofía jurídica de Locke, fundadora de la doctrina liberal fue recogida en los textos de Derecho positivo; la libertad religiosa en un principio fue la bandera a izar, en «búsqueda de la felicidad» el iusnaturalismo fue útil en la mezcla del racionalismo y pragmatismo.
- La separación de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones, encuentra en Norteamérica sus más fieros defensores quienes transfieren esta doctrina a la Francia revolucionaria, quedando establecido para la posteridad el lacónico pero contundente artículo 16 de la Declaración Francesa. “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la separación de poderes, no tiene constitución.”³⁷ Queda asentado el espíritu constitucional de esta forma. En la magnánima obra de: Jay, Hamilton y Madison “*El Federalista*”, más que ninguna otra, se visualizan los ideales de los padres fundadores; al exponer la separación de los poderes, como uno de los fundamentos de la democracia representativa, la describen así: “La distribución ordenada del poder en distintos departamentos; la introducción de frenos y contrapesos legislativos; la institución de tribunales integrados por jueces que conservaran su cargo mientras observen buena conducta; la representación del pueblo en la legislatura por medio de diputados de su elección.”³⁸

La inmanencia de la Constitución como norma suprema se ha convertido en un legado del constitucionalismo Norteamericano, harto afamado es el fallo de 1803 del Juez John Marshall, al decidir la controversia *Marbury vs Madison*, dice: “El fundamento sobre el que se ha construido el sistema americano es el derecho originario del pueblo a establecer, para su gobierno futuro, aquellos principios que considere más adecuados para obtener la felicidad...¿Qué sentido tiene que los poderes estén limitados y que los límites estén escritos, si aquellos a los que se pretende limitarse pudiesen saltarse tales límites?”³⁹ Prevaleciendo un alto sentido de los principios y valores constitucionales, originando una forma de gobierno; (...) bajo el influjo de América, se han erigido, en reglas de derecho, los principios de libertad, y lo han hecho para toda Europa. Sin América, sin las Constituciones de sus diferentes Estados, quizá tendríamos una filosofía de la libertad, jamás una legislación de la libertad⁴⁰; lo que efectivamente sucedió primero en el continente europeo y posteriormente en las Colonias Españolas en América que luchaban por su independencia.

2.2.5.2.1.- PRINCIPALES DECLARACIONES AMERICANAS

- **Declaración del Buen Pueblo de Virginia, de 1776**, es la declaración más importante por su influencia ulterior, en su momento era la Colonia más grande y la precursora en las innovaciones constitucionales. Fue

37 Jellinek, 125

38 El Federalista, LXIII, p. 269

39 Beltrán de Felipe, Miguel y González, Julio: Las Sentencias Básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Madrid. Boletín del Estado. 2006. p. 96

40 Op. cit. p. 108

redactada por el agricultor y abogado George Mason y sirvió de modelo para la Declaración de Derechos de otros Estados; de la posterior Declaración de Derechos Federal de 1791 y de la Declaración adoptada por la Francia revolucionaria de 1789; la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano.

- **La Constitución Americana, escrita en Filadelfia en 1787**, en sus siete concisos artículos establece una serie de garantías, como la garantía para la libertad personal apoyado por el hábeas corpus, la seguridad de ser juzgado mediante un juicio con jurado y la prohibición de los mandamientos de confiscación y leyes ex post facto.
- **La Declaración de Derechos aprobada en 1791**, fue producto de la Declaración de Derechos Federal formulada por James Madison durante el proceso de ratificación de los Estados de la Constitución Americana.

2.3.5.3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS DECLARACIONES FRANCESAS

Su origen histórico es muy discutido; sin embargo pueden exponerse tres posturas básicas.

- La doctrina de Jellinek, para quien la Declaración francesa emuló las declaraciones norteamericanas que a su vez surgieron ideológicamente de las concepciones puritanas mayormente inspiradas por inmigrantes protestantes.
- La doctrina francesa, a partir de las tesis de Boutmy polemizando con Jellinek, que desecha tanto la paternidad americana como germánica, insistiendo en su derivación por el influjo de la literatura europea, y especialmente del pensamiento ilustrado francés del siglo XVIII.
- La doctrina ecléctica, consistente en afirmar que son compatibles tanto el criterio de Jellinek como la tesis opositorista de Boutmy.

De acuerdo a Xifra Heras (1957). "Hoy día se está de acuerdo en admitir que las fuentes de la primera Declaración francesa fueron múltiples, y que entre ellas figuran indiscutiblemente las declaraciones americanas, la doctrina de los filósofos franceses (Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Condorcet), las teorías iusnaturalistas y las corrientes religiosas tradicionales". (p.345)

Con esta precisión queda prácticamente saldada la disputa que en el fondo no condujo a ningún aporte relevante; ambos desde sus posiciones tenían argumentos a favor que sustentaran sus pensamientos

2.2.5.3.1.- PRINCIPALES DECLARACIONES FRANCESAS

- La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

En su obra supra citada Jellinek argumenta contundentemente, realizando una apología encomiable en cuanto al valor trascendental de esta declaración, estima que: "La influencia de la Revolución americana en la francesa es notoria; ambos sucesos son ciertamente, momentos de una misma evolución política" (p.8), defendiendo sus principios contra los detractores del momento, de esta manera:

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Constituyente francesa del 26 de agosto de 1789 es uno de los acontecimientos más importantes de la Revolución francesa. Ha suscitado, desde diversos puntos de vista, las críticas más encontradas. Los políticos y los historiadores la han discutido a fondo, y a menudo han llegado a la conclusión de que no poco es producir la anarquía en que ha caído Francia después de la toma de la Bastilla. Se han dedicado a demostrar que sus fórmulas abstractas eran ambiguas, y por tanto peligrosas, no respondiendo a la realidad política e implicando desconocimiento de la práctica de las cosas del Estado. Su pathos vacío habría confundido los espíritus, turbado la serenidad del juicio, inflamado las pasiones, apagando el sentimiento del deber — del deber no se trata siquiera —. Otros, por el contrario, principalmente franceses, lo han celebrado como una revelación de alcance histórico universal, como el catecismo de los «Principios de 1789», que constituyen el fundamento eterno del orden político; como el presente más precioso hecho por Francia a la humanidad. (p.41).

La Declaración francesa se convirtió con sus principios de un claro contenido racionalista y laico en la piedra angular del moderno constitucionalismo, su riqueza filosófica-jurídica trasciende; pretende suprimir el anquilosado régimen estamental absolutista por un gobierno donde participe el ciudadano; (...). “El poder absoluto arbitrario o el gobernar sin leyes fijas y establecidas, no pueden ser compatibles con los fines de la sociedad y del gobierno (...) es impensable aún si tuviesen poder para hacerlo, poner en manos de una persona, o de varias, un poder absoluto arbitrario sobre sus personas y bienes. Sería tanto como ponerse en una situación peor que la del estado de naturaleza, en la cual no tenían libertad de defender su derecho contra los atropellos de los demás”.⁴¹

Pensamientos como estos de John Locke, opositor acérrimo del absolutismo contribuyeron a formar una Pléyades de hombres valerosos e infundidos de espíritu libertario dispuestos sentar unos cimientos políticos y sociales diferentes que invistiera de legitimidad a la nación; sin duda otro paladín es Montesquieu quien en: “El famoso libro XI del Espíritu de las Leyes, en el que atribuía la libertad que gozaba Inglaterra en la separación de los poderes en: legislativo, ejecutivo y judicial y a la existencia de frenos y contrapesos entre esos poderes estableció esas doctrinas como dogmas del constitucionalismo liberal. La amplitud de la influencia ejercida por Montesquieu en este aspecto es indiscutible y puede verse en las declaraciones de derechos de las constituciones norteamericanas y francesas”.⁴² Además, de estos Peces – Barba,⁴³ también considera la influencia plural y compleja de ideístas imbuidos del iusnaturalismo racionalista entre los que se encuentran: Pufendorf, Tomasio, Barbeyrac, Burlamaqui, Wolff, Bayle Fontenelle, Voltaire, Diderot, los fisiócratas, la Enciclopedia y hasta Rousseau; coincidiendo con Xifra Heras

41 John Locke, Segundo Tratado del Gobierno Civil. (Buenos Aires).Ediciones Grijalbo, S.A. 1975. p.98

42 Sabine (2006), 427

43 Op. cit. 151

supra citado. Obviando Truyol y Peces-Barbas al abate Sieyes; quien más tarde que Locke clama categóricamente por una Constitución y hace un llamado al pueblo llano; plasmándolo de esta manera en su opúsculo *El Estado Llano* o mejor conocido como el Tercer Estado. “Si no tenemos una Constitución es preciso hacerla; la nación tiene derecho a ella”. Sin embargo, también patrocina la necesidad de un pacto entre las individualidades para formar un gobierno (...) las voluntades individuales siguen siendo el origen y forman los elementos esenciales; pero, consideradas separadamente, su poder sería nulo, puesto que sólo reside en el conjunto⁴⁴. Tal es el origen de un gobierno, ejercido por procuración; coincide con Locke, en legar una porción de poder «a algunos de ellos» el pueblo es numeroso y es imposible consultarlo en su totalidad por toda la nación; esta delegación no implica un desprendimiento total del poder soberano.

Expone su celebre tesis acerca del poder constituyente originario de esta manera:

1.- la comunidad no se despoja, en este caso, del derecho a imponer su voluntad, que es su propiedad inalienable, y únicamente comisiona para su ejercicio.

2.- El cuerpo de delegados no puede ni siquiera tener la plenitud de este ejercicio, puesto que la comunidad no ha podido confiarle, de su poder total, más que aquella porción necesaria para mantener el buen orden. No se concede nada de superfluo a este respecto.

3.- No entra, por tanto, en las atribuciones del cuerpo de delegados traspasar los límites del poder que les ha sido confiado, y se concibe que esta facultad sería contradictoria consigo misma”.⁴⁵

Esta noción se transmitió e insertó en el constitucionalismo convirtiéndose en un concepto clásico, «*el poder constituyente es intrínseco al pueblo mismo, sólo a él pertenece*». Se convierte en un sujeto político. De allí, que el abate contribuye al asentamiento de la democracia como forma de gobierno, por cuanto ésta se vincula a la idea de nación en sentido moderno, se cohesionan pluralidades con sentido de pertenencia a una determinada comunidad que serán los nacionales, originándose derechos propios de la democracia como son los derechos políticos constitucionalizados.

- **Las Declaraciones de 1791 y 1793;** son importantes en la medida en que en ellas empiezan a destellar el reconocimiento de derechos que hoy se denominan económicos, sociales y culturales.

No obstante la doctrina dominante, se considera que se puede proponer un cuarto modelo histórico de aparición de los derechos humanos, que corresponde a la legislación indiana de los siglos XVI y XVII, en el que destacan las llamadas Leyes nuevas de las Indias, de 1542, y de un modo matizado las Ordenanzas del descubrimiento de 1573

Los desmanes ocasionados por los conquistadores-colonizadores valieron para que los Maestros de Salamanca como: Francisco de Vittoria, Francisco

44 Sieyes Emmanuel: ¿Qué es el Estado Llano?. Madrid. Instituto de Estudios Políticos.1950. p.141

45 Op. cit. p. 144

Suárez, Domingo de Soto, se pronunciaron contra estas malaventuras proferidas a los grupos indígenas de los territorios tomados; aportando ideas a favor del llamado *ius eonvi*, cimiento del derecho internacional que se desarrollaría con el discurrir de la historia.

Lo cierto es, que el reconocimiento universal de los derechos humanos como inherentes a la persona es un fenómeno más bien reciente. Sin embargo, el pensamiento de reconocer la dignidad del ser humano, considerado como una creación a la imagen y semejanza de Dios, y de la igualdad entre todos los hombres, derivada de la unidad de filiación del mismo Padre, también como ha quedado expuesto tuvo su influencia durante la colonización de las tierras americanas, los comerciantes y soldados conquistadores no tenían clemencia y atrocemente con el fin de apropiarse de todo aquello que pudieran arremetían contra los indígenas nativos. Los Papas no tardaron en reaccionar y el 2 de junio de 1537, la bula *Sublimis Deus* de Pablo III denunciaba a los que sostenían que “los habitantes de las Indias occidentales y de los continentes australes... debían ser tratados como animales irracionales y utilizados exclusivamente en provecho y servicio nuestro”; y el Papa afirmaba solemnemente: “Resueltos a reparar el mal cometido, decidimos y declaramos que estos indios, así como todos los pueblos que la cristiandad podrá encontrar en el futuro, no deben ser privados de su libertad y de sus bienes — sin que valgan objeciones en contra —, aunque no sean cristianos, y que, al contrario, deben ser dejados en pleno gozo de su libertad y de sus bienes”.

Las directivas de la Santa Sede eran así de claras, incluso Urbano VIII llegaría a excomulgar los que retuvieran a indios como esclavos.

El compromiso decidido en favor de los indios de un *Bartolomé de Las Casas*, soldado ordenado sacerdote, luego profeso dominico y obispo, seguido pronto por otros misioneros, conducía los gobiernos de España y Portugal al rechazo de la teoría de la inferioridad humana de los indios y a la imposición de una legislación protectora, de la cual se beneficiarán también, de algún modo, un siglo más tarde, los esclavos negros traídos de África.

El pensamiento preclaro para su época del Sacerdote Bartolomé de Las Casas valió de inspiración a la doctrina postrera de los derechos universales del hombre, fundados sobre la dignidad de la persona, independientemente de toda afiliación étnica o religiosa. Sin embargo, la estrecha dependencia en que el régimen del Patronato mantenía al clero del Nuevo Mundo no siempre permitió a la Iglesia tomar las decisiones pastorales necesarias.⁴⁶

Es de esa forma como el tema de los derechos humanos, más específicamente el de los derechos individuales y las libertades públicas, ingresó al Derecho Constitucional. Se trata, en verdad, de un capítulo fundamental puesto que el reconocimiento de la intangibilidad de tales derechos implica limitaciones al alcance de las competencias del poder público, en el Derecho Constitucional clásico; las manifestaciones originales de las garantías a los derechos humanos se centraron en lo que hoy se califica como derechos civiles y políticos.

46 <http://multimedios.org/docs/d000187/>. Documento. La Iglesia ante el racismo. Para

2.3.5.4.- LAS DECLARACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XIX

Durante el siglo XIX se producen una serie de declaraciones de derechos las cuales presentan los siguientes rasgos característicos:

- Están vinculadas al movimiento constitucional, clásico enmarcadas en el liberalismo.
- Continúan el iter trazado por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; pero con distinciones que las hacen diferenciarse en cierto modo: a) Se comienza a abandonar el marcado contenido filosófico abstracto, dando inicio a una protección más específica de ciertos derechos; el rumbo procesal hacia la constitucionalización se va delineando; b) Los Derechos Humanos ya no son referidos a todos los hombres *in abstracto*, sino a los ciudadanos de determinados países. Es el proceso de subjetivización; c) Se empiezan a especificar garantías de los derechos como los medios idóneos para su defensa. Es el proceso de positivización de las garantías; d) Los derechos reconocidos comienzan a ampliarse, en procura de otros derechos y hacia un estado de bienestar.
- En este proceso de expansión a partir de la mitad del siglo XIX, emergen los derechos económicos, sociales y culturales; en este interregnum se hace necesario destacar el valor de las luchas por las reivindicaciones obreras y otras pretensiones de carácter social.

León XIII en el año 1891 promulga la primera encíclica social de la Iglesia denominada "*Rerum novarum*", como un grito convincente por las precarias condiciones indignas en que se encontraban los obreros; siendo execrables la situación de miseria que debían soportar. La "*Rerum novarum*", enumera los errores que provoca el mal social y enumera las áreas en las cuales se abrirá la brecha de la doctrina social de la iglesia; señalando:

*(...) sobre el trabajo, sobre el derecho de propiedad, sobre el principio de colaboración contrapuesto a la lucha de clases como medio fundamental para el cambio social, sobre el derecho de los débiles, sobre la dignidad de los pobres y sobre las obligaciones de los ricos, sobre el perfeccionamiento de la justicia por la caridad, sobre el derecho a tener asociaciones profesionales".*⁴⁷

Las anteriores áreas serán tópicos esenciales sobre los cuales se desplegará con ahínco el compromiso de los patrocinadores modernos de los derechos humanos; de ellos se desglosarán otros; no sólo de forma individual o sino además para grupos vulnerables específicos, hasta llegar a los derechos transgeneracionales.

una sociedad más fraterna (Roma 3 de noviembre de 1988. Pontificia Comisión Iustitia et Pax.

47 Conferencia Episcopal Venezolana. Compendio de la doctrina social de la iglesia. Venezuela.2006. p.66

2.3.5.4.1- DECLARACIONES DEL SIGLO XIX:

- Constitución francesa, de 1848.
- Constitución de Cádiz, de 1812.
- Constitución de la Monarquía Española, de 18 de junio de 1837.
- Constitución Española, del 23 de mayo de 1845.
- Constitución de la Monarquía Española, de 1856.
- Constitución de la Nación Española, del 01 de junio de 1869.
- Proyecto de Constitución Federal de la República Española, del 17 de julio de 1873.
- Constitución de la Monarquía Española, de 1876.

2.3.5.5.- DECLARACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XX

Con el devenir del siglo XX, los movimientos sociopolíticos que se generan en América Latina (México), Constitución de Querétaro, como los que se generan en Europa, (Alemania), Constitución de Weimar, van a dar lugar al nacimiento de un nuevo constitucionalismo que:

1. Generará una nueva visión sobre los parámetros fundamentales de la organización del Estado, y los derechos de los ciudadanos. Nace una segunda ola de derechos, que son los derechos sociales, en el área laboral, educación, salud y vivienda.

2. Ello dará lugar a lo que en la doctrina alemana se llamó más tarde el Estado Social. La propiedad que era un típico derecho individual absoluto e ilimitado, en virtud de su función social asume una serie de limitaciones, restricciones y contribuciones.

2.3.5.5. 1- CARACTERÍSTICAS DE LAS DECLARACIONES DEL SIGLO XX

- La Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, prosigue como el gran hito inspirador tanto en el orden constitucional interno (Preámbulo de las constituciones francesas de 1946 y 1958)⁴⁸, como de las declaraciones *stricto sensu*, por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos; contribuyendo a la consagración constitucional e internacional definitiva de los derechos económicos, sociales y culturales; se entreve la vigencia y reconocimiento de los llamados derechos de «tercera generación».

48 Es en la década de los setenta cuando el Consejo Constitucional incorpora al Texto Constitucional la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y el Preámbulo de la Constitución de 1946: Esto se produjo a raíz de la 1ª Decisión del Consejo Constitucional francés 75-51, DC del 27 de diciembre de 1973. Existe en la doctrina francesa cierta polémica en torno a la hipotética relación jerárquica entre los derechos reconocidos en la Declaración de derechos de 1789, y el Preámbulo de la Constitución de 1946, pero es una cuestión que simplemente dejamos apuntada, pues no existe unanimidad en la doctrina. Se puede consultar, en este sentido, GENEVOIS, B., *La jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Principes directeurs*, Paris, 1988, pp. 197 y ss.

- Se acentúa el proceso de expansión de las garantías de los derechos humanos; conllevando a una concientización protectora en el orden internacional.
- Como consecuencia de lo anterior se realizan denodados esfuerzos para crear los organismos internacionales (universales y regionales) de protección de los derechos humanos.
- Surgen y consolidan las denominadas Organizaciones no Gubernamentales con el propósito específico de proteger los Derechos Humanos
- Se concretizan el proceso de protección de los Derechos Humanos hacia grupos o situaciones específicas.

2.3.5.6. - LAS DECLARACIONES CONSTITUCIONALES

Las declaraciones constitucionales se definen como el reconocimiento formal por parte de los textos legales constitucionales contemporáneos, de los derechos humanos como derechos fundamentales, en cuanto a concreción positiva de aquellas, y de sus correspondientes garantías.

- Por el significado trascendental alcanzado en la historicidad de los Derechos Humanos, es plausible destacar: La Constitución Federal de los Estados Unidos de México de 1917.
- La Constitución de la República Soviética Federativa Socialista Rusa de 1918, que incorporó en sus normas la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. De 1917. Ese mismo año ocurre la Revolución bolchevique degenerando en la implantación del modo de producción socialista.
- La Constitución de Weimar, Alemania, de 1919.
- La constitución de la República Española de 1931.

Lo anterior, en su conjunto ha ido conformando las particularidades que hoy día se le reconocen a los derechos humanos como tales, siendo propicio establecer la interrelación existentes entre ellas.

2.3.6.- CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Las características de los derechos humanos han sido precisadas en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993⁴⁹, al establecer que son:

1. Universales
2. Indivisibles e interdependientes.

49 <http://www.cinu.org.mx/temas/dh/decvienapaccion.pdf5>. “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Pero además se puede agregar que son:

3. Absolutos en sustancia.
4. Inalienables e irrenunciables.
5. Progresivos.
6. Transnacionales.
7. Irreversibles.

2.3.6.1.- UNIVERSALIDAD

Esta característica implica que todas las personas son titulares de los derechos humanos y no pueden invocarse diferencias de regímenes políticos, sociales o culturales como pretexto para ofenderlos o menoscabarlos. La universalidad es inherente a los derechos fundamentales del hombre porque se trata de derechos que son expresión de la dignidad intrínseca de todo individuo, debiendo, en ese sentido, ser aceptados y respetados por todos los Estados, con independencia de su sistema ideológico-político, económico y socio-cultural.

La Carta de las Naciones Unidas lo expresa de forma categórica exigiendo en el preámbulo su cumplimiento como esencial condición de paz y comprometiéndose a promover su respeto universal.

“La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza”⁵⁰.

No obstante, hay que aclarar que pueden existir distinciones que no impliquen discriminación entre los seres humanos, y esto ocurre cuando se encuentran legítimamente fundamentadas.

En este sentido la misma Corte Interamericana de Derechos humanos ha expresado: (...) no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio...no habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas, ya que sólo es discriminatoria una distinción cuando carece de justificación objetiva y razonable”⁵¹.

El artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra esta característica de la siguiente forma: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo,

50 Bidart Campos, Germán y otros: Derechos Humanos Corte Interamericana. Opiniones Consultivas. Textos completos y comentarios. CIDH OC /NO.4 del 19/01/1984, Párrafo. 55)

51 Ib. CIDH O/C N°.4 del 19/01/1984, párr. 56 y 57

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

La universalidad también se evidencia del contenido del artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y del artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Sin embargo, a pesar del carácter universal de los derechos humanos se han permitido la existencia de ciertas diversidades culturales.

En particular, esto es así en lo que concierne a las garantías que rodean a ciertos derechos, o en la interpretación de conceptos jurídicos determinados. Originando de esta forma lo que se conoce como: la doctrina del margen de apreciación o discrecionalidad que en el caso de conceptos jurídicos indeterminados permite a cada Estado fijar, de acuerdo con sus circunstancias, el sentido y alcance de ese concepto. Por ejemplo, corresponde al Estado precisar, en principio, y sujeto a control posterior por parte de los organismos internacionales, la restricción de ciertos y determinados derechos, así como determinadas materias entre las que se encuentran:

- Lo que constituye un plazo razonable para la duración del proceso.
- La naturaleza excepcional de las circunstancias y la necesidad de suspender los derechos humanos.
- El significado de seguridad nacional, orden público, salud pública, moral pública, o los derechos de los demás.

En este caso, es evidente que las restricciones que algún Estado pueda considerar necesarias para preservar los intereses sociales pueden no serlo en el país vecino.

2.3.6.2. - INDIVISIBILIDAD E INTERDEPENDENCIA

For the reason that it is insufficient to respect some human rights and not others. In practice, the violation of one right will often affect the respect of several others rights. Al human rights should therefore be seen as having equal importance and of being equally essential to respect for the dignity and worth of every person”.⁵²

Los derechos humanos no pueden ser considerados en forma aislada, forman un todo y se encuentran vinculados unos con otros, por lo tanto todos tiene una similar importancia. Estos derechos se complementan entre sí, por lo que es necesario para alcanzar la vigencia de unos, que se garanticen los otros. No es por eso permitido enarbolar el subdesarrollo para justificar el atentado a los derechos humanos. Ciertamente esa circunstancia condiciona, merma, desde luego el disfrute de estos derechos, pero no debe ser invocado como excusa absoluta de su vulneración más flagrante.

En ocasiones se destaca diferencias entre los derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos, sin embargo la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán (1968) proclamó la indivisibilidad de los derechos humanos, afirmando que la plena realización de los derechos

52 <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf>

civiles y políticos era imposible sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, postura que fue avalada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, según Resolución 32/130.

En ese sentido los países de Latinoamérica y del Caribe, en enero de 1993, en San José de Costa Rica, expresaron: “No se puede ni se debe desconocer el goce de unos (derechos) so pretexto de no haberse alcanzado el pleno disfrute de los otros”⁵³.

2.3.6.3. – SON ABSOLUTOS

Son absolutos en sustancia, porque las reglamentaciones a su ejercicio no pueden suprimir la esencia del derecho. Para poder determinar el límite debajo del cual carece de significación un derecho, se debe estar en condiciones de probar, en cada caso en concreto, si la finalidad del derecho, después de la limitación, puede o no lograrse.

Una limitación afecta el contenido esencial de un derecho cuando su titular queda convertido en mero objeto de la actividad estatal, especialmente cuando se condiciona el ejercicio del derecho al cumplimiento de presupuestos que no pueden realizarse a pesar de poner en ello el máximo esfuerzo, por ello es relevante la discrecionalidad y proporción en la restricción de un determinado derecho. En consecuencia, el acto de suspensión de garantías debe publicarse por los medios oficiales del Derecho interno de cada país y comunicarse a la comunidad internacional, según lo pautan las convenciones de derechos humanos.

2.3.6.4.- SON IRRENUNCIABLES

Esta característica significa que los derechos no pueden perderse, ni aún por renuncia de sus titulares. Es decir, ningún ser humano como titular de los derechos puede decidir dejarlos sin efecto, no puede, aún con su consentimiento, dejar de gozar de ellos; es decir la persona no puede afectar su dignidad; tampoco el Estado puede violentarlos o transgredirlos.

El argumento básico para justificar la irrenunciabilidad de los derechos es la dimensión del daño que inferiría a su titular como consecuencia de su renuncia.

La inalienabilidad e irrenunciabilidad denotan el carácter fundamental de los derechos humanos, sin los cuales el hombre no puede ser considerado como tal. Nikken, citado por Cubas, señala: “Sin embargo hay que acotar que, en situaciones de normalidad, los límites no pueden nunca afectar el contenido esencial del derecho humano sujeto a restricción. Por otra parte, en situaciones de emergencia la ocasional suspensión de garantías está sujeta a determinadas condiciones, que pueden resumirse en las siguientes:

1.- **Estricta necesidad:** La suspensión de las garantías debe ser indispensable para atender la emergencia.

53 <http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/Opendocument> Informe de la reunión regional para America Latina y el caribe de la conferencia mundial de derechos humanos

2.- **Proporcionalidad:** Implica que sólo cabe suspender aquellas garantías que guarden relación con las medidas excepcionales necesarias para atender la emergencia.

3.- **Temporalidad:** Las garantías deben quedar suspendidas sólo por el tiempo estrictamente necesario para superar la emergencia.

4.- **Respeto a la esencia de los derechos humanos:** Existe un núcleo esencia de derechos cuyas garantías no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia. “(...) la lista de garantías no suspendibles más amplia es, probablemente, la contenida en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según la cual están fuera del ámbito de los estados de excepción los siguientes derechos:

1. derecho a la vida;
2. derecho a la integridad personal;
3. la prohibición de esclavitud y servidumbre;
4. la prohibición de la discriminación;
5. el derecho a la personalidad jurídica;
6. el derecho a la nacionalidad; los derechos políticos; el principio de legalidad y no retroactividad;
7. la libertad de conciencia y religión;
8. la protección a la familia y los derechos del niño;
9. así como las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos, entre los cuales deben considerarse incluidos el amparo y el hábeas corpus. (p.45)

2.3.6.5.- SON PROGRESIVOS

El desarrollo de la protección internacional de los derechos humanos, si bien ha sido paulatino, a medida que ha transcurrido el devenir histórico, estos se han afianzado traspasando la barrera del derecho interno de los Estados para insertarse en un sistema trasnacional. El derecho internacional al ser complementario se mantiene atento para atajar la transgresión, por ser un derecho amplio más no restrictivo. Al respecto, en Venezuela se acogió este principio en la Constitución de 1999 en el artículo 19 los siguientes términos:

*“El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”.*⁵⁴

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en fecha 13 de julio de 2005, sentencia N° 1654; señaló: (...) “la progresividad

54 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N° 5.453 Extraordinaria de 24 de marzo de 2000.

de los derechos humanos se refiere a la tendencia general de mejorar cada vez más la protección y el tratamiento de estos derechos”.Refiriéndose a la proporcionalidad de las penas conforme a la gravedad del delito y a la igualdad que debe establecerse, no pudiéndose menoscabar esta por cuanto “(...) sería contradictorio con el verdadero sentido de la justicia y la equidad”.

2.3.6.6.- SON TRASNACIONALES

Si los derechos humanos son inherentes a la persona como tal, no dependen de la nacionalidad de ésta o del territorio donde se encuentre; los porta en sí misma.

Si ellos limitan el ejercicio del poder, no puede invocarse la actuación soberana del gobierno para violarlos o impedir su protección internacional.

Los derechos humanos están por encima del Estado y su soberanía, y no puede considerarse que se violenta el principio de no intervención cuando se ponen en movimiento los mecanismos internacionales para su promoción y protección.

2.3.6.7.- SON IRREVERSIBLES

Cuando un derecho ha sido reconocido por una ley, un tratado o por cualquier otro acto del poder público nacional como inherente a la persona humana, la naturaleza de dicho derecho se independiza del acto por el que fue reconocido, que es meramente declarativo.

La tutela debida a tal derecho se fundamenta en la dignidad humana y no en el acto por el cual fue reconocido como inherente a dicha dignidad. En adelante, merecerá protección propia aún si el acto de reconocimiento queda abrogado o, si se trata de una convención internacional, la misma es denunciada.

En la evolución de los derechos humanos su reconocimiento y protección ha ido «*in crescendo*»; formulándose para su clasificación diversos criterios, sin embargo a los fines de la investigación se estima apropiado aquella que los clasifica o cataloga por *generaciones* atendiendo al contexto histórico y positivista; sin embargo esto no implica que ante la protección de los derechos humanos en el paradigma vigente unos tengan prelación frente a otros; independientemente incluso ante el asentimiento de considerar la existencia del llamado «núcleo duro» de los derechos humanos.

2.3.7.- CLASIFICACIÓN

Una de las clasificaciones más conocidas es aquella que distingue tres grupos de derechos humanos en *generaciones*, la cual responde a dos criterios: uno histórico y otro temático, mediante la cual se trata de explicar la aparición sucesiva de series o grupos de derechos en distintos momentos de la historia, del tal manera que cada generación incluya derechos de una misma clase; esta sistematización se originó una vez aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas decidiera

en 1951 elaborar dos instrumentos que tipificaran los derechos civiles y políticos en un pacto y los derechos económicos, sociales y culturales en otro pacto. Existiendo, para aquel entonces una fuerte corriente doctrinaria que estimaba la reivindicación de los derechos civiles y políticos y su aplicación debía ser de forma inmediata, a diferencia de los derechos económicos, sociales y culturales debían ser implementados de manera progresiva; es decir se entró en una superada distinción de considerar que los derechos constitucionales son unos operativos y otros programáticos.

2.3.7.1.- Derechos de primera generación

Los derechos civiles y políticos; dentro de los cuales se encuentran, entre otros, los siguientes derechos: a la libertad, a la dignidad, a la igualdad, a la vida y a la seguridad personal; a no ser torturado ni sometido a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes; a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o tráfico de seres humanos; a la personalidad jurídica; etc.

Estos derechos implican el deber del Estado de abstenerse de realizar cualquier acto que los menoscabe o pueda menoscabarlos, aunque esto no siempre es así, ya que para determinados derechos se requiere un actuar positivo del Estado.

2.3.7.2.-DERECHOS DE SEGUNDA GENERACIÓN. LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

Dentro de los cuales, entre otros, se ubican los siguientes derechos: al trabajo, a condiciones de equidad, dignidad, seguridad e higiene en el trabajo; de asociación sindical, de huelga y de negociación colectiva; a la salud; a la educación; a la cultura, el arte y la ciencia; a una vivienda digna.

Estas garantías están orientadas a dignificar la existencia humana en sus dimensiones familiar, laboral y comunitaria, mediante la provisión de los servicios públicos y sociales, los cuales implican un actuar positivo por parte del Estado, pero que en algunos casos exigen una abstención por parte del mismo.

2.3.7.3.- TERCERA DE GENERACIÓN.

Donde se incluyen los siguientes derechos tendientes a un orden internacional apto para los derechos humanos; a la libre determinación de los pueblos y a la libre disposición de sus riquezas y recursos naturales; de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a su cultura, a su religión y a su lengua; de los trabajadores migrantes a trabajar en otros países bajo condiciones dignas y justas; a un medio ambiente sano.

En relación con esta clasificación por generaciones hay que indicar que:

1. No es la más adecuada, por cuanto no es cierto que los derechos civiles y políticos hayan sido reconocidos en primer término que los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo cuando los Barones ingleses que propiciaron la Carta Magna de 1215, en el fondo realmente protegían eran sus derechos e intereses económicos ante el abuso del

monarca en la imposición de los impuestos para sufragar su política exterior.

2. También ha implicado una categorización de los derechos que no es acorde totalmente con sus características; la interdependencia de los derechos humanos no permite su desglose no se pueden proteger unos y otros no.

El derecho a la vida implica el goce y ejercicio de los demás derechos; por ejemplo, en el caso Velásquez Rodríguez la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que: “La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto, que infringe el artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a la libertad personal”.⁵⁵

Siendo, Cancado Trindade (1994) contundente al rechazar esta clasificación, pudiendo ser útil sólo a fines «didácticos». Igualmente, Ligia Bolívar (1996), reflexiona acerca de esta clasificación de los derechos económicos, sociales y culturales como de segunda generación en contraposición a los civiles y políticos compartiendo las tesis relativas a la «necesidad de superar la doctrina de la dicotomía a favor de la indivisibilidad y la interdependencia». (p.88).

En definitiva, los derechos humanos deben concebirse desde una perspectiva integral. Los derechos de tercera generación que para el año 1951 aún no estaban en boga y en consecuencia no entraron en el debate doctrinal persiguen la protección de los intereses difusos, es decir aquellos que son susceptibles de ser aprehendidos por todos los integrantes de una comunidad o de varias; es decir están diseminados, esparcidos; la titularidad corresponde no al particular, sino a un grupo indeterminado de personas que tengan un interés legítimo de inestimable valor. Ya no es el derecho de un particular, son los derechos de muchos, de la supervivencia de la Humanidad.

También, cabe mencionar dada por Loperana Rota⁵⁶ quien ofrece otra clasificación dividida en dos categorías: Por una parte, los derechos que el Estado debe respetar y proteger, y por otra, los que el Estado debe promover o proveer. Como bien lo afirma el autor, sólo los primeros son imprescindibles para que una sociedad pueda ser calificada como tal, mientras que los segundos son opciones “civilizatorias”, actualizables con el desarrollo social y progreso económico en su contenido.

Los seres humanos cada día se encuentran ante nuevas amenazas a sus derechos, existiendo un riesgo latente y palpable que afecta a todos como «el calentamiento global»; produciendo inminentes daños, por los momentos quizás en algunos lugares aún no hayan ocurrido desastres naturales a consecuencia de las variaciones climáticas; sin embargo ninguna especie está

55 http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=16. párr. 155

56 Citado por: Mario Peña Chacón en Derechos Humanos y Medio Ambiente: <http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Derechos%20Humanos%20y%20Medio%20Ambie>

exenta del peligro que representa la transgresión avasallante al planeta que alberga a la persona humana; no le corresponde sólo al derecho interno su protección la realidad conlleva a pensar en el orbe.

CAPITULO III

PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DE LA PERSONA HUMANA

Lo que en definitiva desencadenó la internacionalización de los derechos humanos fue la conmoción histórica de millones de personas fallecidas durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior creación de la Organización de las Naciones Unidas. La magnitud del genocidio puso en evidencia que el ejercicio abusivo del poder constituye una actividad peligrosa para la dignidad humana, de modo que su control no debe dejarse a cargo, exclusivamente, de las instituciones domésticas, sino que deben constituirse instancias internacionales para su protección. De acuerdo a Ramírez (...) ha sido una constante que las guerras libradas, aunque han causado daños incommensurables son las que a su vez propician la puesta en marcha las más lúcidas mentes para idear mecanismos e instrumentos para proteger a la dignidad humana (2010).

La idea moderna de los derechos humanos nacido del iusnaturalismo supone un estandarte ante el omnipotente Estado que negaba los derechos mínimos del ser humano; esto lo hace notar Lauterpacht (1950):

The doctrine of natural law thus called into being and periodically resuscitated by its parent, progeny an ally— the rights of man — in due course fulfilled function other than buttressing the claims of the indestructible human right. But the original connexion never disappeared. The doctrine of the fundamental rights of the individual owed as much to the idea of natural law as the latter owed to the former The interaction was constant and mutually beneficial. That drama in the realm of thought was re-enacted, under the impact of the same dynamic cause, at the beginning of the twentieth century during and after the First World War and in the course of the rise of totalitarianism in the decade preceding the Second World War. The renaissance of the law of nature at the beginning of the twentieth century was not yet another theory of the judicial function. It was the unmistakable result of the urge to find a spiritual counterpart to the growing power of the modern State. (...) (p. 112-113).

Consideraba que el renacimiento de la ley de la naturaleza a principios del siglo XX, no fue otra teoría de la función judicial. Fue el resultado inequívoco de la necesidad de encontrar una contraparte espiritual al creciente poder del Estado moderno. Ante el evidente peligro que representaba si una vez más se producían formas amenazantes de gobernar amparados bajo la tutela

de la soberanía de la desenfrenada, en contra del orden internacional y se promocionara la anarquía internacional; amenazando a través del espectro de la guerra moderna, tanto el derecho del hombre como la herencia de su civilización.

El movimiento hacia la reactivación de la ley natural después de la II Guerra Mundial fue la manifestación generalizada del peligro. Cuando el mal intrínseco en la naturaleza humana, logró posicionarse en el Estado alemán y amenazó con extinguir al hombre, en países y regiones que se oponían a la ideología gobernante. La tradición de la ley de la naturaleza una vez más se convirtió en un elemento vital en la afirmación de la dignidad de la persona y en el deseo de encontrar una base en la ley más duradera que la voluntad del soberano pudiese ejecutar.

Una de las manifestaciones más características de la Alemania nacional-socialista y la doctrina italiana fascista era negar los derechos; de donde el derecho natural se imbricó en las bases racionalistas, por lo que se puede explicar el fervor y la intensidad de la reaparición de la idea con fundamento en el derecho natural. Sólo así se puede explicar por qué, en el momento mismo en que el reconocimiento internacional de los derechos humanos se ha convertido en una parte sustancial en el derecho positivo para hacer más eficaz el reconocimiento, no hay ninguna inclinación a desechar los derechos naturales del hombre y la ley de la naturaleza concebida como la justificación y la medida de todas las leyes hechas por el hombre.

3.1- AFRENTAS A LA NATURALEZA HUMANA QUE PROPICIARON LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

No basta con señalar que después del horror acontecido durante la II Guerra Mundial, es cuando nace prácticamente el encumbramiento de los derechos humanos para posicionarse sin ambages en el orden internacional, además de penetrar en el orden interno; en algunas ocasiones con reticencias otras en forma explícita, es menester reflexionar sobre como el «abuso del poder» en forma inmisericorde, no sólo ocasiona daños materiales; sino el ataque directo al meollo que distingue a la persona humana de cualquier otra criatura «su dignidad», produjo la motivación adecuada para que las grandes potencias (EEUU después del ataque a Pearl Harbor, Gran Bretaña y Rusia); coincidieran en colocar su arsenal militar y destreza humana en procura de una causa

Si bien, pueden ser múltiples los métodos que utilizaron los nazis para doblegar al enemigo; todos confluyen en lo siguiente:

a.- La utilización del temor: Montesquieu, en *El espíritu de las leyes*¹, nos dice: “De idéntica forma como en una república es necesaria la virtud y en una monarquía el honor, en un gobierno despótico lo es el *TEMOR* (...), quien mejor que Buerquenthal² (2008), para describir lo que implicó

1 Traducción, Francesc Ll. Cardona. Edicomunicación. (España). 2003. III. IX. p.31

2 Nació en 1934 en Lubochna (antigua Checoslovaquia, hoy Eslovaquia <<el juez víctima>>. Creció en el gueto de Kielce en Polonia y sobrevivió a los campos de Auschwitz (donde

vivir el Holocausto (...) “Nos obligaron a formar una hilera y presenciar las ejecuciones. Se ordenó a los prisioneros que se parasen en sillas bajo las horcas mientras los alemanes obligaban a un número equivalente de reclusos, de pie sobre escaleras, a colocar las sogas al cuello de los condenados, que tenían la cabeza descubierta (...) “Los cuerpos de los prisioneros siguieron colgando durante unos cuantos días junto a la entrada del barracón a modo de advertencia” (...) escribían algo sobre los brazos extendidos (...) “Ahora tenía un nuevo nombre : B-2930, y ese sería el único «nombre» relevante en el campo (...) “amarillo, el color que nos identificaba como judíos.

Había colores diferentes para distinguir a las diversas clases de prisioneros. Los políticos, por ejemplo, llevaban triángulos rojos. Se asignaron otros colores a los homosexuales, a los criminales, etc.). (...) “Ni cadáveres ni nombres. ¡Sólo cenizas y números anónimos!”. (...) “algunas personas se convertían poco a poco en «musulmanes» (*muselmänner*) nombre que se le daba a aquellos prisioneros que ya estaban demacrados, consumidos, iban de aquí para allá con la mirada perdida, habían dejado por completo de ingerir alimentos y al poco tiempo morían”. (...) “era difícil no ponerme a temblar cuando me llamaba alguno de ellos”. (pp. 80-85).

b.- La supresión de la voluntad: Siguiendo con Montesquieu: “en los Estados despóticos la naturaleza del gobierno obliga a una obediencia extrema; una vez conocida la voluntad del príncipe, debe ésta surtir efecto tan infaliblemente como produce el suyo una bola que golpea a otra. No hay lugar para atenuaciones, modificaciones, acomodados, plazos, equivalencias, tratos o reconvenções, ni proponer algo igual o mejor”³. Los gobiernos totalitarios saben apertrecharse de los mecanismos necesarios para lograr tal represión que infunda el temor requerido para dominar, aniquilando la voluntad de la naturaleza humana; “Los pacientes sabían muy bien que los llevaban a las cámaras de gas (...) cada tantas semanas, las SS regresaban al campamento gitano y realizaban sus selecciones periódicas. Tales selecciones en general eran dirigidas por uno o dos médicos de las SS, y a menudo se llevaban a cabo bajo la supervisión del tristemente célebre doctor Mengele, conocido como «el Ángel de la Muerte », y cuyo mero nombre me hacía temblar de miedo”.⁴

c.- Eliminación de todo vestigio de Humanidad. La dignidad de la persona humana simplemente no existe.” Así como en las monarquías la educación se encamina sólo a elevar el ánimo, en los Estados despóticos procura hundirlo. Se requiere, pues, que sea servil (...) se reduce a meter el miedo en el corazón (...) el saber será peligroso, la emulación funesta y, en cuanto a las virtudes, no creía Aristóteles que haya alguna propia de esclavos (...) La educación, en cierto modo no existe.

Hay que quitarlo todo para dar algo y empezar por hacer un súbdito para

perdió a su padre). Desde 1979 hasta 1991 fue Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (...) Desde año 2000 es el Juez estadounidense de la Corte Internacional de Justicia. “Un niño afortunado”, es su obra donde describe esa parte de su vida. Editorial Plataforma (España). 4ed. 2008.

3 Op.cit. Ib, X. p 32

4 Op.cit. p.87

tener un buen esclavo”.⁵ (...) “El temor de los gobiernos despóticos nace entre amenazas y castigos”.⁶

El cercenamiento de las potencias humanas, sin las cuales prácticamente pierde su condición de Hombre, era un fin con tal de imponer los objetivos de lograr un régimen que supuestamente duraría mil años; la impunidad permitida después de la I Guerra Mundial para juzgar al Kaiser Alemán, era inadmisibles después de superada la consternación de la II Guerra Mundial. Creándose para juzgar a los jerarcas nazis el Tribunal de Nuremberg y lo propio en el Tribunal de Tokio; el derecho internacional de los derechos humanos no se detendría allí, en 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados deliberaron sobre la base de propuestas preparadas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido, y los Estados Unidos en Dumbarton Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944.

De esta manera los sistemas de protección de los derechos humanos a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre adoptada el 10 de diciembre de 1948 *“Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”*.⁷ Se ha irradiado, por ello se deben analizar los sistemas emblemáticos que han contribuido al fortalecimiento y protección de la dignidad humana en primer lugar el sistema marco universal y luego a nivel regional el europeo, el americano y el africano.

3.-2.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Xifra Heras (1957) estima que: “La proliferación cada vez más extendida de organizaciones políticas supra estatales y de los documentos rectores de las mismas, justifica el hecho de que se hable, cada vez con mayor insistencia, de una disciplina cuyos perfiles no han sido todavía debidamente fijados: el Derecho Constitucional Internacional” (...) (p.297). Y Alcalá Zamora (1975), se preguntaba ante la proliferación de instrumentos tendientes a proteger los derechos humanos “Los preceptos sobre protección procesal de los derechos humanos, ¿Integran una nueva rama procesal? (p.44) (...) concluyendo que “Hablar de *Derecho constitucional internacional* y correlativamente de su proceso, no supone ningún dislate (...) “Que el derecho constitucional internacional no haya alcanzado todavía, por razones y dificultades obvias, la madurez del interno, no es argumento para rechazar su existencia y la relación entre ambos sería idéntica a la que en un Estado federal media entre la constitución nacional y las de las diversas entidades federativas”. (p.49)

5 Op.cit. IV. III.p.35

6 Op.cit. V. p. 36

7 <http://www.un.org/es/documents/udhr/>

Lo anterior hace percibir que es indudable que a partir de 1945 se asumieron importantes declaraciones y pactos, los cuales constituyen la fuente del Derecho Internacional de los derechos humanos.⁸ Estos generaron una serie de sistemas, asintiendo con Medina Quiroga⁹ en relación a la materia de derechos humanos que: “Sistema de promoción y protección de los derechos humanos es, como la palabra lo enuncia, un conjunto de reglas y principios racionalmente enlazados entre sí, que debe mirarse en su integridad para aplicar cualquier parte de él”; entonces, debe entenderse que el objetivo principal no es más que pautar normas que contribuyan a la afirmación ante el mismo hombre de una necesidad imperante de protegerlo de sí mismo, porque ¿Quién ha concebido las guerras?, ¿Quién indiscriminadamente atenta contra la naturaleza? ...¡El Hombre!; como único ser susceptible de ostentar deberes y derechos, así como es único en estar investido por su peculiar naturaleza de una dignidad, que a decir de los destacados juristas Goig, Nuñez Martínez y Nuñez Rivero (2006) “La preocupación actual del derecho Internacional por la defensa de los derechos humanos parte de la consideración de que el hombre, por su propia naturaleza, por su propia consideración y por su propia dignidad, posee derechos que le son inherentes y que no nacen de una concesión de la sociedad política.

Si la dignidad es consustancial a la persona, habrá que inferir que es previa al Derecho, y por lo tanto el derecho debe realizarla y positivizarla a través de una serie de valores que se fundamentan en la dignidad humana” (...) (p. 21). Por ello, desde que la comunidad internacional comenzó a organizarse y se propició lo que menciona Ruiz de Santiago (1996) citando a Cancado Trindade “La superación del viejo obstáculo de la objeción con fundamento en el llamado dominio reservado de los Estados se acompaña del gradual reconocimiento y la cristalización de la capacidad procesal internacional de los individuos”.¹⁰

Según O’ Donnell (2004) La expresión “corpus juris de los derechos humanos” (...) es un aporte de la Corte Interamericana a la doctrina internacional. En su Opinión Consultiva OC-16/1999, la Corte Interamericana manifestó que “El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones)” (párr. 115).

Este concepto ha sido reafirmado por la Corte Interamericana en sentencias y opiniones más recientes. En su sentencia en el caso de los *Niños de la Calle*, la Corte Interamericana manifestó que: “Tanto la Convención Americana

8 <http://www.un.org/es/documents/>. La Declaración Universal ha inspirado más de 80 convenciones y declaraciones concertadas en el marco de las Naciones Unidas en relación una amplia gama de cuestiones. En virtud de seis de las convenciones se han creado órganos de expertos que vigilan la observancia por los Estados partes de los derechos establecidos en la convención correspondiente. Cuando los Estados las ratifican, aceptan que su legislación y sus prácticas sobre derechos humanos sean examinadas por órganos independientes de expertos

9 Consulta da en <http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex121/BMD000012117.pdf>

10 OC-16/99, párr. 115.

como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo *corpus juris* internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana” (párr. 194). Las disposiciones de la Convención sobre los derechos del niño, sentenció la Corte Interamericana, “(...) permiten precisar, en variadas direcciones, los alcances de las ‘medidas de protección’ a que alude el artículo 19 de la Convención Americana” (párr. 196); sin embargo aclara que: (...) “Este concepto es valiosísimo; no obstante, debe manejarse con conocimiento de sus límites teniendo en cuenta que se refiere esencialmente a la interpretación de normas, y no autoriza ignorar la distinción entre instrumentos que tienen carácter vinculante y los que no tienen esta calidad” (p.58).

Estos instrumentos han marcado pauta en la evolución progresiva del reconocimiento y protección de la persona, sirviendo de herramientas útiles al estatuir normas que en definitiva son conquistas de la humanidad, de allí la importancia de analizar los diferentes sistemas existentes, tales como:

3.-2.1- SISTEMA UNIVERSAL¹¹

Partiendo de la comunidad internacional organizada, especialmente de la Organización de las Naciones Unidas; desde donde se han proclamado múltiples Resoluciones, Acuerdos, Pactos o Convenios, tendientes en su conjunto a lograr los ansiados objetivos prescritos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas¹²; así enfáticamente desde el principio declara: “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas determinados (...) *a reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y valor a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia*

11 O'Donnell, Daniel: Derecho internacional de los derechos humanos Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Primera edición: Bogotá, abril de 2004. “La expresión “sistema universal” se refiere a los órganos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (en particular la Comisión de Derechos Humanos, la Subcomisión y los Relatores y Grupos de Trabajo que de éstas dependen), a los Comités de expertos establecidos en virtud de ciertos tratados en materia de derechos humanos (Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité contra la Tortura y Comité de los Derechos del Niño) y, eventualmente, a documentos elaborados por el Secretariado de las Naciones Unidas y resoluciones adoptadas por el Consejo Económico y Social (Ecosoc), la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Esta expresión no se refiere a los órganos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) u otras agencias que forman parte del sistema de las Naciones Unidas”.

12 La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta.

y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional” (...) ¹³.

Asimismo, en el Capítulo I donde se consagran los propósitos y principios se declara realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo *del respeto a los derechos humanos* y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión (...).¹⁴ Aparte, de la Carta de la Naciones Unidas se deben señalar algunos instrumentos que forman parte del sistema universal de protección de los derechos humanos.

3.-2.1.1- INSTRUMENTOS JURÍDICOS DEL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

- Carta de las Naciones Unidas
- Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
- Declaración Universal de Derechos Humanos
- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Racial
- Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
- Convención sobre los Derechos del Niño
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
- Convención sobre la Esclavitud
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
- Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
- Estatuto de la Corte Penal Internacional
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

¹³ <http://www.un.org/es/documents/charter/chapter>

¹⁴ Ib. Ib

- Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte
- Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer
- Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional
- Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926
- Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud
- Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación
- Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad
- Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
- Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
- Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones
- Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales
- Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas
- Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer
- Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado
- Declaración de los Derechos del Niño
- Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social
- Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz
- Declaración sobre el derecho al desarrollo
- Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
- Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
- Proclamación de Teherán
- Convención sobre el Estatuto de los Apátridas
- Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
- Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
- Declaración sobre el Asilo Territorial
- Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven
- Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Refugiados

- Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (Convenio I)
- Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (Convenio II)
- Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III)
- Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV)
- Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I)
- Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)
- Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación
- Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
- Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos
- Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales
- Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes
- Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza
- Convenio sobre igualdad de remuneración
- Convenio sobre el trabajo forzoso
- Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso
- Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la Prostitución ajena
- Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder
- Declaración de los Derechos del Retrasado Mental
- Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición
- Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad
- Declaración de los Derechos de los Impedidos
- Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias a que pueda dar lugar la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza
- Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad

mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios

- Convención para reducir los casos de apatridia
- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
- Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
- Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones
- Convenio sobre la edad mínima
- Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil.¹⁵

Desde el sistema universal se han formado los sistemas regionales.

3.-2.2.- SISTEMA EUROPEO

El Convenio Europeo Relativo a la Protección de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 Roma y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953, contiene como eje transversal la creación de mecanismos de protección jurisdiccional no sólo de los Estados (Art. 33), sino además de los particulares (Art. 34).

La idea surgió en el Congreso de La Haya de 1948, desde sus inicios se consideró que los ciudadanos de los países asociados pudieran iniciar ante la Corte sus reclamos. En el “Mensaje a los Europeos”, adoptado en la sección final, los congregantes declararon: “Deseamos una Carta de Derechos Humanos que garantice las libertades de pensamiento, de reunión y de expresión, así como el libre ejercicio de una oposición política (...) Deseamos una Corte de Justicia capaz de aplicar las sanciones necesarias para que la Carta sea respetada; la Comisión Europea de Derechos Humanos se instaló en 1954 y la jurisdicción internacional se constituyó el 21 de enero de 1959.

El objetivo principal que se propone consiste en alcanzar la protección, mediante la articulación de mecanismos jurídicos eficaces en relación a los derechos civiles y políticos de los individuos.

La Convención de Roma no protege todos los derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas, teniendo en principio un carácter selectivo. Los derechos contemplados por esta Convención son:

- El derecho a la vida (Art.2);
- La prohibición de la tortura, las penas o los tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art.3);
- La prohibición de la esclavitud o servidumbre y de determinados trabajos forzosos u obligatorios (Art. 4);

15 www.corteidh.or.cr/sistemas

- El derecho a la libertad y a la seguridad (Art.5);
- Los derechos jurisdiccionales en materia civil y las garantías procesales en el curso del proceso criminal (Art. 6);
- La prohibición de la retroactividad de las leyes penales (Art. 7);
- El derecho de protección de la vida privada y familiar, el domicilio y la correspondencia (Art. 8);
- El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (Art. 9);
- La libertad de opinión, de expresión e información (Art. 10);
- La libertad de reunión pacífica, asociación y fundación de sindicatos (Art. 11),
- El derecho a contraer matrimonio y fundar una familia (Art. 12).

En el sistema europeo se crearon dos órganos de protección de derechos humanos: la Comisión Europea de los Derechos del Hombre y la Corte Europea de los Derechos del Hombre; la Comisión la conformaba un miembro de cada Estado y realizaba funciones sobre todo de conciliación. En principio la Comisión recibía la denuncia de un Estado miembro sobre la violación de la Convención por parte de otro, o la demanda de un ciudadano, grupo de particulares u organizaciones no gubernamentales. Se Determinaban los hechos mediante un examen contradictorio e intentaba un arreglo amistoso sino se llegaba a un acuerdo se remitía el asunto al Comité de Ministros del Consejo de Europa luego se elevaba a la Corte el asunto, no podían hacerlo los particulares ni los grupos organizados.

El Protocolo 11 implica la más importante revisión que haya tenido, desde sus orígenes, el sistema europeo de protección de los derechos humanos. Entró en vigencia el 01 de noviembre de 1998; dejó de existir la anterior Corte, la Comisión continuó durante un año, instruyendo los asuntos que había admitido antes de la entrada en vigencia del Protocolo 11. Se crea un nuevo Tribunal que reemplaza a los dos órganos de control del sistema originario - la anterior Corte y la Comisión; cumple las funciones que éstos tenían. Funciona de manera permanente (Estrasburgo). Toda persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares, tienen el derecho de plantear su demanda directamente ante el Tribunal; por el sólo hecho de que el Estado demandado ratificó el Protocolo 11; a diferencia del sistema interamericano los europeos pueden acudir directamente al orden jurisdiccional sin pasar por una Comisión para demandar el goce y ejercicio efectivo de sus derechos.

El Tribunal de Derechos Humanos Europeo ha sido instituido con el fin de garantizar el respeto de los compromisos de los Estados Partes. A pesar de estar su sede está en Estrasburgo, cuando lo juzgue útil puede funcionar en otros lugares del territorio de los Estados Miembros del Consejo de Europa. Puede decidir que desde la instrucción de un asunto alguna de sus Salas realice investigaciones u otras funciones, en otros lugares; por ser permanente los jueces deben residir en el lugar en que esta tiene su sede o en lugares próximos.

La competencia del tribunal abarca el conocimiento de todas las cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de la Convención y de sus Protocolos. En caso de impugnación de la competencia el propio Tribunal decide la cuestión.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o Tratado de Lisboa, el pasado 1 de diciembre de 2009 un baluarte fundamental en este sistema de integración es el respeto a los derechos humanos, en este sentido el artículo 1 se enuncia de esta manera: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos (...), estando lo anterior en plena concordancia con el artículo 6 donde se incorpora a este tratado la Carta de los Derechos Fundamentales, equiparándola al mismo valor jurídico de los tratados.¹⁶ Pero, además, en Europa se han dispuestos diversos tratados y convenios que procuran la protección de la persona humana los cuales es preciso mencionar.¹⁷

3.-2.2.1 INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL SISTEMA EUROPEO

- Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales revisado de conformidad con el Protocolo n° 11 completado por los Protocolos n° 1 y 6
- Carta Social Europea
- Reglas de la Corte
- El Protocolo N ° 14 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que modifica el sistema de control de la Convención
- Acuerdo europeo sobre las personas que participan en procedimientos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
- El Protocolo N ° 14 bis del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
- Estatuto del Consejo de Europa
- Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa
- Protocolo del Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa Europea
- Acuerdo interino sobre Regímenes de Seguridad Social relativas a la Vejez, Invalidez y Sobrevivientes
- Protocolo del Acuerdo Europeo Interina de la Seguridad Social distintas de los dispositivos de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes
- Convenio Europeo de Asistencia Social y Médica

16 Artículo 6 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. “1.- La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los derechos fundamentales del 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los tratados (...)

17 http://europa.eu/index_es.htm

- Protocolo del Convenio Europeo de Asistencia Social y Médica
- Convenio Cultural Europeo
- Segundo Protocolo al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa
- Convenio Europeo para la Solución Pacífica de Controversias
- Convenio Europeo de Extradición
- Tercer Protocolo del Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa
- Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal
- Acuerdo europeo sobre la abolición de visados para los Refugiados
- Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa
- El Protocolo N ° 2 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que confiere a la Corte Europea de Derechos Humanos la competencia para emitir opiniones consultivas
- El Protocolo N ° 3 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Las Libertades Fundamentales, que modifica los artículos 29, 30 y 34 de la Convención
- Protocolo N ° 4 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, reconocen ciertos derechos y libertades distintos de los que ya figuran en la Convención y en el primer Protocolo en su forma enmendada por el Protocolo N ° 11
- Protocolo N ° 5 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, se modifican los artículos 22 y 40 de la Convención
- Convenio Europeo para la adopción de niños
- Convenio europeo sobre la repatriación de los menores
- Convenio europeo sobre inmunidad de los Estados
- Protocolo adicional al Convenio Europeo para la inmunidad de los Estado
- Convenio Europeo para la Seguridad Social
- Acuerdo Complementario para la Aplicación de la Convención Europea para la Seguridad Social
- Convenio Europeo sobre la no Aplicabilidad de las Limitaciones legales a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra
- Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo
- Convenio europeo sobre el estatuto jurídico del trabajador migrante
- Segundo Protocolo adicional al Convenio Europeo de Extradición
- Protocolo adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal
- Acuerdo europeo sobre la transferencia de responsabilidad para los Refugiados

- Convenio sobre traslado de personas condenadas
- Protocolo N ° 6 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en su versión modificada por el Protocolo N ° 11
- Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos
- El Protocolo N ° 7 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
- Protocolo N ° 8 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
- Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos o Degradantes
- Protocolo Adicional a la Carta Social Europea
- Quinto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa
- El Protocolo N ° 9 a la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
- Protocolo que modifica la Carta Social Europea
- El Protocolo N ° 10 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
- Protocolo No. 1 al Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos o Degradantes
- El Protocolo N ° 2 del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos o Degradantes
- Protocolo del Convenio Europeo de Seguridad Social
- Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales
- Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño
- Sexto Protocolo del Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa
- Carta Social Europea
- Convenio Europeo sobre la Nacionalidad
- Protocolo adicional al Convenio sobre traslado de personas condenadas
- Protocolo Adicional a la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, sobre la prohibición de la clonación de seres humanos
- Convención sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal
- Convenio de derecho penal sobre la corrupción
- El Protocolo N ° 12 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
- Protocolo Adicional a la Convención sobre los Derechos Humanos y

- Biomedicina, sobre el trasplante de órganos y tejidos de origen humano
- El Protocolo número 13 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia
 - Convenio sobre la Ciber delincuencia
 - Protocolo Adicional a la Convención sobre el delito cibernético, relativo a la penalización de actos de naturaleza racista y xenófoba cometidos a través del sistema informático
 - Protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la corrupción
 - Protocolo que modifica el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo
 - El Protocolo N ° 14 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que modifica el sistema de control de la Convención
 - Protocolo Adicional a la Convención sobre los Derechos Humanos y Biomedicina, sobre Investigación Biomédica
 - Consejo de Europa sobre la prevención del terrorismo
 - Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos
 - Consejo de Europa sobre la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual
 - Convenio Europeo para la adopción de niños (revisado)
 - Protocolo Adicional a la Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina, en relación con las pruebas genéticas con fines de salud¹⁸.

3.-2.3.- SISTEMA INTERAMERICANO

La Convención Americana sobre Derechos Humanos¹⁹ adoptada en 1969 entró en vigor el 16 de julio de 1978, una vez que el número de países mínimo para su ratificación se concretó tal como lo pauta el artículo 74.2; expresado, así *“La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General*

18 <http://www.corteidh.or.cr/sistemas>

19 La Convención Americana fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.

La CIDH ha dicho: “La declaración Americana en efecto, fue adoptada por la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 1948) en virtud de una resolución tomada por la propia Conferencia. No fue concebida ni redactada para que tuviera la forma de un tratado. La resolución XL de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de Guerra y de la Paz (Chapultepec, 1945), había estimado que para lograr la protección internacional de los derechos humanos, éstos deberían estar enumerados y precisados en una Declaración adoptada en forma de Convención por los Estados. En el posterior proceso de elaboración del proyecto de Declaración en el Comité Jurídico Interamericano y luego en la Novena Conferencia, este enfoque inicial se abandonó y la Declaración se adoptó como tal, no previéndose ningún procedimiento para que pudiese pasar a ser un tratado” (CIDH, Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio)

de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión". El proceso hasta llegar a la Convención comenzó en 1948 en Bogotá (Colombia), donde con la adopción, por parte de la OEA,²⁰ de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La Convención Americana consagra derechos civiles y políticos, que se encuentran enumerados en los artículos 3 al 25; sólo dispone una norma sobre los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA (Art. 26)²¹; consagra obligaciones generales para los Estados respecto de los derechos reconocidos en la Convención (principalmente los Arts. 1 y 2); regulaciones aplicables en situaciones de emergencia (Art. 27); criterios de aplicación de la Convención en regímenes federales (Art. 28); normas de interpretación (Art. 29); referencias para incorporar derechos no reconocidos al régimen de la Convención (Art. 31); normas sobre restricciones y correlación entre derechos y deberes (Arts. 30 y 32); y mecanismos y órganos de supervisión del cumplimiento de las obligaciones allí consagradas para los Estados partes (Arts. 33 y siguientes).

El catálogo de derechos civiles y políticos de la Convención quizás por ser anterior a otros tratados de derechos humanos difiere en algunos aspectos generales. Los redactores de la Convención pudieron no sólo usar como modelos los textos de los Pactos Internacionales y de la Convención Europea, sino que también tuvieron la oportunidad de examinar como se venía desarrollando el sistema europeo, que comenzó a funcionar en 1953.²²

Los derechos están formulados de manera que, de vez en cuando, dejan ver las tradiciones e idiosincrasia de los Estados

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato:

20 La Carta de la OEA fue aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, realizada en Bogotá, Colombia, 1948. Hasta diciembre del 2001, la Carta había sido modificada por los siguientes instrumentos: Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Buenos Aires", suscrito el 27 de febrero de 1967, en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria; por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Cartagena de Indias", aprobado el 5 de diciembre de 1985, en el decimocuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General; por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Washington", aprobado el 14 de diciembre de 1992, en el decimosexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General; y por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Managua", adoptado el 10 de junio de 1993, en el decimonoveno período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

21 Esa referencia corresponde a la Carta de la OEA reformada por el Protocolo de Buenos Aires de 1967; sin embargo, el texto actualizado de la Carta de la OEA ha sustituido el nombre del capítulo aludido por "Desarrollo Integral".

22 Hoy día es notorio observar en diversas sentencias de la CIDH referencias a decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

- a) Recibe, analiza e investiga peticiones individuales que alegan violaciones de los derechos humanos, según lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención.
- b) Observa la vigencia general de los derechos humanos en los Estados miembros, y cuando lo considera conveniente publica informes especiales sobre la situación en un estado en particular.
- c) Realiza visitas *in loco* a los países para profundizar la observación general de la situación, y/o para investigar una situación particular. Generalmente, esas visitas resultan en la preparación de un informe respectivo, que se publica y es enviado a la Asamblea General.
- d) Estimula la conciencia de los derechos humanos en los países de América. Para ello entre otros, realiza y publica estudios sobre temas específicos. Así por ejemplo sobre: medidas para asegurar mayor independencia del poder judicial; actividades de grupos irregulares armados; la situación de derechos humanos de los menores, de las mujeres, de los pueblos indígenas.
- e) Realiza y participa en conferencias y reuniones de distinto tipo con representantes de gobiernos, académicos, grupos no gubernamentales, etc... para difundir y analizar temas relacionados con el sistema interamericano de los derechos humanos.
- f) Hace recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la adopción de medidas para contribuir a promover y garantizar los derechos humanos.
- g) Requiere a los Estados que tomen “medidas cautelares” específicas para evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos en casos urgentes. Puede también solicitar que la Corte Interamericana requiera “medidas provisionales” de los Gobiernos en casos urgentes de peligro a personas, aún cuando el caso no haya sido sometido todavía a la Corte.
- h) Somete casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y actúa frente a la Corte en dichos litigios.
- i) Solicita “Opiniones Consultivas” a la Corte Interamericana sobre aspectos de interpretación de la Convención Americana.²³

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)²⁴ tiene un papel principal en la interpretación de los derechos humanos de la Convención: sus sentencias son jurídicamente vinculantes para los Estados que son parte en el caso y, además, constituyen un fundamento sobre el cual la Corte construye principios y conceptos que se utilizan, a menudo, en la labor de supervisión

23 <http://www.cidh.oas.org/que.htm>. Estatuto CIDH, Arts. 18 - 20.

24 Caldera Juan José: 60 años de las Declaraciones Internacionales de los Derechos Humanos. Universidad Monteavila. Caracas.2008. La Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá también aprobó la Resolución XXXI sobre la “Corte interamericana para proteger los Derechos del Hombre” (p.33)

que realiza la Comisión Interamericana y se invocan por los defensores de las víctimas de violaciones. La Corte tiene también una competencia no contenciosa, calificada por ella misma como “un método judicial alternativo de carácter consultivo”.²⁵

Durante medio siglo, la defensa de los derechos humanos y del sistema democrático ha sido el eje central del trabajo del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Durante las primeras décadas, cuando gran parte de los países de la región estaban gobernados por dictaduras militares o Gobiernos autoritarios, la comisión fue la única alternativa para miles de personas que buscaban respuestas a las desapariciones, asesinatos y torturas de sus familiares y amigos. Por ejemplo, la visita a Argentina en 1979 permitió poner freno a las graves violaciones a los derechos humanos y obligó a la dictadura a responder a las denuncias de la comisión ante el mundo entero. En la década de los noventa, la visita a Perú durante el Gobierno autoritario de Fujimori-Montesinos facilitó el camino para la transición a la democracia.

El aporte más importante que ha dado este sistema a la región ha sido precisamente el fortalecimiento del sistema democrático, promoviendo dos pilares centrales del Estado de derecho: justicia y libertad de expresión. En el primer caso, principalmente mediante el reconocimiento de que hoy en día las leyes de amnistía por violaciones de los derechos humanos son inaceptables. Las decisiones de la comisión en casos contra Argentina, Uruguay, El Salvador, Chile y Perú abrieron una puerta que ha permitido sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de los golpes de Estado y del asesinato y desaparición de miles de personas. En el segundo caso, la derogación de las leyes que sancionan la crítica a funcionarios públicos -desacato- conjuntamente con la sanción de leyes de acceso a la información están consolidando la democracia, al permitir la crítica de las autoridades sin riesgo de represalias y la transparencia del accionar de los gobernantes.

Asimismo, la continuidad de Gobiernos democráticos permitió lograr importantes avances, como la modificación de Constituciones para evitar la censura previa, la sanción de leyes sobre justicia militar y violencia doméstica, la entrega de tierras a pueblos indígenas, y la reapertura de casos para terminar con la impunidad por la brutalidad policial. Indudablemente, en las próximas décadas este sistema deberá responder aún a más desafíos, como

25 “La función consultiva que confiere a la Corte el artículo 64 de la Convención es única en el derecho internacional contemporáneo. Como la Corte ya lo ha expresado en anterior oportunidad, ni la Corte Internacional de Justicia ni la Corte Europea de Derechos Humanos han sido investidas con la amplia función consultiva que la Convención ha otorgado a la Corte Interamericana (Otros tratados, supra 32, párrs. nos. 15 y 16). Cabe aquí, simplemente, poner énfasis en el hecho de que la Convención, al permitir a los Estados Miembros y a los órganos de la OEA solicitar opiniones consultivas, crea un sistema paralelo al del artículo 62 y ofrece un método judicial alternativo de carácter consultivo, destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso. Sería, por lo tanto, contradictorio con el objeto y fin de la Convención y con las disposiciones pertinentes de ésta, adoptar una interpretación que sometería el artículo 64 a los requisitos exigidos por el artículo 62 en cuanto a competencia, restándole así la utilidad que se le quiso dar, por el solo hecho de que pueda existir una controversia sobre la disposición implicada en la consulta”. Opinión Consultiva OC-3/83, Párr. 43

son la pobreza, la contaminación y el impacto del calentamiento global sobre la vida y salud de las personas, entre otros. Sin embargo a decir de Faúndez Ledesma (1999):

(...) los derechos humanos han tenido un efecto político importante, derivado de la interdependencia que existe entre ellos, la democracia y el desarrollo económico, pues tampoco se puede desconocer la existencia de condiciones objetivas que en sí mismas constituyen una violación de la dignidad humana, y que hacen indispensable realizar esfuerzos que permitan erradicar la pobreza extrema y eliminar la injusticia social.

En cuanto se refiere a la democracia, esta relación supone, desde luego, un camino de doble vía en que si bien la democracia es tanto un presupuesto necesario como una garantía, para el goce y ejercicio de los derechos humanos no es menos cierto que la plena vigencia de estos últimos ha pasado a formar parte esencial del contenido mismo de la democracia, por lo que esta tampoco se puede concebir sin aquellos. En realidad, la democracia y los derechos humanos son nociones que sólo pueden lograr un desarrollo aceptable de manera armónica, sin que ninguno de estos elementos pueda sacrificarse en el provecho del otro. Por consiguiente, sería erróneo pensar que los derechos humanos son sólo un problema de las dictaduras del pasado, y que resultan superfluos en el marco de una sociedad democrática; la diferencia está en que en esta última es más fácil afianzarlos y es menos traumático y peligroso defenderlos (p.35-36).

De esta manera, los Estados que forman parte del sistema interamericano también se han adentrado en la corriente *pro homine* que cada día estatuye derechos como la reciente declaración del derecho al agua como un derecho humano.²⁶ Los derechos humanos deben cumplir la teleología para lo cual han sido concebidos, no basta con que estén vaciados en sendos textos jurídicos en la praxis diaria es donde realmente se patentiza la eficacia que pueda surtir su consagración; en el solaz de los individuos, ciudadanos de un determinado país ee donde efectivamente se siente lo pragmático de consagrar unos derechos tendientes a proteger su naturaleza humana.

En este orden se mencionan a continuación algunos instrumentos jurídicos de protección de derechos humanos en el ámbito interamericano.

26 <http://www.un.org/spanish/News/> "28 de julio, 2010 La Asamblea General de la ONU reconoció hoy el acceso al agua potable como un derecho humano básico y urgió a garantizar que los casi 900 millones de personas que carecen del líquido vital puedan ejercer ese derecho.

En una resolución adoptada por 122 votos a favor, ninguna en contra y 41 abstenciones, la Asamblea estipuló también que el acceso a los servicios sanitarios básicos es un derecho en vista de que la contaminación del agua es una de las principales causas de mortalidad en los países más pobres. El texto -propuesto por Bolivia y copatrocinado por otros 33 Estados miembros de la ONU - recuerda que más de 2.600 millones de personas viven sin instalaciones sanitarias adecuadas, lo que contribuye a la muerte anual de 1,5 millones de niños por enfermedades relacionadas con la falta de salubridad".

3.-2.3.1- INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO

- Declaración Americana de los Derechos Deberes del Hombre
- Convención Americana sobre Derechos Humanos
- Carta de la OEA
- Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte
- Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
- Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”
- Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
- Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Convenio de Sede entre el Gobierno de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Carta Democrática de la OEA
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para”
- Estatuto de la Comisión Interamericana de Mujeres
- Convención Interamericana Contra la Corrupción

3.-2.4.- SISTEMA AFRICANO

Basándose en el sistema europeo en África también se propusieron tener su Carta de Derechos del Hombre y de los Pueblos que fue “Aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya” y entró en vigor el 21 de octubre de 1986, sin embargo a diferencia de las Convenciones Europea e Interamericana de Derechos humanos la africana se destaca en los siguientes aspectos:

1. No sólo proclama derechos sino también deberes.
2. Codifica tanto derechos individuales como del pueblo.
3. Además de garantizar los derechos civiles y políticos también protege los derechos sociales, económicos y culturales
4. Está elaborada de tal forma que permite a los Estados Parte imponer restricciones o limitaciones muy amplias al ejercicio de los derechos proclamados.

El contenido de la Carta refleja la influencia de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas y el de las tradiciones africanas. El énfasis de la Carta radica en el reflejo que las tradiciones africanas encuentran en su preámbulo y en la manera como mucho de los derechos y deberes se encuentran consagrados. El preámbulo expresa: “Teniendo en cuenta las virtudes de sus tradiciones históricas y los valores de la civilización africana que deben inspirar y caracterizar sus reflexiones sobre la concepción de los derechos humanos y de los pueblos”. La Carta contiene un artículo de no discriminación y de igual protección ante la ley (artículo 2 y 3).

Garantiza el derecho a la vida (artículo 4), al respeto de la dignidad y el reconocimiento de la personalidad jurídica y prohíbe la esclavitud como la tortura y los tratos y penas crueles, degradantes e inhumanas (artículo 5). Prohíbe la detención arbitraria (artículo 6). Asimismo, garantiza la libertad de religión y de conciencia (Artículo 8), de expresión (artículo 9), de asociación (artículo 10), el derecho de la propiedad (artículo 14), al trabajo y a un salario justo (artículo 15), a la salud (artículo 16), y a la educación (artículo 17).

No contiene ninguna disposición que autorice la derogación de los derechos humanos en caso de situaciones excepcionales. Además de los derechos individuales antes mencionados, se consagran derechos de los pueblos, como es el derecho a la autodeterminación (artículo 20), del ejercicio pleno de la soberanía sobre sus recursos (artículo 21), y al desarrollo económico (Artículo 22).

También, dispone el derecho a la paz (artículo 23) y el derecho a contar con un medio ambiente satisfactorio y global, propicio para su desarrollo (artículo 24). En cuanto a los deberes, se preceptúan dos tipos:

1. Aquellos correlativos a los derechos.
2. Los derivados de la restricción al ejercicio de un derecho determinado por un deber frente al colectivo en relación al ejercicio del mismo.

La distinción dependerá de si la limitación es consecuencia del derecho de los demás o por consideraciones de la seguridad y el bienestar colectivo, como por ejemplo lo estipulado en el artículo 29 en relación la su familia.

En relación con las obligaciones asumidas por los Estados se puede señalar: Tienen el deber de reconocer los derechos, deberes y libertades determinadas en la Carta y de adoptar las medidas legislativas o de otro tipo para dar efectividad a los mismos. (Artículo 1); la primera obligación se complementa con el deber que tienen los Estados de presentar informes cada dos años sobre las medidas aplicadas para hacer efectivo su compromiso. (Artículo 62). Igualmente, el artículo 25 obliga a los Estados a promocionar y asegurar, por medio de la educación y la difusión, el respeto a los derechos y libertades enunciados en la Carta; otra de las obligaciones es la determinada en el artículo 26, en el sentido de garantizar la existencia de un poder judicial autónomo e independiente, y de permitir el establecimiento de instituciones nacionales apropiadas para la promoción y la protección de los derechos y garantías establecidas en la Carta.

Una característica que la diferencia con la Convención Europea y la Americana es la inexistencia de un tribunal de derechos humanos, contando sólo con la Comisión de los Derechos del Hombre y de los Pueblos.

En relación con la Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, es la encargada de promover los derechos humanos y de los pueblos y de asegurar su protección en África. Esa función de promoción es bastante amplia y está determinada en el artículo 45, la cual va desde realizar estudios de investigación, emitir opiniones y hacer recomendaciones a los Gobiernos, hasta formular y fijar reglas y principios dirigidos a resolver los problemas jurídicos, que sirvan de base para la elaboración de textos legislativos por parte de los gobiernos africanos.

Por último, en cuanto al sistema de comunicaciones dirigidas por individuos u organizaciones distintas a los Estados Parte, es conveniente tener en cuenta que este sistema de petición individual no autoriza a la Comisión a conocer de casos particulares de violación de los derechos consagrados en la Carta; este permite a la Comisión actuar únicamente cuando existan casos especiales, que revelen una grave o masiva violación de los derechos del hombre y de los pueblos. En pocas palabras, una comunicación privada que no revele una serie de graves o masivas violaciones de estos derechos, no es causa para que la Comisión pueda actuar. Aunque, si la queja o comunicación revela tal situación, la Comisión estará en la capacidad de investigar sólo si la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno lo solicita. (Artículo 58.2).

Existe un Protocolo Facultativo que establece la Corte Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos. Adoptado el 9 de junio de 1998, entró en vigencia el 25 de enero de 2004. A pesar, de haber entrado en vigencia no ha sido constituido el Tribunal por existir una resolución de la Organización de la Unidad Africana de fusionarlo con la Corte de Justicia de la Unión. El problema radica en que el Protocolo que establece la Corte de Justicia, adoptado el 11 de julio de 2003, no ha alcanzado el número de ratificaciones necesarias para entrar en vigor.²⁷ En cuantía menos que anteriores sistemas analizados el sistema africano contiene una serie de tratados que a continuación se explican.

3.-2.4.1- INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL SISTEMA AFRICANO

- Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos “Carta de Banjul”
- Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño
- Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el establecimiento de una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
- Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África
- Protocolo de la Corte de Justicia de la Unión Africana
- Unión Africana sobre la prevención y lucha contra la corrupción
- Unión Africana de no agresión y el Pacto de Defensa Común

27 <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1297.pdf>

- Convención Africana sobre la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales
- Protocolo relativo a la constitución del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana
- África nuclear Zona Libre de Armas (Tratado de Pelindaba)
- Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Africana
- Convención de la OUA que regula los aspectos propios de los problemas de los refugiados en África
- Convención General sobre los Privilegios e Inmunidades de la Organización de Unidad Africana
- Protocolo Adicional a la Convención General de la OUA sobre los privilegios e inmunidades
- Convención de la OUA sobre la prevención y lucha contra el terrorismo
- Protocolo a la Convención de la OUA sobre la prevención y lucha contra el terrorismo
- Carta Africana de la Juventud
- Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad
- Protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos

3.3.- CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LATINOAMÉRICA

Como se observó el derecho internacional ha calado en el constitucionalismo latinoamericano siendo el reconocimiento y protección de los derechos humanos el tópico en el cual se patentiza esta evolución de una manera más palpable; desde los preámbulos donde se exponen preciosos anhelos los cuales son incorporados al articulado constitucional formando hoy lo que se conoce como el bloque de la constitucionalidad,²⁸ pero este bloque, será quebradizo si los esfuerzos realizados en los procesos constituyentes se derogan por la inaplicabilidad de las decisiones de los tribunales o cortes competentes en materia de derechos humanos; una cosa es su establecimiento en las diferentes Cartas Políticas y otra es lo que llama Zagrebelsky (2007) el derecho viviente; (...) o sea, el derecho que efectivamente rige, no es el que está escrito en los textos, sino el que resulta del impacto entre la norma en abstracto y sus condiciones reales de funcionamiento” (...) (p.122).

En Latinoamérica la evolución de la protección de los derechos humanos ha sido paulatina hasta darle una preeminencia al reconocimiento y garantía

28 La noción de bloque de constitucionalidad es de origen francés y se la entiende como integradora del preámbulo de la Constitución francesa de 1946 la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, los principios fundamentales reconocidos por las leyes y los principios políticos económicos y sociales. Es un complejo sistema de fuentes constitucionales más orientado a los derechos fundamentales y libertades públicas y que tiene entre sus antecedentes la decisión del Consejo Constitucional francés sobre la libertad de asociación donde anulo una disposición legislativa por contravenir la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 (D. 51DC de 27 de diciembre de 1973).

como resultado del desarrollo político y social de los Estados que la conforman; de allí que algunas constituciones han consagrado estos, así, por ejemplo:

3.3.1.- CONSTITUCIÓN DE ARGENTINA

Le concede en el artículo 75 ordinal 22 jerarquía constitucional a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; a la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, a la Convención Internacional sobre la Prevención y la sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación la contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos de l Niño; los cuales complementan la protección nacional otorgada. Los anteriores tratados sólo pueden ser denunciados por el Poder Ejecutivo previa aprobación por las dos terceras partes por ambas cámaras legislativas.²⁹ Este texto constitucional no sólo concede categoría constitucional a la protección de los derechos humanos, sino además incluye prácticamente un catálogo de instrumentos a los cuales le otorga esta relevancia.

3.3.2.- CONSTITUCIÓN DE BOLIVIA

En el Artículo 13, I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. (...) IV Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. En forma casi idéntica se reproduce este artículo en el 256 ubicado en el Título VIII al tratar sobre la relaciones internacionales del país y señala de esta manera que: Artículo 256. I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables.³⁰

29 Op. Cit, 100-101

30 <http://libresdelsur.org.ar/archivo/IMG/pdf/NUEVA.pdf>.

3.3.3.- CONSTITUCIÓN DE BRASIL

Esta Constitución desde sus principios dispone como uno de sus fundamentos (Artículo 1 III) la “dignidad de la persona humana”, en artículo 4, II señala como uno de sus principios “prevalencia de los derechos humanos” y en las disposiciones transitorias en su artículo 7 contundentemente se propone “Brasil propugnará la formación de un Tribunal Internacional de derechos humanos”.³¹

No hay que olvidar que Brasil al igual que muchos países de Latinoamérica, también transitó por un período de inestabilidad política en que las férreas dictaduras gobernaron gran parte del siglo pasado, por eso no es de extrañar estas disposiciones que categóricamente exaltan la protección de los derechos humanos.

3.3.4.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

En su artículo 5 sin más, reconoce la “primacía de los derechos inalienables de la persona”, ratificando esta prevalencia en el orden interno de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso cuando sean limitados en los estados de excepción (Artículo 93)³²; en este sentido la Corte constitucional colombiana prontamente al ser sancionada la vigente Constitución se pronunció sobre la aplicación de normas supranacionales en el orden interno colombiano en las sentencias T-409 de 1992 M.P’s: Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y C- 574-92 MP: Ciro Angarita Barón; se estableció que los convenios sobre derecho internacional humanitario tienen carácter prevalente sobre la legislación nacional³³. A partir, de la mencionada jurisprudencia, la Corte Constitucional comenzó a interpretar el inciso segundo del artículo 93 de la Carta como la norma que disponía la prevalencia de los tratados o convenios internacionales en el orden jurídico interno, siempre y cuando dichas normas hubiesen sido integradas en la normatividad colombiana a través de la ratificación del Estado, previo análisis de constitucionalidad.³⁴

3.3.5.- CONSTITUCIÓN DE COSTA RICA

Es conocida la anuencia de la República de Costa Rica en coadyuvar al orden internacional a solidificarse, no en vano en suelo costarricense funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos; al ex presidente Oscar Arias, le concedieron el premio Nobel de la Paz en 1987 por sus esfuerzos en Pro de

31 Op. cit, pp. 147 y 221

32 Op. Cit. 239 y 249

33 Sentencia C-574-92 MP: Ciro Angarita Barón.

34 Sentencia C-578-95 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz: Los principios del derecho internacional humanitario plasmados en los Convenios de Ginebra y en sus dos Protocolos, por el hecho de constituir un catálogo ético mínimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o internacional, ampliamente aceptado por la comunidad internacional, hacen parte del ius cogens o derecho consuetudinario de los pueblos

la pacificación de Centroamérica y en su discurso al recibir el galardón dijo:

(...)He dedicado mi vida a construir el sueño de una América Latina más pacífica, más libre, más próspera, más democrática, más acorde con la idea que me inculcó la maestra. Aún hoy sigo construyendo esa visión: una América Latina en donde el poder no se concentre, sino que se distribuya; en donde la ley no se irrespete, sino que se fortalezca; en donde los aparatos estatales no se ahoguen, sino que se vuelvan eficaces; en donde el militarismo no se atice, sino que ceda campo al desarrollo humano. Esa América Latina es posible. Existe en cada uno de ustedes. Hoy les pido que, como yo, se gradúen en sueños y despierten a esa América que espera más allá del esfuerzo y el trabajo.³⁵

La Constitución costarricense posee un amplio catálogo de derechos humanos protegidos las cuales versan desde los derechos individuales, sociales y transgeneracionales; la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se propone como misión: "Proteger la dignidad y los derechos del ser humano en todas sus formas, garantizando la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional y Comunitario de los Derechos Humanos vigentes en la República".³⁶

3.3.6.- CONSTITUCIÓN DE CHILE

Esta Constitución una vez aprobada mediante plebiscito convocado el 11 de agosto de 1980, allana su soberanía al reconocer como límite "el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana"; imponiendo como un deber a "los órganos del Estado respetar y promover tales derechos", garantizados no sólo por la Constitución sino más aún por "los tratados internacionales ratificados por Chile"³⁷. Sin embargo, aquí se debe destacar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Olmedo Bustos contra Chile por la censura impuesta a la proyección de la película "La Última Tentación de Cristo"; "En la reforma constitucional de 1989 se optó por no presentar modificaciones a todos los artículos de la Constitución Política de 1980 que implicaren dar una mayor extensión a los derechos humanos en ella consagrados y lo que se hizo fue establecer una norma vinculante para todos los órganos del Estado (artículo 5 inciso segundo) que exigiera la garantía y protección de todos los derechos humanos garantizados en la propia Constitución Política y en los tratados de derechos esenciales de la persona humana ratificados y vigentes en Chile", en consecuencia la Corte se pronunció decidiendo que:

En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. Esta

35 <http://www.forodemocratico.org/profiles/blogs/discurso-del-dr-oscar-arias>

36 <http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/>

37 Op.cit. 363

norma es universalmente aceptada, con respaldo jurisprudencial. La Convención Americana establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en ella consagrados. Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio del *effet utile*). Esto significa que el Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 2 de la Convención. Dichas medidas sólo son efectivas cuando el Estado adapta su actuación a la normativa de protección de la Convención. (párr. 87)³⁸

El anterior fallo generó cambios en el derecho interno de Chile en acatamiento del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

3.3.7.- CONSTITUCIÓN DE EL SALVADOR

Otro de los países Centroamericanos que padeció un cruento conflicto bélico interno en la década de los ochenta, consagra sin embargo paradójicamente en el artículo 1 de su texto político el reconocimiento “a la persona humana como origen y el fin de la actividad del Estado”; de esta manera expone lo que a posteriori desarrolla en la consagración del derecho a la vida, a la libertad al trabajo, a la propiedad (Art. 2), es decir derechos individuales; sociales como la protección a la familia (Art. 32), a la cultura y a la cultura (Art. 53); derechos políticos tales como el derecho a ejercer el sufragio, asociarse en partidos políticos y optar a cargos públicos (Art. 72).

Aunque, no explícita que rango jerárquico tiene la afirmación de los derechos humanos en el orden interno, el Protocolo por el cual se reafirman los derechos económicos, sociales y culturales lleva el nombre de esta República.³⁹

3.3.8.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Al sancionar su Carta Política el pueblo de Guatemala lo hace decidido (...) “a impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernadores procedan con absoluto apego al Derecho”. (Preámbulo), ratificando su preeminencia en el artículo 46 cuando establece como principio general que respecto a la materia de los derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen esta distinción de preeminencia. Igualmente, la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ser ejercida mediante la simple denuncia sin formalismos ni caución alguna (Art. 45).

38 <http://www.derechos.org/nizkor/doc/tentacion.html>

39 <http://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos4.htm>. A-52: Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” (adoptado en San Salvador, el Salvador, el 17 de noviembre de 1988).

3.3.9.- CONSTITUCIÓN DE HONDURAS

Con similitud a la República de El Salvador; se establece como un fin supremo de la sociedad y del Estado el respeto y protección de la persona humana, además de consagrar la inviolabilidad de la dignidad humana (Art. 59).

Durante el conflicto armado sucedido en varios países centroamericanos sucedieron flagrantes violaciones a los derechos humanos (desapariciones forzadas, secuestros, torturas, tratos crueles e inhumanos etc) tal como lo dice Buergenthal (2008) (...) “la mayoría de los países de América Latina habían caído en manos de regímenes militares y dictadores civiles que cometían violaciones a los derechos humanos. (p. 246), que motivaron la resolución ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de varios casos emblemáticos.⁴⁰ Estos casos han contribuido a formar una doctrina sólida en materia de violación de derechos humanos, que a su vez coadyuva implícitamente al cumplimiento y garantía de los derechos pautados en la convención Americana de Derechos Humanos.

3.3.10.- CONSTITUCIÓN DEL PARAGUAY

“La República del Paraguay, en sus relaciones internacionales, acepta el derecho internacional y se ajusta a los siguientes principios (...) la protección internacional de los derechos humanos (Art. 143 numeral 5), admitiendo en el artículo 145 un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos (...)

3.3.11.- CONSTITUCIÓN DEL PERÚ

A semejanza de la Carta Magna Paraguaya, también el Perú se circunscribe en la onda de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos (Art. 44); teniendo el Congreso la atribución o competencia de ratificar los tratados que versen sobre esta materia (Art.56).

En Perú también durante el mandato de Alberto Fujimori se estima que proliferó la vulneración pasando a los anales de la historia el caso María Elena Loayza, en el cual por vez primera una Corte Internacional encargada de juzgar casos violatorios a la dignidad humana se pronunciaba sobre el “*proyecto de vida*”;⁴¹ criterio ratificado posteriormente en el fallo Villagrán

40 Caso: Velásquez Rodríguez Vs. Honduras Sentencia de 29 de julio de 1988; Caso: Godínez Cruz Vs. Honduras. Sentencia de 20 de enero de 1989; Caso: Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras Sentencia de 7 de junio de 2003; Caso: de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia del 8 de marzo de 1998; Caso: Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000; Caso: Myrna Mack Chang Vs. Guatemala Sentencia de 25 de noviembre de 2003; Caso: Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia de 27 de noviembre de 2003; Caso: de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Sentencia 01 de Marzo de 2005.

41 Caso: Loayza Tamayo Vs. Perú, Sentencia de 27 de noviembre de 1998 (Reparaciones y Costas). Por lo que respecta a la reclamación de daño al “proyecto de vida”, conviene manifestar que este concepto ha sido materia de análisis por parte de la doctrina y la

Morales.⁴²

Otro caso que marcó un hito fue el caso Castillo Petruzzi;⁴³ El 30 de mayo de 1999 la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el fondo del caso *Castillo Petruzzi y otros*. Este caso se refiere a cuatro ciudadanos chilenos que fueron juzgados, declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua por el delito de “traición a la patria” por una corte militar “sin rostro”. La Corte concluyó, *inter alia*, que se habían cometido numerosas violaciones del derecho al debido proceso y ordenó al Perú que volviera a juzgar a los ciudadanos chilenos ante la justicia ordinaria conforme a las garantías del debido proceso. La Corte ordenó además al Estado que adoptara las medidas necesarias para modificar las normas internas que, conforme a las conclusiones de la sentencia, resultaban violatorias de la Convención, y ordenó el pago de US\$10.000, o su equivalente en moneda nacional, a los familiares de los ciudadanos chilenos, como compensación por los gastos incurridos durante el trámite del caso.

El 11 de junio de 1999 el Supremo Consejo de Justicia Militar del Perú dictó una resolución mediante la cual declaró “inejecutable” la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso *Castillo Petruzzi*. El 14 de junio de 1999 la Corte Suprema del Perú dictó una resolución similar, declarando “inejecutable” la sentencia de reparaciones de la Corte Interamericana en el caso *Loayza*. Posteriormente, el 1° de julio de 1999, la Representante Permanente del Perú ante la OEA, Embajadora Beatriz M. Ramacciotti, dirigió una nota al Secretario General, César Gaviria, mediante la cual el Gobierno peruano informó que no cumpliría con las sentencias de la Corte en estos casos. El 9 de julio de 1999 Perú presentó ante la Secretaría General de la OEA la notificación de “retiro” de su declaración de aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. El Estado indicó que este “retiro” tendría “efecto inmediato” y se aplicaría a todos los casos en los cuales el Perú no hubiese contestado la demanda incoada ante la Corte.⁴⁴

El criterio anterior fue modificado una vez advenido al Poder Ejecutivo Alejandro Toledo, produciéndose los cambios previsibles en las demás ramas del poder; se produjo la recepción de normas de carácter internacional y el Tribunal Constitucional Pleno Jurisdiccional de Perú en la decisión 00007-2007-PI/TC ante una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el

jurisprudencia recientes. Se trata de una noción distinta del “daño emergente” y el “lucro cesante”. Ciertamente no corresponde a la afectación patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos, como sucede en el “daño emergente”. Por lo que hace al “lucro cesante”, corresponde señalar que mientras éste se refiere en forma exclusiva a la pérdida de ingresos económicos futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos indicadores mensurables y objetivos, el denominado “proyecto de vida” atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas (párr. 147)

42 Caso: de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 1999

43 Caso: Castillo Petruzzi y otros Vs. Sentencia de 30 de mayo de 1999

44 <http://www.cidh.org>

Colegio de Abogados del Callao contra el artículo único de la Ley N° 28642, modificatoria del artículo 5°, numeral 8 de la Ley N° 28237 del Código Procesal Constitucional, interpretó y decidió con fundamento a normas de los tratados internacionales sobre derechos humanos y el Derecho Interno, que de acuerdo al artículo 55 de la constitución; *“Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”*.

Recalcando el Tribunal su reiteración de criterio sustentado en el Fundamento N° 22 de la sentencia recaída en el Expediente N° 0047-2004-AI/TC (Caso: José Claver Nina-Quispe Hernández, en representación del gobierno Regional de San Martín), el rango constitucional de los tratados de derechos humanos señalando:

Nuestro sistema de fuentes normativas reconoce que los tratados de derechos humanos sirven para interpretar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Por tanto, tales tratados constituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y libertades. Estos tratados no sólo son incorporados a nuestro derecho nacional –conforme al artículo 55 de la constitución – sino que, además por mandato de ella misma, son incorporados a través de la recepción interpretativa”.⁴⁵

3.3.12.- CONSTITUCIÓN REPÚBLICA DOMINICANA

En su artículo 8 reconoce que la protección efectiva de los derechos de la persona humana es una fin del Estado, consagrando a su vez el principio de progresividad, el cual se debe cumplir dentro de un orden de libertad individual y de justicia social; lo anterior es compatible de una manera general con el orden público y el bienestar y por supuesto los derechos de todos.

3.3.13.- CONSTITUCIÓN DE VENEZUELA

La supremacía constitucional impregnada de valores y principios, se convierten en el alma de los pueblos; Venezuela tiene una historia republicana con sólidas tradiciones, a pesar de los vaivenes de muchos gobiernos ha sido un país con anhelo de consolidarse como (...) *“un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos”* ⁴⁶(...) También en el artículo 3 propone como uno de sus fines esenciales la *defensa y desarrollo de la persona humana y el respeto a su dignidad*; siendo que en su artículo 7 estipula que la *Constitución es la Norma Suprema*; la República ha entrado en el camino de la constitucionalización de los derechos humanos desde sus normas de apertura.

De allí, deviene la importancia que se le debe a los artículos subsiguientes como lo son los artículos: 19, 23, 29, 30, 31 y 49. Se está ante un conjunto

45 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02730-2006-AA%20Aclaracion.html>

46 Art. 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. G.O Extraordinaria N° 5.908

de normas que guardan entre sí estrecha correspondencia cuyo significado estriba en definir y precisar, fundamentándose en valores y principios la estructura de la convivencia que se aspira a lograr. Por lo tanto hay que ponderar, debidamente, estas normas básicas que forma las articulaciones constitucionales como conexiones sistemáticas con sentido entre las disposiciones conforme a su ratio".⁴⁷

Estos artículos incorporan al ordenamiento constitucional venezolano normas que venían transitando desde tiempo atrás en el contexto internacional, en el artículo 23 se le otorga rango constitucional a los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, por supuesto siempre que hayan sido ratificados por la República; además la aplicación del tratado, pacto o convención se le dará preferencia cuando contenga normas más favorables a la persona para el pleno goce de sus derechos; es decir en caso de colisión emerge el principio *pro homine* o *pro libertate*. Así las cosas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional se pronunció en sentencia N° 328 de fecha 09 de marzo de 2001 en los siguientes términos:

(...) "En este contexto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Venezuela (G.O. N° 31.256 de fecha 14-06-77), en su artículo 8 numerales 1 y 2, establece lo siguiente:

1.- *Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (omissis).*

En este contexto, la Sala precisa, que conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Venezuela, todo juicio debe ser llevado ante un tribunal de instancia, cuyo fallo pueda contar con una instancia revisora superior (principio de la doble instancia). De lo anterior se observa, que el citado Convenio, contiene disposiciones más favorables al goce y ejercicio del derecho consagrado en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, como lo es, recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, disposición legal con base a la cual fue declarada sin lugar la acción de amparo interpuesta...resulta incompatible con el artículo 8, numerales 1 y 2, literal "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual es de aplicación "*inmediata y directa*" conforme al citado artículo 23 de Nuestro Texto Fundamental. Siendo ello así, resulta forzoso para la Sala, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, según el cual es obligación del juez inaplicar las leyes u otras normas jurídicas cuando éstas son incompatibles con la Constitución" (...).

47 Pablo Lucas, Verdú: Teoría General de las Articulaciones Constitucionales Editorial Dykinson 1998, pág. 27.

Si, en el 2001 la Sala Constitucional del Máximo Tribunal estimaba que (...) “la Convención Americana de Derechos Humanos...es de aplicación *“inmediata y directa”* conforme al citado artículo 23 de Nuestro Texto Fundamental (...); posteriormente en el fallo 1942 (TSJ/SC de fecha 15 de julio de 2003), con ocasión de pronunciarse acerca de un recurso de nulidad por inconstitucionalidad de varios artículos del Código Penal, que presumiblemente a decir del recurrente vulneraban la libertad de expresión y contravenían el valor obligatorio de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se decidió que tantos los informes como las Resoluciones de los mencionados órganos del sistema interamericano deben estar conformes a la Constitución de Venezuela según lo determine el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de acuerdo al artículo 335 constitucional; las decisiones de éstos órganos internacionales de protección de los derechos humanos no son de obligatorio cumplimiento y carecen de aplicación o son inaplicables si violan la Constitución o no se hayan agotado los recursos internos.

“Al incorporarse las normas sustantivas sobre derechos humanos, contenidas en los Convenios, Pactos y Tratados Internacionales a la jerarquía constitucional, el máximo y último intérprete de ellas, a los efectos del derecho interno es esta Sala Constitucional, que determina el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales (artículo 335 constitucional), entre las cuales se encuentran las de los Tratados, Pactos y Convenciones suscritos y ratificados legalmente por Venezuela, relativos a derechos humanos.

Resulta así que es la Sala Constitucional quien determina cuáles normas sobre derechos humanos de esos tratados, pactos y convenios, prevalecen en el orden interno; al igual que cuáles derechos humanos no contemplados en los citados instrumentos internacionales tienen vigencia en Venezuela. Esta competencia de la Sala Constitucional en la materia, que emana de la Carta Fundamental, no puede quedar disminuida por normas de carácter adjetivo contenidas en Tratados ni en otros textos Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por el país, que permitan a los Estados partes del Tratado consultar a organismos internacionales acerca de la interpretación de los derechos referidos en la Convención o Pacto, como se establece en el artículo 64 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, ya que, de ello ser posible, se estaría ante una fa de enmienda constitucional en esta materia, sin que se cumplan los trámites para ello, al disminuir la competencia de la Sala Constitucional y trasladarla a entes multinacionales o transnacionales (internacionales), quienes harían interpretaciones vinculantes”⁴⁸.

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José la en su artículo 62, 3 corresponde a la Corte Interamericana como órgano jurisdiccional interamericano interpretar y desentrañar, con carácter vinculante, el alcance y sentido de los derechos consagrados en la Convención

48 www.tsj.gov.ve. (TSJ/SC de fecha 15 de julio de 2003),

y los posibles incumplimientos por los Estados signatarios; sin embargo de acuerdo al fallo citado la Sala Constitucional tiene prelación en el orden interno en ejercicio del control concentrado. (...) las sentencias de la justicia supranacional o transnacional para ser ejecutadas dentro del Estado, tendrán que adaptarse a su Constitución. Pretender en el país lo contrario sería que Venezuela renunciara a la soberanía (...).⁴⁹

Continuando con la sentencia esta también dejó sentado que:

(...) Por otra parte, dado que la sociedad internacional como sistema de Estados soberanos carece de órgano jurisdiccional central omnicompetente, las decisiones de los órganos judiciales internacionales existentes, institucionales o ad hoc (arbitrales), de carácter sectorial, para su ejecución en el Estado destinatario, no pueden obviar impunemente la soberanía nacional de estos. Esto significa que, para su ejecución, los fallos deben atravesar el sistema jurídico interno que, sólo en el caso de que la sentencia no vulnere principios y normas constitucionales, podría darle pasavante y proceder a su cumplimiento. En caso de menoscabo de la Constitución, es posible sostener que, aun en esta hipótesis, no hay lugar a responsabilidad internacional por la inejecución del fallo, por cuanto éste atenta contra uno de los principios existenciales del orden internacional, como es el debido respeto a la soberanía estatal (...)

Lo que pudiera ser interpretado como una contradicción concatenando este dictamen con el artículo 2 de la Convención Americana, por cuanto de acuerdo a su teleología son los Estados partes o signatarios quienes en concordancia con el artículo 1 (...) “se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos”; continúa esta decisión exponiendo un criterio que a decir de Faúndez Ledesma (2003) al comentarla señaló en su momento (...) resulta sorprendente que, en una sentencia del más alto tribunal de la República, todavía se recurra a la noción petrificada de soberanía absoluta enunciada (...) hace más de 400 años. Asimismo, llama la atención que este tribunal asuma que, desde su fundación con el nacimiento del Estado territorial moderno, el sistema internacional actual ha permanecido invariable, y que no ha experimentado ninguna transformación; para el sentenciador, el sistema internacional se ha mantenido estático (...) la noción de soberanía absoluta, propia de la época de las monarquías absolutas, hace mucho tiempo que ya ha sido superada, para ser sustituida por el principio de la “igualdad” “soberana” de los Estados, entendida en términos de independencia política de otros Estados pero de ninguna manera como expresión de la ausencia de normas o de la anarquía en que puedan operar los Estados en el ámbito internacional” (pp.189 y ss). Se vislumbra en esta decisión de la Sala Constitucional, lo que sucedería a posteriori con fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; como por ejemplo la sentencia N° 1265/2008, la cual estableció que en caso de evidenciarse una contradicción entre la Constitución y una

49 Op. cit

convención o tratado internacional, “*deben prevalecer las normas constitucionales que privilegien el interés general y el bien común, debiendo aplicarse las disposiciones que privilegien los intereses colectivos... (...) sobre los intereses particulares (...)*”, se advirtió en el referido fallo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pretendía que el Estado venezolano indemnizara a los ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz, a quienes califica de “*víctimas*” por haber presuntamente sido violados sus derechos individuales.

Estimando la Sala Constitucional que la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de agosto de 2008, afectaría principios y valores esenciales del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y pudiera conllevar a un caos institucional en el marco del sistema de justicia, al pretender modificar la autonomía del Poder Judicial constitucionalmente previsto y el sistema disciplinario instaurado legislativamente. Igualmente, con base en el mismo principio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se solicitó al Ejecutivo Nacional proceder a denunciar la Convención, ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la decisión in comento.

Otorgarle un pasavante⁵⁰ a las sentencias de los órganos internacionales, a los que se les ha concedido reconocimiento al suscribir y ratificar los tratados que lo rigen; en consonancia con los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena,⁵¹ pareciera una dicotomía entre lo consagrado en el Texto constitucional y las decisiones jurisdiccionales.

Decisiones de este tenor fueron objeto de análisis por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe del 30 de diciembre de 2009 relacionado sobre “La Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”.

En el mismo la Comisión explana enfáticamente como debe ser interpretado el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, criterio que esta a su vez compaginado con el discernimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir ambos organismos integrantes del sistema de protección de los derechos humanos en Latinoamérica, no tienen divergencias y quien alegue mejor razonamiento a este precedente debe desmontar todo un sistema que poco a poco ha ido sentando unas bases sólidas en reconocimiento y defensa de los derechos humanos; por lo que:

(...) Al respecto, la CIDH reitera que las únicas restricciones admisibles para regular el ejercicio y goce de los derechos políticos son las expresamente establecidas en el inciso 2 del artículo 23 de

50 Pasavante: (De pasar y avante) documento que, con carácter provisional, da un cónsul al buque mercante adquirido en el extranjero, para que pueda ir a abanderarse y matricularse en un puerto español

51 Artículo 26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Artículo 27. "El derecho interno y la observancia de los tratados". Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.

la Convención Americana. Los Estados deben abstenerse de emitir leyes que establezcan restricciones más allá de las señaladas en este artículo. De forma tal que son inadmisibles las restricciones a los derechos políticos que no estén autorizadas en el inciso 2 del artículo 23, aún cuando, a juicio de los tribunales internos, dichas restricciones se fundamenten en razones de interés general, seguridad de todos y en las justas exigencias del bien común (...)

Entre sus conclusiones la Comisión sin ambages dice que:

En general, el Estado de Venezuela ha asumido una actitud de rechazo hacia las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos bajo el argumento de que contravienen la soberanía nacional. Sobre este aspecto, la Comisión enfatiza que, en virtud del principio de buena fe, consagrado en el artículo 31.1 de la Convención de Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si trata de derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones y decisiones de sus órganos de protección como son la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, y además “ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 2 de la Convención. En virtud de lo anterior, la CIDH reitera al Estado su deber de cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos libremente asumidas bajo la Convención Americana y demás instrumentos jurídicos aplicables y exhorta a Venezuela a dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones contenidas en el presente Informe a fin de contribuir al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto democrático.”⁵²

La adaptación de los sistemas jurídicos internos en acatamiento del artículo 2 de la Convención donde se pauta la obligación que tienen los Estados Partes de adaptar su ordenamiento jurídico para ser efectivos tales derechos; es tarea de los Estados Contratantes en un sistema de integración, en la praxis los tratados, pactos, convenios, etc. se convertirán en nugatorios si no se cumple con los propósitos estatuidos, Cançado Trindade (1996), (...) sostiene que en materia de derechos humanos debe aplicarse el principio de la primacía de la norma más favorable a las víctimas, de forma que en caso de conflicto de normas debe prevalecer la norma más beneficiosa al ser humano (...) (p. 50) Este criterio es cónsono con, el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos humanos prevé que: “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de

52 www.cidh.org/default.htm

dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”.

Las normas internacionales en materia de derechos humanos es complementaria a la normativa constitucional interna; el hecho de ser en un determinado caso más beneficiosa no implica que la normativa interna sea nula.

La norma más favorable siempre será la más amplia y nunca la restrictiva. Sin embargo como expresa en el voto razonado del juez Sergio García Ramírez para la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile del 19 de septiembre de 2006, señala que: (...) “los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el (...) artículo 29 (de la convención americana), así como las establecidas en la convención de Viena sobre el derecho de los tratados” (párr.2).

En la recepción de normas provenientes del derecho internacional influye el tratamiento que le otorgue el Estado a sus relaciones internacionales, debiéndose analizar y describir como en varias constituciones latinoamericanas se estatuyen y proyectan las relaciones internacionales.

3.4.- TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN LATINOAMÉRICA

Brasil a excepción de otros países no tuvo batallas teñidas de sangre par a lograr su escisión de Portugal; sin embargo se mantiene a la cabeza en América del Sur con un alto índice de desarrollo,⁵³ en el artículo 4 de su Carta Magna⁵⁴ señala en su Parágrafo Único: “La República Federativa de Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con vistas a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones”; Igualmente la novel constitución del Ecuador en su artículo 416 sostiene que: Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderá a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia: (...) 2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos. (...) 10. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de bloques económicos y políticos regionales, y el fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural. 11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región andina, de América del Sur y

53 http://www.elpais.com/graficos/internacional/futuro/visto/latinoamericanos/elpgaint/20100701elpeuint_1/Ges/

54 Luis Ortiz Alvarez y Jacqueline Lejarza. *Constituciones Latinoamericanas*. Caracas. Academia de Ciencias Políticas. 1997. p. 147

de Latinoamérica.⁵⁵ El Ecuador se alinea en el afán integracionista que gradualmente por lo menos en los textos constitucionales se va impregnando Latinoamérica.

A tenor de lo anterior, también Guatemala ha consagrado en su texto constitucional en el artículo 150 este anhelo de unidad comunitaria como una forma de progreso y desarrollo señalando lo siguiente: “Guatemala, como parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad (...) artículo 151 “El estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos estados, cuyo desarrollo económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala”⁵⁶ (...) . Nicaragua, también se inserta en este asunto en el artículo 9 constitucional, señalando al respecto: “ Nicaragua defiende firmemente la unidad centroamericana, apoya y promueve todos los esfuerzos para lograr la integración política y económica y la cooperación en América Central, así como los esfuerzos por establecer y preservar la paz en la región.

Nicaragua aspira a la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe” (...).⁵⁷ República Dominicana al reconocer la aplicación del derecho internacional, también (...) “se pronuncia a favor de la solidaridad económica de los países de América “(...).⁵⁸ La República del Uruguay en su artículo 6 de la misma manera explana que: (...) “procurará la integración total y económica de los Estados Latinoamericanos”⁵⁹ (...).

En Venezuela desde el preámbulo se desea lograr este anhelo aún inconcluso, señalando que aspira a (...) Promover la cooperación pacífica entre las naciones e impulsar y consolidar la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos (...) desglosando luego una serie de preceptos como el artículo 15 referidos a la integración y al respecto dice: “El Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración”; en conexión con el anterior y en aras de propiciar la integración en el Artículo 152 se pauta: “Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales”; llegando a un culmen

55 <http://www.diarioportada.com>

56 Op. cit. 504

57 Op. cit. 659

58 Op. cit. 823

59 Op. cit. 845

loable de acuerdo a las pautas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados⁶⁰ cuando en el Artículo 153 se dice: “La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región (...)

La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones. (...) Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna”.

Proclamando en artículo en el Artículo 155 el reconocimiento a las vías pacifistas en la resolución de los conflictos, cuando expresa: “En los tratados, convenios y acuerdos internacionales que la República celebre, se insertará una cláusula por la cual las partes se obliguen a resolver por las vías pacíficas reconocidas en el derecho internacional”.

Pero, aunque en la práctica el derecho comunitario en Latinoamérica no sea aún palpable no se debe dejar de mirar las bases, América Latina ya ha tenido experiencia histórica de aspirar a una integración sustentada en los lazos comunes que la unen. En la Constitución del 06 de mayo de 1821 adoptada en Cúcuta (Colombia) vigente hasta 1830 Venezuela, Ecuador y Colombia contando con Panamá avizoraban a una unión supraconstitucional; sin embargo la sombra de la inconsistencia política que pareciera no abandonar a la región continuarían posponiendo los sueños de integración. “Dos tendencias contradictorias dividieron en seguida a los diputados, acerca del lazo constitucional que debía unir a las Provincias de Venezuela con las de Nueva Granada”.⁶¹ Con fundamentos y nexos comunes las provincias en aquel entonces que luchaban por su independencia y hoy Estados soberanos, continúan propiciando y en algunos casos consolidando tratados que los van conectando desde el aspecto económico hasta lo cultural y quizás bajo las condiciones propicias se culmine en lo político.

De allí, se puede afirmar con Palomares Lerma (2004) “En los nuevos contextos políticos y económicos nacionales e internacionales, se ha vuelto imprescindible articular las políticas internas de desarrollo y modernización con los objetivos e instrumentos de las políticas exteriores. Las ‘agendas’ de ambas políticas, tal como se evidencia en materia de relaciones políticas, comerciales, financieras, o de consolidación de los esquemas de integración regional, se mezclan y se retroalimentan constantemente” (p.24)

De esta forma dentro del sistema internacional reviste suma importancia la manifestación expresa de la voluntad de los Estados de aceptación y reconocimiento de los Derechos en instrumentos internacionales, ello permite su efectiva tutela a través de normativas preventivas y coercitivas en caso de violación.

60 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados UN Doc A/CONF. 39/27 (1969).

61 José Gil Fortoul. Historia Constitucional d Venezuela. Caracas. Editorial Las Novedades. 1942. p. 428

3.5.- JERARQUÍA DE LOS TRATADOS EN LAS CONSTITUCIONES LATINOAMERICANA

Se puede observar en el anterior análisis como los países latinoamericanos conciben en sus constituciones diferentes formas de incorporar al ordenamiento jurídico interno el orden normativo internacional; si bien en su mayoría propugnan en sus relaciones internacionales y en la protección de los derechos humanos el acatamiento a los tratados, convenciones o pactos, la recepción de normas internacionales recibe diverso tratamiento jerárquico, pudiéndose observar los siguientes modos:

a. Supraconstitucional; los tratados en especial los que receptan los derechos humanos por disposición expresa de la propia Constitución, tienen una jerarquía superior a ella. Disposición de la misma Constitución los

b. Constitucional; también por disposición constitucional los tratados tienen una jerarquía igual a la propia Constitución.

Supralegal; esta forma adoptada en las constituciones considera a los tratados internacionales sobre derechos humanos u otra materia por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes internas.

c. Legal; los tratados internacionales sean de la materia que sea, tienen un rango inferior a la Constitución e igual a la ley interna.

Key Cantor (2007) citando a Isaac Guy, advierte que: “El derecho internacional no regula, por él mismo, las conducciones en las cuales las normas contenidas en los tratados deban integrarse en el orden jurídico de los Estados para ser aplicadas allí por sus órganos jurisdiccionales; deja esa materia en manos de que cada Estado que la regula, por lo tanto, soberanamente, en función de la concepción de las relaciones entre el Derecho internacional y el Derecho interno a la que se sume”. (p.136). Entonces, dependerá como cada asuma y ponga en práctica los tratados que suscriba y ratifique.

También se puede apreciar la influencia de del ius naturalismo en la admisión positiva Latinoamericana del Derecho Internacional, así se tiene que las bases del sistema jurídico está en el hecho de que el ser humano es, ante todo, un ser racional y social, de allí que este enfoque extrapolado a la sociedad internacional que está constituida por seres humanos, también tiende hacia la racionalidad y que los mismos actores establecen ciertas normas para la vida social internacional; así lo expone Toro Jiménez (2004), “La fundamentación del Derecho Internacional Público, como Derecho Positivo, en el Derecho Natural, reside en el mandato, originario de este último, de que los sujetos del Derecho Internacional Público están obligados a cumplir los tratados, ya que éstos no pueden constituir sino expresión de la naturaleza racional o social de los Estados” (p.53).

En este contexto de la protección de los derechos humanos se han traspasado barreras imponiéndose estos hasta ser un pilar fundamental en el constitucionalismo internacional. Los Derechos Humanos han superado diversos factores de poder, por tanto su reconocimiento, históricamente, ha estado infiltrado por la ideología imperante en los procesos políticos, sociales, culturales, económicos y tecnológicos; es también a criterio de Faúndez Ledesma, cuando afirma que los Derechos Humanos son conquistas sociales derivadas de luchas históricas⁶².

62 Héctor Faúndez Ledesma .Op. Cit. pp.92 y ss.

Sin lugar a dudas la progresividad es un elemento esencial de los Derechos Humanos, es la característica que hace posible que como materia inconclusa, que los derechos humanos puedan ser afirmados cada vez en mayor número y que los Estados deban incorporar a sus normas los nuevos Derechos a medida de su evolución.

Un ejemplo de ello, lo expone Víctor Rodríguez Cedeño⁶³, quien comenta que durante las negociaciones sobre el Estatuto de Roma, Venezuela mantuvo un firme rechazo a la aplicación de la pena de muerte, ya que esta había sido abolida en la legislación venezolana y está prohibida en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, pues el derecho a la vida es el máximo derecho de la persona. En consecuencia, la admisión de la pena de muerte sería contraria a los principios de irreversibilidad y progresividad. Hoy día, es difícil imaginar cual derecho falta por proteger si hasta las generaciones futuras se han convertido en un deber para las generaciones actuales, resguardar su derecho a vivir en un planeta con un ambiente sano donde se preserven las especies y recursos naturales. En los derechos transgeneracionales se percibe la indivisibilidad de los derechos humanos; sin importar si el derecho a la vida ha sido clasificado como de primera generación y el derecho a un ambiente sano como de tercera generación; ambos están intrínsecamente unidos, más cuando los problemas ambientales ocupan una lugar preeminente en aras de preservar a la persona humana.

63 Víctor Rodríguez Cedeño. *Clase Magistral*. Instituto Superior de Estudios Internacionales y Diplomáticos. 11 de febrero del 2005.

CAPITULO IV

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS TRANSGENERACIONALES

La primera oleada de literatura ambientalista se produce a principios de los años 60 (B. Russell, Carson, Udall, Dorst). A esta primera denuncia científica se la ha calificado de "pesimismo ecológico". Todos estos autores coinciden en que la propia supervivencia del hombre está amenazada y que éste se encuentra en un camino imparable hacia su destrucción si la situación continúa en la misma forma.¹ Comienzan las primeras presiones de los movimientos sociales en defensa del medio ambiente, comienzan a surgir algunos documentos de trascendental importancia en el ámbito internacional generadas por algunas Organizaciones Internacionales como la Declaración de principios del Consejo de Europa sobre la lucha contra la contaminación del aire 08 de marzo de 1968 o Carta del Agua del Consejo de Europa del 06 de mayo de 1968.²

Todo ello culmina con el estudio publicado por el Club de Roma en 1972, denominado "Los límites del crecimiento" sobre el crecimiento de la población, la industrialización, contaminación, agotamiento de los recursos naturales y sus efectos interactivos; el que mayor impacto produjo en la conciencia mundial. En éste se afirma que los patrones de uso de recursos que hasta entonces imperaban llevarían a un colapso en el próximo siglo. Ello provocó que se prestara atención a la escasez de recursos: muchos productos se almacenaron, los precios de otros se elevaron, y se creían que el mundo se enfrentaba a un futuro de costos y carestía.

Por su parte, en 1968, la Asamblea General de la ONU inició los trabajos preparatorios de una Conferencia Especializada que se realizaría cuatro años más tarde.

Pero, además en el año 1988 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en cooperación con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), establecieron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) con la misión de analizar y evaluar el cambio climático, sus impactos potenciales, los métodos para adaptarse a los cambios y reducir las emisiones. En el año 1992 concluyeron las negociaciones y se creó la Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En él se define al cambio climático como "un cambio de clima

1 http://salonhogar.net/Salones/Historia/4-6/Ser_humano_medioambiente/Indice.htm

2 Principio 7

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, actividad que altera la composición de la atmósfera global y que es adicional a la variabilidad natural del clima observada en un período de tiempo comparable”.³

Esta oleada de protección al medio ambiente entendido de acuerdo a Foghin (2009) “Como la suma de todas las condiciones externas que afectan la vida, desarrollo y supervivencia de un organismo. Es decir, el entorno que condiciona las circunstancias de vida de los individuos o de la *sociedad*. Comprende el conjunto de elementos naturales (clima, suelo, vegetación, entre otros) sociales y culturales que caracterizan un espacio determinado, en un momento determinado. Dichos elementos se encuentran sujetos a transformaciones permanentes, tanto de origen natural como antrópico, los cuales pueden determinar efectos positivos o negativos sobre las generaciones futuras” (p. 136); ha generado su consagración en múltiples instrumentos jurídicos que protegen los derechos humanos y Constituciones; correspondiendo a continuación establecer la relación existente entre el derecho a la vida, el derecho a un ambiente sano para poder concebir la existencia de los derechos transgeneracionales.

4.1 - LA VIDA COMO UN DERECHO Y UN DEBER

La palabra vida, en su concepción lingüística tiene un significado objetivo, puesto que en los diccionarios de diversas lenguas dice casi lo mismo. Según la definición del diccionario de la Real academia Española, vida del latín *Vita* significa: “Fuerza o actividad interna sustancial, mediante la que obra el ser que la posee. Estado de Actividad de los seres orgánicos. Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte”. El derecho a la vida es, antes que nada, el derecho a la propia existencia fisiológica y biológica. Este es un concepto puramente naturalístico, según lo cual, Vida equivale a ser humano vivo.

La unanimidad demostrada en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos al reconocer y garantizar el derecho la vida, no significa que dejen de presentarse, divergencias las cuales versan en torno a tres peculiaridades relevantes como lo son:

- a. es la base ontológica de todos los otros derechos,
- b. su violación es irreversible ya que implica la desaparición de su titular.
- c. la propia definición de “vida” genera conflictos entre conceptos éticos, morales y religiosos, lo que alimenta debates como los sostenidos sobre la eutanasia, el aborto y el suicidio asistido.⁴

El sentido primordial de este derecho es el de impedir que el Estado, de manera arbitraria, arrebatase la vida a cualquier persona o legalice o autorice la muerte de esta de forma arbitraria; se trata, por lo tanto de una obligación

3 El CMNUCC entró en vigor en marzo del 94; ocho años más tarde había sido firmado por 188 países.

4 Massini, Carlos. El Derecho a la vida en la sistemática de los Derechos humanos. En: *Problemas Actuales sobre Derechos humanos. Una Propuesta filosófica*. Coord. Javier Saldaña. México. UNAM. 2000. Pág. 161

que recae intrínsecamente en el Estado. Este concepto « tradicional » ha evolucionado, pues la tendencia actual es la ser una obligación positiva, primando la dignidad humana como parte del derecho a la vida.

El derecho a la vida indubitadamente es el derecho matriz de los otros derechos de la persona, aunque de acuerdo a la Declaración de Viena, adoptada por la segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad debe tratar los derechos humanos en forma global de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos la misma importancia.” (párr. 5); el derecho a la vida posee un carácter y relevancia especial en su Observación General sobre el artículo 6 del PIDCP, el Comité de Derechos Humanos lo calificó como “el derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones que pongan en peligro la vida de la nación”⁵; también en 1993, en un caso relativo a la pena de muerte, el Comité de Derechos Humanos hizo la observación siguiente: (...) *El derecho a la vida es el más esencial de estos derechos*⁶.

Desde entonces, el Comité ha reiterado textualmente esta.⁷ La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana) ha empleado un lenguaje más sutil y cuidadoso al abordar este tema, señalando: “Si el debido proceso legal, con su conjunto de derechos y garantías, debe ser respetado en cualquier circunstancia, su observancia es aún más importante cuando se halle en juego el supremo bien que reconocen y protegen todas las declaraciones y tratados de derechos humanos: la vida humana”⁸ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en el reconocimiento del carácter especial del derecho a la vida.

En una decisión adoptada en 1996 expresa: (...) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe destacar (...) que el derecho a la vida entendido como un derecho fundamental de la persona humana consagrado en la Declaración Americana y en diversos instrumentos internacionales a escala regional y universal, tiene el estatus de *jus-cogens*. “El concepto de *jus-cogens*” agrega la CIDH, “se deriva de un orden superior de normas establecidas en tiempos antiguos y que no pueden ser contravenidas por las leyes del hombre o de las naciones.”⁹

La Convención Americana señala que el derecho a la vida “estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”. Sin embargo el

5 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 6, párr. 1 (1982).

6 Comité de Derechos Humanos, caso *Kindler c. Canadá*, párr. 13.1

7 Comité de Derechos Humanos, caso *A.R.J. c. Australia*, párr. 6.8 (1997); *G.T. c. Australia*, párr. 8.1 (1998).

8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-16/99, párr. 135.

9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), caso *Remolcadora 13 de marzo*, párr. 79 (1996). Ver también *Sequieras Mangas c. Nicaragua*, párr. 145. (1997). La CIDH hace una exégesis de la relación y las diferencias entre los conceptos de derecho consuetudinario y de *jus cogens* en los párrafos 43 a 50 de su decisión en el caso *Domínguez c. Estados Unidos* (2002).

el PIDCP y las Declaraciones (Universal y Americana) guardan silencio sobre la cuestión de saber cuándo hay que reconocer y proteger la vida. Se estima conveniente señalar algunos instrumentos internacionales que consagran el derecho a la vida

4.1.1.- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

4.1.2.- PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (PIDCP)

Artículo 6

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

4.1.3.- DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

Artículo I.

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

4.1.4.- CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Artículo 4. Derecho a la vida

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

4.1.5.- CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Artículo 6

1 Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

2. Los Estados Partes garantizan en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

Se observa que la normativa jurídica internacional respecto a este derecho no prohíbe categóricamente su privación, más bien se manifiesta en cuanto a su privación arbitraria y al derecho de vivir. Tampoco explicitan desde cuando se protege a excepción de la Convención Americana.

Los países Latinoamericanos han acogido este criterio de diversas formas, a veces como garantía otras como derecho, incluso ambas; Brasil por ejemplo lo acoge como una garantía - derecho en el Título II dentro del Capítulo I de los derechos y Deberes Individuales y Colectivos (Artículo 5); Colombia

la consagra como un derecho en el Título II, Capítulo I de los Derechos Fundamentales (Artículo 11); la Constitución costarricense no explicita si es un derecho o garantía, sin embargo en el Título IV relacionado con los Derechos y garantías individuales Capítulo Único dice: “La vida humana es inviolable” (Artículo 21); la Constitución chilena no utiliza la acepción derecho sino que « asegura » 1.- el derecho a la vida, pero además a la integridad física y psíquica de la persona, protegiendo la vida del que está por nacer (Artículo 19); El Salvador lo reconoce como un derecho en el Título II, Capítulo I en los Derechos individuales, además de la integridad física y « moral » Guatemala se inscribe en el criterio de la Convención Americana, al garantizar y proteger la vida humana desde su concepción, incluyendo la integridad y la seguridad de la persona (Título II de los Derechos Humanos, Capítulo I de los Derechos Individuales (Artículo 3)¹⁰; en Venezuela desde el Preámbulo se pretende asegurarla, en el Título I de los principios fundamentales se propugna como un valor y en el Título II de los derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes, Capítulo II se establece como un derecho inviolable, proscribiendo la pena de muerte (Artículo 43).

Para vivir se necesitan ciertas condiciones básicas e indispensables que realmente garanticen la existencia humana; que contribuyan a la realización del proyecto de vida que cada uno; no se puede vivir sino se tiene acceso al agua, sino se vive en un ambiente sano... estas son las variables más apropiadas al tema in comento. El entorno ambiental sano y apropiado es un asunto que se debate en los actuales momentos a nivel internacional, porque la contaminación y el deterioro al ambiente y sus consecuencias puede poner en peligro a todos los hombres sin importar el lugar donde se origine el daño. Entonces, la vida ¿Será sólo un derecho actual, puede ser un derecho a futuro o un deber de la generación presente para los que han de venir?.

4.2.- ¿LAS GENERACIONES FUTURAS TIENEN O NO TIENEN DERECHOS?

Con sustento en los avances científicos organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, se han avizorado las consecuencias del comportamiento humano y su impacto sobre el ambiente, propiciándose la discusión respecto a los derechos de las generaciones futuras; este deber hacia el futuro según lo concibe Pontana (1996), puede apreciarse desde el punto de vista de la “responsabilidad moral” (p.23), e incluso estima que el debate se ha producido recientemente dirigiendo la controversia sobre todo filósofos anglosajones de tendencia « analítica », sobresaliendo Jan Narveson pionero que influenció notablemente en los subsiguientes argumentaciones; también cabe mencionarse a M.P Golding y Jhon Rawls (1971) quien en su obra: Teoría de la Justicia dice:

(...) en los primeros principios de la justicia no se nos permite tratar de un modo diferente a las generaciones, sólo sobre la base de que sean anteriores o posteriores en el tiempo. La posición original está definida de tal manera que conduzca al principio adecuado. En el caso del individuo, la preferencia en el tiempo es irracional. Significa que no está considerando

10 Op.cit. pp 87 sgtes

todos los momentos como partes iguales de una vida. En el caso de la sociedad, la pura preferencia en el tiempo es injusta. Significa (como por ejemplo, cuando se desestima el futuro) que los que viven toman ventaja de su posición en el tiempo para favorecer sus propios intereses.” (p.274).

Antes de estos menciona el contractualismo propugnado primeramente por Hobbes, como una forma articulada de reglas mediante las cuales los contratantes se sienten unidos y limitados en beneficio común no permitiéndose el perjuicio del otro sujeto, respetando las cláusulas pactadas al estilo del planteamiento de Locke, en donde lo primordial es el provecho de todos, en este contexto “según el contractualismo efectivo los intereses de las generaciones futuras están relegados a la moral del provecho mutuo”. No existiendo unanimidad en cuanto a la asunción de responsabilidad para con las generaciones futuras, por ello se esbozarán distintas corrientes¹¹.

El mismo Pontana cita a De George y trae a colación la tesis que contraría el derecho de las generaciones futuras; asentando esto:

Las personas futuras no tienen, individual o colectivamente, en el momento presente ningún derecho a los recursos existentes en la actualidad. En tal sentido, aquéllas son diferentes de las personas actualmente existentes, las cuales en general, tienen derecho a un uso juicioso de los bienes necesarios para la continuación de su existencia.

Y si, a causa de exigencias racionales presentes, alguno de estos bienes se agota hoy, sería un error decir que personas o generaciones futuras tendrán un derecho a *estos* bienes y que, en consecuencia, al haberlos agotado violamos sus derechos. De las generaciones o de los grupos o los individuos futuros se puede decir, con exactitud, que solamente tienen derecho a aquello que sea accesible cuando vengan al mundo y por tanto, cuando sus posibles derechos futuros se transformarán en actuales y presentes¹².

Exponiendo los argumentos en los cuales se apoya la anterior tesis, siendo estos dos, primordialmente:

- Es necesario existir para ser susceptible o acreedor de derechos y en consecuencia poderlos reclamar, exigir, valer “si es necesario incluso con la fuerza”;
- Como consecuencia de lo anterior, los individuos nacidos a futuro al no existir *ahora*, no tienen ningún poder para exigir un eventual derecho que se le pueda garantizar; entonces “no es plausible atribuirles derechos válidos *ahora*”.

Objetando tal posición y expresa que: (...) tener un derecho y estar en condiciones de hacer valer una determinada exigencia son dos cosas totalmente diferentes y que siempre la segunda presupone la primera y no viceversa; poniendo como ejemplo el caso de los niños (recién nacidos y los de corta edad) o los individuos discapacitados mentalmente; tienen derechos, aunque no los puedan ejercer por sí mismos. Igualmente, refuta

11 Op. Cit. 78

12 Op. Cit. 110

la argumentación propuesta por De George, diciendo (...) exigencias de individuos pertenecientes a generaciones futuras pueden hacerse valer *ahora* a través de personas o instituciones que les representen.¹³

El autor supra citado, también menciona como participe de la anterior tesis a D. Callahan, según este no “logra entender como se puede negar la exigencia de un derecho humano fundamental que hace valer una persona que vive en la actualidad dando preferencia a la exigencia condicional que puede hacer valer alguien que existirá en un futuro”; no compartiendo tal tesis, inscribiéndose en el utilitarismo.

En base a esta teoría ética se debe actuar siempre de tal modo que se maximice la felicidad, el bienestar o la utilidad, aludiendo a Bentham y más recientemente a Sidgwick; atribuyendo de acuerdo al asunto in comento (...) “desde un punto de vista universal, el tiempo en el que un ser humano existe no puede incidir en el valor de su felicidad, [razón por la cual] un utilitarista debe tomar en consideración los intereses de la posteridad en la misma proporción que los de sus contemporáneos, teniendo presente los efectos de sus acciones sobre la posteridad incluso la propia existencia de seres futuros”¹⁴ (...). Para concluir, de acuerdo a Pontana es irrelevante éticamente concebir sólo el factor temporal para darle la relevancia debida a las generaciones futuras; estas tesis no han tenido realmente cabida, imponiéndose pausada pero firmemente la concepción de asumir el compromiso hoy porque no habrá mañana para nadie; las calamidades naturales que azotan a los Estados Unidos (Huracán Katrina), los tsunamis en Asia, las inundaciones en Europa y Latinoamérica no son hechos aislados; afirmándose entonces los llamados derechos de solidaridad; ¿Por qué la existencia de estos derechos? Al respecto, es menester establecer guiados por Leonardo Boff (2004) los fundamentos que priman al interrelacionar el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente sano con los derechos transgeneracionales;

4.3.- DERECHOS DE SOLIDARIDAD

Aunque el reconocimiento de los derechos humanos ha sido progresivo el elemento de la solidaridad se hace presente sobre todo en los derechos denominados de segunda y tercera generación, en estos se encuentra un componente predominante, como lo es la intervención del Estado, el cual se puede apalancar con otras instituciones que propendan objetivos colectivos para hacerlos factibles en este sentido el Estado protege y a su vez contribuye a promoverlos. Cuando se trata de proteger el medio ambiente y consecuentemente la vida de las generaciones futuras se entrecruzan dos variables; primero su reconocimiento como un derecho y luego el deber por parte del Estado y de *todos* de conservar condiciones naturales idóneas que permitan la vida en el planeta, por lo que es preciso conjugar por medio de un sistema legislativo tutelar y pragmático la acción humana y el curso de la naturaleza, es la gran misión estatal. Los derechos no se reconocen ni garantizan hasta que se hace palpable el riesgo y peligro de una determinada

13 Op.cit. 111

14 Op.cit. 136

situación; los estragos contra el ambiente ahora no son los mismos de hace cuarenta o cincuenta años atrás, hoy son perceptibles las contingencias naturales cada vez peores; para los que vivieron la tragedia natural de 1999 en el Estado Vargas (Venezuela) se volvió connatural la relación ambiente-vida:

Con un mar de fondo se inicia en el estado Vargas la emergencia fue le primer signo de los que sería después una gran tragedia. El mar tomó terreno e invadió las principales avenidas de la región (...) Pienso en las palabras que días después decía el Padre Reinaldo Herrera: Dios Perdona siempre; los hombres perdonan a veces; pero la naturaleza NUNCA perdona (...) Indescriptible el sufrimiento existencial de un padre a su hija, mientras cruza el río crecido, teniendo en su mano a la hija menor a la vez que a la mayor se la lleva el río y grita desesperada: "Papá, sálvame por favor, no me dejes"; ¿Quién sería capaz de consolar a una madre que ha perdido a sus cuatro hijos por la inclemencia de la naturaleza? O a un niño que perdió a sus padres y se quedó sólo, sin casa, y lo que es peor sin familia? Que se le puede decir a unos padres que consignaron a su hijo pequeño, vivo a un helicóptero de rescate, y hasta el día de hoy todavía no saben donde está, ni siquiera si está vivo o no? (...) incomparable sufrimiento, que aún muchos varguenses padecen. Sólo el que ha sufrido una guerra sabe lo que es la guerra. (...) Sólo el que sufrió la terrible y horrorosa (no encuentro palabras más intensas) tragedia de Vargas, puede saber realmente lo que fue.¹⁵

Al reconocer la tuición a la vida, al ambiente y más aún a las generaciones que aún son una expectativa es porque existen razones para ello. La interdependencia, indivisibilidad y universalidad de los derechos humanos, no permite su encasillamiento, de allí, que la progresividad como principio immanente en su estudio no admite que el Hombre se detenga en beneficio propio. Sostiene el autor supra citado que: "La solidaridad está inscrita objetivamente en el código de todos los seres, pues todos somos interdependientes unos de otros. Coexistimos en el mismo cosmos y en la misma naturaleza con un origen y un destino comunes (...) la ley suprema del universo es la de la solidaridad y la cooperación de todos con todos". (55) siguiendo a este autor se puede inferir que la solidaridad es un vínculo que ha unido al Hombre en su (...) "salto de la animalidad a la humanidad y a la creación de la socialidad que se expresa por el lenguaje" (...); entonces quien pretenda que las catástrofes, tragedias, calamidades, desastres etc. Producto de las acometidas naturales se evitan y solucionan aisladamente está errado.

Convirtiéndose la solidaridad en una cuestión ontológica y axiológica, la inmanencia en los seres humanos de su responsabilidad para consigo mismo y con los demás, es propio de la naturaleza humana ¡sobrevivir!; concluyendo Boff en que: "Es importante también alimentar la solidaridad con las generaciones futuras, pues también ellas tienen derecho a una tierra habitable".

15 Bazó Canelón, Abelardo: La tragedia de Vargas (Apuntes de testigo).Caracas, Ediciones Centauro. 2002. pp.9, 19 y 190.

Estando esta afirmación en congruencia con la doctrina social de la iglesia la cual tiene postulados paradigmáticos a tenor del tema en cuestión, en dos documentos memorables; en el “Evangelio de la Vida”, Juan Pablo II (1995), conjuga la donación divina dada al hombre y la deuda que este debe honrar; enunciando que: “El hombre, llamado a cultivar y custodiar el jardín del mundo (Gn. 2, 15), tiene la responsabilidad específica sobre el *ambiente de vida*, o sea, sobre la creación que Dios puso al servicio de su dignidad personal, de su vida: respecto no sólo al presente, sino también a las generaciones futuras. Es la *cuestión ecológica* desde la preservación de hábitat (...) hasta la ecología humana propiamente (...) el dominio confiado al hombre por el Creador no es un poder absoluto, ni se puede hablar de libertad de “usar y abusar”, o de disponer de las cosas como mejor parezca” (p. 50). De esta forma; la solidaridad tiene que ser un puente que una las conciencias de quienes tienen el poder y el deber de guiar el destino de la humanidad. Y, en igual sentido se pronuncia Benedicto XVI en “Caritas in Veritate” (2009) “La solidaridad universal, que es un hecho y un beneficio para todos, es también un deber” (p.67); la relación existente entre los derechos humanos conducen intrínsecamente a no sobreponerlos unos a otros, ante el cambio climático y las consecuencias sufridas por esta causa el entorno ambiental cobra vital importancia; la biosfera no es un bien individual es un patrimonio común de la humanidad, cuando se cuida una determinada extensión geográfica esta acción se colectiviza y trasciende, se irradia hacia el orbe.

Todos los derechos tienen una dimensión social, en la medida en que son ejercidos por individuos o grupos en un contexto social; pero, ciertos derechos como los de solidaridad, se relacionan en mayor grado con la propia comunidad. Así ha quedado establecido en sentencia de fecha 30/06/2000 emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de Venezuela:

La Sala Constitucional en este sentido va a delinear notas características congruentes con los derechos de solidaridad en los cuales se enmarcan una serie de valores y principios que se implican en la calidad de vida y el bien común. Al respecto, señala que: “El artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa que Venezuela es un Estado Social de Derecho y de Justicia. Esto significa, que dentro del derecho positivo actual y en el derecho que se proyecte hacia el futuro, la ley debe adaptarse a la situación que el desarrollo de la sociedad vaya creando, como resultado de las influencias provenientes del Estado o externas a él. Son estas influencias las que van configurando a la sociedad, y que la ley y el contenido de justicia que debe tener quien la aplica, deben ir tomando en cuenta a fin de garantizar a los ciudadanos una calidad integral de vida, signada por el valor dignidad del ser humano. El Estado constituido hacia ese fin, es un Estado Social de Derecho y de Justicia, cuya meta no es primordialmente el engrandecimiento del Estado, sino el de la sociedad que lo conforma, con quien interactúa en la búsqueda de tal fin.

(...) Como derechos cívicos, destinados a proteger la calidad de la vida, a ellos se les pueden resaltar varios caracteres. Uno, el

que formando parte de los derechos otorgados a la ciudadanía, mecanismos legales para precaver el bien común, cualquier miembro de la sociedad, con capacidad para obrar en juicio, puede –en principio– ejercerlos. Dos, que siendo ellos deferidos como parte de una interacción social, que actúan como elementos de control de la calidad de la vida comunal, no pueden confundirse con los derechos subjetivos individuales que buscan la satisfacción personal, ya que su razón de existencia es el beneficio del común, y lo que se persigue con ellos es lograr que la calidad de la vida sea óptima. Esto no quiere decir que en un momento determinado un derecho subjetivo personal no pueda, a su vez, coincidir con un derecho destinado al beneficio común.

Una tercera característica de estos derechos, es que al perseguir con ellos el bien común, su contenido gira alrededor de prestaciones, exigibles bien al Estado o a los particulares, que deben favorecer a toda la sociedad, sin distingos de edad, sexo, raza, religión, o discriminación alguna.

Planteado así, estos derechos de protección ciudadana no están necesariamente dirigidos contra el Estado o sus entes, sino que pueden ir orientados contra particulares, hacia organizaciones con o sin personalidad jurídica, y tal vez en un futuro, en el plano internacional, conforme a los Tratados Internacionales, hasta contra otros Estados.

Es la afectación o lesión común de la calidad de vida, que atañe a cualquier componente de la población o de la sociedad como tal, independientemente de las relaciones jurídicas que puedan tener con otros de esos indeterminados miembros, lo que señala el contenido del derecho e interés difuso.

Pero es esa defensa del bien común afectado, el que hace nacer en los miembros de la sociedad un interés procesal que les permite accionar, a causa de la necesidad de exigir al órgano jurisdiccional que mantenga la calidad de vida, si es que el lesionado se la niega.

Los derechos de solidaridad han conquistado adeptos que han logrado promover la asunción de responsabilidades tomadas en las diferentes Declaraciones que no deben quedar en palabras o depositadas en fardos resquebrajados. En este sentido, conviene analizar diferentes conferencias propiciadas desde la Organización de Naciones Unidas que afrontan los tópicos en cuestión.

4.4.- CONFERENCIAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Según Kelsen (1957) de acuerdo a la Teoría Comunista del Derecho y del Estado; (...) “el derecho debe basarse en la sociedad. Debe ser la expresión de sus intereses y necesidades comunes” (p. 31) Partiendo de esto y esbozado

lo anterior, cabe analizar como ante la realidad apremiante e inaplazable la mayoría de los países que conforman el orbe han debido ocuparse de la protección del ambiente, en beneficio de los presentes y para las generaciones futuras; en diferentes Declaraciones y Protocolos, el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo para las futuras generaciones ha calado; este desarrollo acompasado ha sido debido principalmente a las siguientes Conferencias con el fin supremo de salvaguardar a la humanidad, de allí la importancia de analizar el contenido y objetivos propuestos en ellas.

4.4.1.- CONFERENCIA SOBRE EL MEDIO HUMANO O CONFERENCIA DE ESTOCOLMO (SUECIA)

Convocada por la Organización de Naciones Unidas, se realizó esta Conferencia entre los días 05 y 16 de junio de 1972, es un referente obligatorio como antecedente a la protección ambiental; incluso como lo señala, Troconis Parilli (2007) (...) para tratar el derecho ambiental como disciplina científica, complementado con el tratamiento de aspectos coadyuvantes con la juridificación tales como contaminación, cooperación, protección, conservación, lo generacional, educación, planificación, ordenación, investigación y desarrollo (p.131); alertados por las advertencias del Club de Roma, acudieron 113 representaciones estatales y más de 400 organizaciones no gubernamentales; promoviéndose las bases futuras de protección ambiental en los aspectos supra citados.

La Declaración compuesta de un Preámbulo, 26 Principios y consecuentemente, un Plan de Acción en procura de la conservación y protección del ambiente se convirtieron en el punto de partido de lo que se ha denominado el Derecho Ambiental Internacional; aunque reitera la soberanía de los Estados en relación a la explotación de sus recursos naturales, esta explotación y administración debe ser cónsona con la una debida planificación y cooperación, auspiciándose acuerdos con el fin de evitar perjuicios ambientales y garantizar una justa indemnización a posibles víctimas en caso de contaminación u otros daños.

El preámbulo de esta Declaración es un *panegírico* a los derechos humanos especialmente al ambiente; exponiendo su valía, de esta manera: El Hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material (...) Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial; son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma¹⁶.

Entre sus Principios destacan el 1º referido primordialmente a un anhelo que aspira a ser una acción tangible expresada así: El Hombre tiene el derechos fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras.

De los principios 21, 22 y 23 se visualiza el Derecho ambiental Internacional bajo la égida del respeto supranacional y la cooperación; los estamentos

16 <http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html>

quedaron definitivamente abolidos con este nuevo paradigma que impregna en adelante la Declaración de Estocolmo.

4.4.2.- CUMBRE DE NAIROBI (KENIA)

La Cumbre de Nairobi (Kenia), celebrada entre el 10 y 18 de mayo de 1982, con motivo de conmemorar y evaluar la Cumbre del Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo, si bien en la misma se consideró los progresos habidos después de la Cumbre precedente también mostró (...) “su profunda preocupación por el estado actual del medio ambiente en todo el mundo, y reconoce la urgente necesidad de intensificar los esfuerzos regionales y nacionales a nivel mundial para proteger y mejorar el ambiente”.

Los puntos más resaltante sobre los cuales versó la misma se pueden resumir en los siguientes:

1.- Se reconoció la valía de la Conferencia de Estocolmo considerándola que estimuló una fuerza poderosa en la conciencia pública creciente y comprensión de la fragilidad del medio ambiente humano, avances significativos en las ciencias del medio ambiente, educación, información y difusión la formación se han ampliado considerablemente, en casi todos los países se ha legislado respecto a la protección ambiental incorporándolo incluso en los textos constitucionales a través de los procesos constituyentes y reformas recientes. Incluso la Organización de Naciones Unidas creó el Programa para el Medio Ambiente; igualmente han proliferado, organizaciones no gubernamentales, además de haberse importantes acuerdos internacionales en materia de cooperación medioambiental.

2.- Se admitió sin embargo, que el Plan de Acción previsto en Estocolmo sólo se había aplicado parcialmente, considerándose insuficientes los resultados por cuanto el Plan de Acción no ha tenido suficiente impacto en la comunidad internacional en su conjunto. Aún continúa la deforestación, la degradación del suelo y del agua y la desertificación han alcanzando proporciones alarmantes y ponen en grave peligro las condiciones de vida en gran parte de la mundo; como consecuencia se asocian brotes de enfermedades por las malas condiciones ambientales que continúan causando miseria.

Los cambios en la atmósfera - como los de la capa de ozono, la creciente de carbono, dióxido de carbono, la lluvia ácida, la contaminación de los mares y aguas interiores, el descuido en la utilización y eliminación de sustancias peligrosas y la extinción de especies animales y vegetales constituyen graves amenazas para el medio ambiente y en consecuencia para los humanos.

3.- Durante la última década, han surgido nuevas percepciones; tales como la íntima relación entre el ambiente y el desarrollo; influyendo necesariamente en la población y la administración de los recursos. Los esfuerzos que se efectúen tanto a nivel mundial como regional debe conllevar a decisiones ecológicamente racionales compatibles con un progreso sostenible tanto en lo económico como en lo social.

4.- Se exhortó en esta Cumbre a la promoción de un nuevo orden económico internacional que propugne la modificación de los patrones de consumo; señalando que el Organismo Internacional de Estrategia de Desarrollo para

el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo es uno de los principales instrumentos en el esfuerzo mundial para revertir la degradación ambiental. Se deben combinar y planificar mecanismos que conjuguen el desarrollo, la gestión de los recursos y el medio ambiente sano.

5.- Se abogó para que todos los esfuerzos que se realicen en pro del ambiente contribuyan a fomentar una atmósfera internacional de paz y seguridad; libre de las amenazas de cualquier guerra, especialmente la guerra nuclear, así como del apartheid, la segregación racial y todas las formas de discriminación, colonial y otras formas de opresión y dominación extranjera.

6.- Lo anterior, se deduce debido a que muchos problemas ambientales trascienden las fronteras nacionales debiéndose resolver pacíficamente en beneficio de todos. Por lo tanto, los Estados deben promover el desarrollo progresivo del derecho ambiental, incluidos los convenios y acuerdos, además de ampliar la cooperación en la investigación científica y la gestión ambiental.

7.- Se planteó una equitativa distribución de recursos técnicos y económicos debido a la desigualdad existente entre los países, imponiéndose la necesidad de colaboración para resolver los problemas ambientales más graves; los cuales se agudizan en los países pobres que a su vez reciben expolio de sus naturales.

8. También, se planteó aparte de combinar esfuerzos para desarrollar y lograr una buena gestión ambiental la búsqueda de nuevos métodos como por ejemplo para el pastoreo, el reciclaje, desarrollo de nuevas fuentes de energía etc. Que redunden en una efectiva protección ambiental.

9.- Se asumió como un reto el freno y en la medida de lo posible la reversión del daño ambiental; considerando la prevención de manera prioritaria a través de actividades educativas que instruyan sobre la importancia de la protección ambiental, esta formación se lograría a través de aumentar el conocimiento público y la conciencia política de la importancia del medio ambiente. Concediéndole importancia al rol protagónico que pueden ejercer las organizaciones no gubernamentales; atribuyéndole a su vez la responsabilidad por el deterioro ambiental a las empresas, incluidas las empresas multinacionales, sobre las cuales deben tomarse medidas de control en la producción industrial y en los métodos y tecnologías utilizadas. Conjugando lo anterior en una legislación adecuada.

10. Reafirmando la comunidad mundial de Estados en esta Cumbre su compromiso con el Convenio de Estocolmo y su Plan de Acción, así como el fortalecimiento de los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional en el ámbito de la protección del medio ambiente. Asimismo, se revalidó el apoyo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como el principal catalizador e instrumento mundial para promover la cooperación ambiental; reconociendo la precariedad de recursos económicos necesarios para abordar los problemas de la el medio ambiente. Instando a todos los gobiernos y pueblos del mundo para que cumplan con su responsabilidad, individual y colectivamente, para asegurar el planeta pase a las generaciones futuras en condiciones que garanticen una vida con dignidad humana para todos.¹⁷

17 www.pnuma.org/docamb/index.php

Sin embargo, la Cumbre de Nairobi no tuvo la repercusión internacional esperada; sin embargo entre esta Cumbre y la siguiente se continuaron realizando actividades y celebrados Convenios tendientes a procurar la protección ambiental tales como: Convenio de Viena del 22 de marzo de 1985¹⁸, el cual se afianzó con el Protocolo de Montreal del 16 de septiembre de 1987,¹⁹ el cual versó acerca de la protección de la capa de ozono; el Convenio de Basilea del 22 de marzo de 1989, el cual versó sobre los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos²⁰.

Además, en 1987, en el informe anual de la Comisión Brundtland²¹ se formaliza el concepto de “desarrollo sostenible”. A partir de ese momento se maneja ese término por doquier en todos los ámbitos, desde la propia ONU, pasando por los organismos gubernamentales, internacionales, empresariales, etc.

En Berlín 1995, 160 países firmaron un documento que establecía la voluntad de reducir los gases que causan el efecto invernadero. En esta reunión, aunque se consiguió una declaración de intenciones, no se fraguaron compromisos para combatir el problema. Al año siguiente, en la reunión de Ginebra, delegados de 150 países asumieron que la causa del cambio climático radicaba en las actividades humanas, tras ser debatido un informe encargado a un comité intergubernamental.²²

4.4.3.- CUMBRE DE RÍO (BRASIL)

En Río, 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes de Estado y de Gobierno, aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura: el Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los Estados, y una Declaración de principios relativos a los bosques, serie de directrices para la ordenación más sostenible de los bosques en el mundo; considerada *La Cumbre de la Tierra* en clave política exhorta a garantizar la supervivencia de la especie humana.

Se abrieron a la firma además dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria: la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Al mismo tiempo se iniciaron negociaciones con miras a una Convención de lucha contra la desertificación, que quedó

18 www.pnuma.org/ozono/tratadosinternacionales

19 www.pnuma.org/ProtocoloMontreal/pdf

20 www.pnuma.org/.../24%20Alvarez%20Convenio%20de%20Basilea.pdf

21 El libro “Nuestro Futuro Común” (nombre original del Informe Brundtland) fue el primer intento de eliminar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. Presentado en 1987 por la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, encabezada por la doctora noruega Gro Harlem Brundtland, trabajó analizando la situación del mundo en ese momento y demostró que el camino que la sociedad global había tomado estaba destruyendo el ambiente por un lado y dejando a cada vez más gente en la pobreza y la vulnerabilidad

22 http://www.natureduca.com/cienc_hist_cumbrestierra.php

abierta a la firma en octubre de 1994 y entró en vigor en diciembre de 1996.

En el Programa 21, que contiene más de 2.500 recomendaciones prácticas, se abordan los problemas urgentes de hoy en día. El Programa 21 tiene por objeto preparar al mundo para los retos del próximo siglo e incluye propuestas concretas en cuestiones sociales y económicas, como la lucha contra la pobreza, la evolución de las modalidades de producción y de consumo, la dinámica demográfica, la conservación y ordenación de nuestros recursos naturales, la protección de la atmósfera, los océanos y la diversidad biológica, la prevención de la deforestación y el fomento de la agricultura sostenible.

En el Programa 21 se recomiendan maneras de fortalecer el papel de los grupos principales; las mujeres, los sindicatos, los agricultores, los niños y los jóvenes, las poblaciones indígenas, la comunidad científica, las autoridades locales, el comercio, la industria y las organizaciones no gubernamentales con miras al desarrollo sostenible.

Al aprobar el Programa 21, la Conferencia exhortó a los participantes a adoptar varias iniciativas importantes en esferas fundamentales del desarrollo sostenible. Entre esas iniciativas cabe señalar la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, de la cual surgió un Programa de Acción para esos Estados, una Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, de fuerza jurídica obligatoria, y la celebración de conversaciones sobre la prevención del agotamiento de las poblaciones de peces altamente migratorios y de las poblaciones de peces cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas (poblaciones de peces transzonales).

En la Declaración de Río se definieron los derechos y las obligaciones de los Estados respecto a los principios básicos sobre el medio ambiente y el desarrollo. Se incluyeron las siguientes ideas: la incertidumbre en el ámbito científico no ha de demorar la adopción de medidas de protección del medio ambiente; los Estados tienen el “derecho soberano de aprovechar sus propios recursos” pero no han de causar daños al medio ambiente de otros Estados; la eliminación de la pobreza y la reducción de las disparidades en los niveles de vida en todo el mundo son indispensables para el desarrollo sostenible, y la plena participación de la mujer es imprescindible para lograr el desarrollo sostenible.

La Declaración de principios para la ordenación sostenible de los bosques, que no tiene fuerza jurídica obligatoria, constituyó el “primer consenso mundial” sobre la cuestión. En la Declaración se dispone, fundamentalmente, que todos los países, en especial los países desarrollados, deberían esforzarse por reverdecer la Tierra mediante la reforestación y la conservación forestal; que los Estados tienen derecho a desarrollar sus bosques conforme a sus necesidades socioeconómicas, y que deben aportarse a los países en desarrollo recursos financieros destinados concretamente a establecer programas de conservación forestal con miras a promover una política económica y social de sustitución.

Tras la aprobación de los principios relativos a los bosques se estableció, en 1995, un Grupo Intergubernamental sobre los Bosques, en calidad de órgano subsidiario de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. .

Desde la Cumbre para la Tierra, celebrada en 1992, el “espíritu de Río” perdura en la acción de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los grupos principales y las personas de todo el mundo.

Bien cabe llamar a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible el órgano custodio del “espíritu de Río” y del desarrollo sostenible; la Comisión no sólo ha logrado movilizar el interés y la participación activa de los gobiernos y del sistema de las Naciones Unidas, incluidos los bancos de desarrollo, sino que también ha captado la atención de grupos no gubernamentales y del público en general.²³

4.4.4.- PROTOCOLO DE KYOTO (JAPÓN)

El acuerdo fue suscrito en la ciudad japonesa de Kioto el 10 de diciembre de 1997. Se trata de un acuerdo jurídicamente vinculante cuyo objetivo es que, en el período 2008-2012, los países industrializados reduzcan sus emisiones colectivas de gases que causan el efecto de invernadero en un 5,2%, respecto a 1990, se cree que este efecto está provocando, al menos en parte, el aumento de la temperatura del planeta.

Entonces 34 países industrializados, la mayor parte de ellos europeos, se comprometieron a cumplir determinadas metas.

Para que el protocolo entrara en vigor, tenía que ser ratificado por los países industrializados causantes del 55% de las emisiones de estos gases.

Cuatro de los 34 países originales no lo han ratificado: Estados Unidos (responsable por el 36,1%) de las emisiones entre los países industrializados en 1990), Australia (2,1%), Liechtenstein (0,001%) y Mónaco (0,001%).

En 2004, después de dos años de debates y negociaciones, Rusia ratificó el protocolo, lo que posibilitó que 90 días después, el 16 de febrero, éste entrara en vigor.

El protocolo establece que estas naciones son las que menos contribuyen al cambio climático pero las que con más probabilidades sufrirán sus efectos.

Muchos países en desarrollo han firmado el acuerdo. Éstos no tienen que cumplir un objetivo específico.

Sin embargo, deben informar sobre sus niveles de emisión y desarrollar programas para reducirlas. China e India, con economías crecientes y poblaciones numerosas, están entre los principales contaminantes. Ambos ratificaron el protocolo, pero en términos reales no están jurídicamente obligados a cumplir ninguna meta.²⁴

En el Protocolo de Kyoto se estableció un “Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático” compuesto por especialistas de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los Estados Partes se comprometieron a reducir las emisiones de los siguientes gases Dióxido de carbono (CO₂), Metano (CH₄), Óxido nitroso (N₂O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC),

23 <http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm>

24 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2005/kioto/newsid_4234000/4234085.stm

Hexafluoruro de azufre (SF₆).

Comprometiéndose a elaborar y seguir medidas conforme a las circunstancias nacionales de cada país; por ejemplo las siguientes:

1) Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional;

2) protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación;

3) promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático;

4) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales;

5) reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean contrarios al objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado;

6) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal;

7) medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del transporte;

8) limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y utilización en la gestión de los desechos así como en la producción, el transporte y la distribución de energía.

Igualmente, las Partes procurarán intercambiar experiencia e información sobre tales políticas y medidas, en particular concibiendo las formas de mejorar su comparabilidad, transparencia y eficacia.²⁵

El Protocolo de Kioto, compromete a los países industrializados a cumplir metas específicas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

El protocolo sufrió un gran golpe cuando Estados Unidos, responsable por una cuarta parte de las emisiones globales, lo abandonó en 2001.

Sin embargo en 2004 Rusia decidió ratificarlo, lo que permitió que se convirtiera en realidad el 15 de febrero de 2005.

El camino no es fácil, sin embargo no por falta de Convenciones, Declaraciones, Acuerdos etc. Los objetivos trazados serán vacuos si los Estados Partes efectivamente no resguarden los compromisos asumidos; por cuanto hartos ya está escrito el problema del cambio climático es global; en

25 http://unfccc.int/files/essential_background/kyoto_protocol/application/pdf/kpspan.pdf

la medida que se produzcan daños al ambiente, a la biosfera la tragedia está latente; lo mejor será evitar antes que paliar el deterioro. Plasmar soluciones y luego no cumplirlas es fatuidad ante los embates de la naturaleza que en muchas ocasiones ni avisan cuando llegan ni su intensidad es predecible con exactitud.

4.4.5.- CUMBRE DE JOHANNESBURGO (SUDÁFRICA)

La Cumbre se efectuó del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002. En el Sandton Convention Centre, a las afueras de Johannesburgo. Entre las varias sesiones e informes, se puede catalogar como los puntos más neurálgicos y que a su vez encierran el *pneuma* de la cumbre los siguientes:

4.4.5.1.- LOS GRANDES PROBLEMAS QUE SE DEBEN RESOLVER

1.- La erradicación de la pobreza, la modificación de pautas insostenibles de producción y consumo, la protección y ordenación de la base de recursos naturales para el desarrollo social y económico son objetivos primordiales y requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible.

2.- La fisura que divide a la sociedad humana entre ricos y pobres así como el abismo cada vez mayor que separa al mundo desarrollado del mundo en desarrollo representan una grave amenaza a la prosperidad, seguridad y estabilidad mundiales.

3.- El medio ambiente mundial sigue deteriorándose. Continúa la pérdida de biodiversidad; siguen agotándose las poblaciones de peces; la desertificación avanza cobrándose cada vez más tierras fértiles; ya se hacen evidentes los efectos adversos del cambio del clima; los desastres naturales son más frecuentes y más devastadores, y los países en desarrollo se han vuelto más vulnerables, en tanto que la contaminación del aire, el agua y los mares sigue privando a millones de seres humanos de una vida decente.

4.- La globalización ha agregado una nueva dimensión a estos problemas. La rápida integración de los mercados, la movilidad del capital y los apreciables aumentos en las corrientes de inversión en todo el mundo han creado nuevos problemas y oportunidades para la consecución del desarrollo sostenible. Pero los beneficios y costos de la globalización no se distribuyen de forma pareja y a los países en desarrollo les resulta especialmente difícil responder a este reto.

5.- Se corre el riesgo de que estas disparidades mundiales se vuelvan permanentes y, si no se actúa de manera que se cambie radicalmente la vida de los pobres del mundo pueden perder la fe en sus representantes y en los sistemas democráticos con los cuales se está comprometido, y empezar a sentir que sus representantes vienen a ser sólo metal que resuena o címbalo que retine.

4.4.5.2.- COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

1.- Velar para que la rica diversidad, fuente de fuerza colectiva, sea utilizada en una alianza constructiva para el cambio y para la consecución del objetivo común del desarrollo sostenible.

2.- La Cumbre de Johannesburgo centró la atención en la indivisibilidad de la dignidad humana decidiendo los países participantes resolver, mediante la adopción de decisiones sobre objetivos, calendarios y asociaciones para la colaboración, aumentar rápidamente el acceso a servicios básicos como el suministro de agua potable, saneamiento, energía, atención de la salud, seguridad alimentaria y protección de la biodiversidad. Al mismo tiempo colaborar para ayudarse unos a otros a tener acceso a recursos financieros, beneficiarnos de la apertura de mercados, lograr la creación de capacidad, utilizar la tecnología moderna para lograr el desarrollo y asegurarse de que haya transferencia de tecnología, desarrollo de los recursos humanos, educación y capacitación a fin de erradicar para siempre el subdesarrollo.

3. - Comprometiéndose a asegurar que la potenciación y emancipación de la mujer y la igualdad de los sexos sean integradas en todas las actividades abarcadas por el Programa 21, los objetivos de desarrollo del Milenio y el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre.

4.- Reconocieron la realidad de que la sociedad global tiene los medios y está dotada de los recursos para recoger los retos de la erradicación de la pobreza y el logro del desarrollo sostenible a que hace frente toda la humanidad. Unidos se tomarán las medidas adicionales para velar por que estos recursos disponibles sean aprovechados en beneficio de toda la humanidad.

5.- Se libró una exhortación a los países desarrollados que no lo hayan hecho a que hagan esfuerzos concretos por alcanzar los niveles internacionalmente convenidos de asistencia oficial para el desarrollo, a fin de lograr las metas y objetivos propuestos

6.- Se aupó y apoyó la aparición de agrupaciones y alianzas regionales más fuertes, como la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, para promover la cooperación regional, una mayor cooperación internacional y el desarrollo sostenible.

7.- Se reconoció la necesidad de prestar especial atención a las necesidades de desarrollo de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados.

8.- Igualmente, que el desarrollo sostenible exige una perspectiva a largo plazo y una amplia participación en la formulación de políticas, la adopción de decisiones y la aplicación a todos los niveles. Como colaboradores sociales, seguiremos bregando por la formación de asociaciones estables con todos los grandes grupos, respetando el importante papel independiente que desempeña cada uno de ellos.

9.- Convinando que en la realización de sus actividades legítimas el sector privado, incluidas tanto las grandes empresas como las pequeñas, tiene el deber de contribuir a la evolución de comunidades y sociedades equitativas y sostenibles.

10. También se convino en prestar asistencia a fin de aumentar las oportunidades de empleo generador de ingresos, teniendo en cuenta la Declaración de Principios de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Derechos Fundamentales en el Trabajo.

11.- Además, en que es necesario que las empresas del sector privado cumplan la obligación de rendir cuentas, rendición que ha de tener lugar en un entorno reglamentario transparente y estable.

4.4.5.3.- EL MULTILATERALISMO ES EL FUTURO

1.- Se abogó por fortalecer y mejorar la gobernanza en todos los planos para lograr la aplicación efectiva del Programa 21, los objetivos de desarrollo del Milenio y el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre. El multilateralismo es el futuro

2.- Se aspiró que para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, se necesita instituciones internacionales y multilaterales más eficaces, democráticas y dispuestas a rendir cuentas.

3. Se reafirmó la adhesión a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional así como al fortalecimiento del multilateralismo. Apoyando la función rectora de las Naciones Unidas que, por ser la organización más universal y representativa del mundo, es la más indicada para promover el desarrollo sostenible.

4. comprometiéndose, además a vigilar periódicamente el avance en la persecución de los objetivos y metas de desarrollo sostenible.

4.4.5.4.- CÓMO LOGRARLO

1. Acordaron en que debe ser éste un proceso inclusivo, con intervención de todos los grandes grupos y Gobiernos que participaron en la histórica Cumbre de Johannesburgo.

2. Se comprometieron a trabajar juntos, unidos con la determinación común de salvar el planeta, promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la paz universales.

3. Comprometiéndose una vez más a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a acelerar la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos fijados.

4. Desde el continente africano, cuna de la humanidad, pse prometió solemnemente a los pueblos del mundo y a las generaciones que heredarán la tierra, que se está decidido a velar por que se haga realidad nuestra esperanza colectiva de un desarrollo sostenible.²⁶

La Declaración Política y el Plan de Acción fueron los acuerdos más relevantes; aunque se consideran que sólo contiene buenas intenciones soslayando compromisos concretos y contundentes, así como la precaución de nuevos fondos; lo más significativo estuvo signado por la ratificación del Protocolo de Kyoto por varios países, poniendo en evidencia la tozudez de algunos países de no suscribir ni ratificar este importante instrumento; para algunos analistas la Cumbre de Johannesburgo fue un fracaso.

Además, de las emblemáticas Cumbres, Conferencias, y Declaraciones descritas y analizadas incluyendo el Protocolo de Kyoto. A posteriori, se han celebrados otros eventos similares en concordancia con la problemática *in comento*, tal como la Cumbre de Nueva York (2002), donde nuevamente 189 Jefes de Estado se reunieron a fin de concertar acerca de (...) problemas

26 <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N02/578/86/PDF/N0257886.pdf?OpenElement>

climáticos, principales problemas ambientales desertización, bosques donde también se propusieron medidas para cubrir la necesidad de desarrollo, mejoramiento y garantía de servicios ambientales a gran parte de la población del mundo en vista de la carestía del servicio del agua.²⁷

En noviembre de 2006 del 6 al 17 se convocó nuevamente en Nairobi la XII Conferencia sobre el cambio climático, de los países firmantes del protocolo de Kyoto. Asistieron 180 países y concluyó con la aprobación de una nueva revisión del Protocolo de Kyoto en el 2008 para reducir la emisión de gases contaminantes. En Nairobi se los asistentes se propusieron evitar un vacío temporal entre el primer periodo de compromisos y el segundo, que se fijará en el tratado que sustituya a Kyoto. La Conferencia también aprobó que el “Mecanismo de Desarrollo Limpio” (MDL), que entonces sólo tenía 9 de 400 proyectos en África, fuera más equitativo geográficamente.²⁸

4.4.6.- CUMBRE DE COPENHAGUE

En Copenhague, capital de Dinamarca, se realizó del 7 al 18 de diciembre de 2009 la Cumbre, en la cual se disertaría acerca de un tratado internacional que comprometa a todos los países del mundo, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; con motivo de vencerse en el 2012 las pretensiones de Kyoto. Los líderes mundiales tuvieron en Copenhague la oportunidad de proponer y asumir un cambio de modelo que olvidara el motor que ha alimentado el crecimiento en los últimos siglos y ha generado todo un trastoque en el clima; el cambio de paradigma es menester que ocurra de un modo consensuado que satisfaga a todos, que comprometa a cada Estado a cumplir. “Los problemas que hoy nos afligen no atañen simplemente a los países en singular, sino a toda la humanidad, no sólo a los próximos años, sino a los próximos siglos; no únicamente a las próximas elecciones, sino a todas las generaciones futuras. Los problemas planetarios -el calentamiento global, la ampliación de las desigualdades sociales e incluso biológicas, el desigual acceso al conocimiento y a sus productos, las fuertes migraciones internas y entre distintos países-, obligan a cada presidente, rey, jeque, primer ministro a postularse no simplemente como un líder de su país, de su población y de su tiempo, sino también como uno de los líderes del mundo y de la humanidad”²⁹. Los Estados Unidos hoy día con un Presidente erigido líder mundial y recién premio Nobel de la Paz, junto con China no han sido precisamente los modelos en la protección del medio ambiente, y consecuentemente en torno al tema en cuestión en el cuidado de la vida planetaria; por lo que desde el país más pequeño y pobre tiene todo el derecho y deber de alzar su voz para hacerse escuchar, especialmente en estos eventos.

Aramis Latchinian en su libro *Globotomía*; es crítico a la celebración de estas Cumbres proponiendo que: “La extinción de especies provocada por el Hombre es sin dudas una problemática grave sobre la cual es imprescindible continuar trabajando, pero comenzar a hacer cumbres mundiales y financiar

27 Op. Cit: 134

28 http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php

29 Elpais.com15/12/2009

investigaciones millonarias para salvar al oso panda es una burla que no admite discusión. Llamemos a las cosas por su nombre y busquemos las causas de la extinción en una economía mundial basada en el lucro y en el crecimiento indefinido en lugar de basarse en la satisfacción de las necesidades humanas. Urge ordenar nuestras prioridades ambientales locales, que tienen que ver con la basura, cursos de agua contaminados, con los asentamientos humanos y con la pobreza.”³⁰

Los resultados de Copenhague; no fueron satisfactorios, mostrando los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) su preocupación para que exista un resultado balanceado y efectivo en Cancún donde se llevará a cabo la próxima Cumbre; insistiendo en la necesidad del compromiso sobre todo de los países más contaminadores “para salvar a la humanidad y a nuestra Madre Tierra”³¹

4.5.- RECEPCIÓN EN EL DERECHO INTERNO LATINOAMERICANO DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

El mensaje propuesto en los anteriores instrumentos internacionales ha ido penetrando en el en el derecho interno, a tenor de esto se expresa Barbé (2005) “El medioambiente se ha insertado de forma paulatina en la agenda de las relaciones internacionales, ha evolucionado como *issue* y ha sufrido numerosos ascensos y descensos en la lista de prioridades de los Estados y del resto de los actores internacionales” (p. 317); de allí emana la necesidad de esbozar como ha sido a nivel latinoamericano esta apertura hacia la protección ambiental en consonancia con el derecho a la vida y el deber para con las futuras generaciones; previsto en algunas de manera explícita en otras implícita, pero lo que es indubitable es la acogida a esta preocupación global en los diferentes ordenamientos jurídicos Latinoamericanos; así se tiene por ejemplo:

4.5.1.- CONSTITUCIÓN ARGENTINA

El artículo 41 preceptúa el derecho de gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; estableciendo el deber de preservarlo; otorgándole la potestad al Poder Legislativo de legislar respecto a la obligación de reparar el daño ambiental.³²

4.5.2.- CONSTITUCIÓN DE BRASIL

En su artículo 225, también acoge el derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado concediéndole importancia para una sana calidad de vida

30 <http://globotomiasur.wordpress.com/>

31 <http://cmpcc.org/2010/10/06/discurso-del-alba-sobre-protocolo-de-kioto-kp/#more-2373>

32 Op.cit. 95

e igualmente le impone al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras³³.

4.5.3.- CONSTITUCIÓN DE CHILE

En su Constitución de 1980 en el artículo 19, numeral 8 prevé que el Estado protege el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación y tutela la preservación de la naturaleza.³⁴

4.5.4.- CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA

Artículos 79 al 82; estipula derecho de gozar de un ambiente sano subrogándose el Estado el deber que tiene que proteger el Ambiente con la planificación y el manejo además del aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible y su conservación; prohibiendo las armas nucleares y bioquímicas; prohibiendo al país el ingreso de sustancias tóxicas.³⁵

4.5.5.- CONSTITUCIÓN DE COSTA RICA

Formula en el segundo aparte del artículo 50 la garantía por parte del Estado a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; concediendo a toda persona afectada el derecho de denunciar cualquier infracción a esa prerrogativa y a exigir la debida reparación del daño causado.³⁶

4.5.6.- CONSTITUCIÓN DE GUATEMALA

También se circunscribe en el ámbito de preservar el ambiente, a fin de mantener el equilibrio ecológico promoviendo sancionar las normas necesarias para garantizar el aprovechamiento de la fauna, flora, agua y tierras evitando su depredación (Artículo 97).³⁷

4.5.7.- CONSTITUCIÓN DE HONDURAS

En el artículo 145 el derecho a un ambiente sano, imponiéndolo también como un deber personal y comunitario; además en el artículo 340 se declara la reforestación del país y la conservación de bosques de conveniencia nacional y de interés colectivo.³⁸

33 Ib. 214

34 Ib. 361

35 Ib. 248

36 Ib. 316

37 Ib. 494

38 Ib. 546

4.5.8.- CONSTITUCIÓN DE MÉXICO

Artículo 4 reformado: derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Artículo 25: bajo los criterios de productividad se apoyará a las empresas sujeto al cuidado de la conservación del medio ambiente

Artículo 27 reformado: incorporación el concepto de sustentabilidad.

Artículo 76: el congreso tiene la facultad de: g. expedir leyes en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico

Art. 115: organización territorial III los municipios sus funciones y servicios públicos: c) recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos

Art. 122: el gobierno federal se sujeta a lo siguiente j) legislar en materia de planeación del desarrollo en uso del suelo, preservación del medio ambiente y protección ecológica.³⁹

4.5.9.- CONSTITUCIÓN DE PANAMÁ

Contiene preceptos ambientales previstos en el Título II, Capítulo 7° del Régimen ecológico donde en los artículos 114-115 se le confiere al Estado el deber fundamental de garantizar el derecho de habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado; asociando en este deber a todos los habitantes con el objetivo de prevenir la contaminación del ambiente y evitar con esto la destrucción de los ecosistemas.⁴⁰

4.5.10.- CONSTITUCIÓN DE PARAGUAY

Establece en su artículo 7 el derecho de habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado; son objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación y la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como conciliación con el desarrollo humano integral. Además, en el artículo 8 prevé la protección ambiental mediante regulación legislativa de aquellas las actividades susceptibles de producir una alteración ambiental, igualmente impone la prohibición de las armas nucleares, químicas y biológicas y otros elementos peligrosos como el tráfico de recursos genéticos.⁴¹

4.5.10.- CONSTITUCIÓN DE PERÚ

En los artículos 66 al 69 contiene normas donde el Estado se reserva los recursos naturales y renovables como patrimonio de la Nación, con la potestad de implementar las políticas ambientales promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales; incluso el desarrollo sostenible de la Amazonia.⁴²

39 <http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/26.htm?s=>

40 Ib. 706

41 Ib. 742

42 Ib. 798

4.5.11.- CONSTITUCIÓN DE VENEZUELA

Ya en la Exposición de Motivos como (...) una expresión de la intención subjetiva del Constituyente (...) ⁴³ al referirse al derecho a la educación muestra la articulación constitucional ⁴⁴ venezolana en materia ambiental; de esta manera traza un rumbo:

*(...) Se proclama la educación como un derecho humano y como un deber constitutivo de la raíz más esencial de la democracia y se le declara gratuita obligatoria, y la asume el Estado como función indeclinable de servicio público (...) Para ser incluidas en los diseños curriculares, se le dio rango constitucional a las **materias relativas al ambiente**, a lo lingüístico y a lo neohistórico (...)* (Negrillas de la tesista).

De esta manera la educación ambiental debe ser prioritaria en el proceso formativo integral de los individuos; haciéndose parte tangencial del sentido humanista constitucional; anhelo también propuesto en el Preámbulo cuando se aspira a (...) el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad (...).

Si bien es cierto que una de las conquistas más encomiables de la Constitución de 1999 es la afirmación de los derechos humanos, en lo atinente a la protección ambiental como un Derecho Humano, es primigenia respecto a sus antecesoras, así en el Título III Capítulo IX referente a los Derechos Ambientales, concretamente en el artículo 127 consagra: *“Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”*

La transversalidad que caracterizan los postulados constitucionales de acuerdo a su coyuntura partiendo de la Exposición de Motivos, siguiendo con el preámbulo como parte integrante del bloque de la constitucionalidad existen una serie de normas que forman un racimo conexo que otorgan un sustento básico y fundamental histórico en el contexto jurídico venezolano, así se presentan conectados entre otros que pudieran mencionarse los artículos: 15, 107, 112, 119, 120, 127, 128, 129, 153, 178, 184, 299, 304, 307 y 326, los cuales de una u otra forma tienen repercusión o injerencia en asuntos ambientales; (...) las normas constitucionales conectan entre sí porque les inspira una misma ratio, una razón de ser y se fundamentan, axiológicamente (...) (Op. cit. P. 29); en Venezuela existe todo un entramado constitucional y legal que le dan vida a todo lo que implica la tuición ambiental; desde concebirlo como patrimonio de la humanidad, conector integracionista, un deber para las generaciones futuras a su vez se conjugan elementos que conllevan a discernir sobre el desarrollo sustentable, solidaridad, paz etc.

43 <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/decisiones.shtml>. Sentencia N° 93 del 06/02/2001

44 Lucas Verdú, Pablo: “La articulación constitucional formal manifiesta la coherencia lingüística y lógica de las normas fundamentales”. Teoría general de las articulaciones constitucionales. Editorial Dykinson, S.L Madrid. 1998 (p.27)

4.6.- LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO EUROPEO

El punto de arranque de la política de protección penal medioambiental en el ámbito europeo es la Resolución del Consejo de Europa 28/1977, sobre la Contribución del Derecho penal a la protección del Medio Ambiente, en la que se recomienda a los Estados miembros la criminalización de las actividades contaminantes dolosas o imprudentes así como el uso de sanciones penales cuando se produzcan agresiones al medio ambiente, ya sean las clásicas (penas privativas de libertad y multas) u otras específicas, entre las que se enumeran la obligación de reparar o restaurar el daño causado, la clausura de establecimientos contaminantes, la inhabilitación de los responsables, la aplicación del importe de las multas a regenerar los daños ambientales, etc. Asimismo, se recomienda la revisión del proceso penal para adaptarlo a las particularidades del Derecho Ambiental, potenciándose la creación de Fiscalías, Tribunales Especiales y de unidades especializadas de Policía Judicial.

Una segunda Resolución del Consejo de Europa, la 1/1990, relativa a la protección del Medio Ambiente a través del Derecho penal actualizó las recomendaciones de la anterior, estableciéndose la necesidad de elaborar un listado de tipos penales en los que se asegurase la protección adecuada al medio ambiente y a sus elementos integrantes (agua, aire, suelo, flora y fauna, así como a las personas); la regulación de las infracciones penales a través de tipos de peligro (abstracto, concreto o potencial); la delimitación en materia ambiental entre delitos (Derecho penal) e infracciones administrativas (Derecho administrativo) sobre la base de la gravedad y al riesgo de los comportamientos y, por último, en lo relativo a la persecución se recomienda que sea posible no sólo en los países donde se ha cometido el hecho sino también que se pueda perseguir en los países en donde se hubiesen producido daños, resultado o consecuencias, sin perjuicio de la aplicación del principio *no bis ídem*.

Dos tratados internacionales se han concluido bajo la égida del Consejo de Europa: la Convención sobre responsabilidad civil por daños resultantes y actividades peligrosas para el medio ambiente, pero quizás, donde con mayor claridad se vean reflejadas las propuestas de las anteriores resoluciones sea en el Convenio del Consejo de Europa, de 4 de noviembre de 1998, sobre la protección del medioambiente, a través del Derecho penal.

Tras la celebración de la 17 Conferencia de Ministros europeos de Justicia, en Estambul, en 1991, el Comité de Ministros del Consejo de Europa impulsó la creación de lo que inicialmente se denominó "Grupo de especialistas sobre la protección del medio ambiente a través del Derecho penal" y que, posteriormente, se transformó en un Comité de expertos tradicional. Dicho Comité trabajó -de octubre de 1991 a diciembre de 1995- en el proyecto que fue aprobado por el Comité de Ministros en junio de 1996. Para ello, en esos cuatro años se crearon diez grupos de trabajo y tuvieron lugar siete reuniones plenarias. El objetivo era plantear abiertamente el recurso al Derecho penal, establecer unas directrices comunes para luchar contra los atentados al medioambiente, y más particularmente: a) Elaborar una lista de infracciones con la finalidad de proteger penalmente los valores ambientales: el agua, la tierra, el aire, la flora y la fauna u otros componentes del medioambiente, así como a la persona humana; b) La creación de tipos de peligro (concreto, abstracto o potencial) independiente del daño efectivo; c) Definir la relación

entre el Derecho penal y el Derecho administrativo en materia ambiental; d) Tomar en consideración, de cara a la persecución o a la sanción, las actuaciones del delincuente para evitar el peligro o el daño resultante de la infracción; e) La posibilidad de aplicar los Convenios europeos en el ámbito penal a las cuestiones de criminalidad ambiental, cooperación internacional, competencia jurisdiccional, conflictos de competencia, lugar de la comisión de la infracción, así como a otras cuestiones pertinentes relativas al Derecho penal internacional, que conciernen al medioambiente.

La aprobación del Acta Única Europea en el mes de febrero de 1986 y su entrada en vigor el 1 de julio de 1987, supuso, por tanto, que la política ambiental fuese reconocida como uno de los objetivos principales de la U.E., hasta el punto, que se ha proclamado que ha de ser un componente esencial en las demás políticas de la Comunidad, o lo que es lo mismo: se antepone, en primer término, la protección del medio ambiente ante cualquier agresión de la política económica, agrícola, ganadera etc. Por lo tanto, la integración de la política ambiental dentro del resto de políticas comunitarias es fundamental ya que es la única que se impone al resto de las políticas como una exigencia.

Los objetivos del Acta Única son: 1- Conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente; 2- Contribuir a la protección de la salud de las personas; 3- Garantizar una utilización prudente y racional de los recursos naturales.

Se pretende, de esta manera, por un lado, uniformar el Derecho de los Estados miembros, así como racionalizar la utilización de los recursos naturales comunitarios, y por otro, que los Estados asuman las repercusiones medioambientales contaminantes.⁴⁵

La Unión Europea continúa poniéndose tono en su Tratado de Funcionamiento al modificar el artículo 174 reformulándolo como sigue:

En el apartado 1, el cuarto guión se sustituye por el texto siguiente: el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente, y en particular a luchar contra el cambio climático. También en el Título XX referido a la energía describe la forma de lograr los objetivos propuestos; de esta forma regula en su artículo 176 A

1. En el marco del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior y atendiendo a la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente, la política energética de la Unión tendrá por objetivo, con un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros:

- a) garantizar el funcionamiento del mercado de la energía;
- b) garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión;
- c) fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético así como el desarrollo de energías nuevas y renovables; y
- d) fomentar la interconexión de las redes energéticas.⁴⁶

Se observa, como en el transcurso de los años los paradigmas han cambiado; constituyéndose la protección al ambiente en un hito sobre el cual deben girar

45 http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/21/03_derecho_y_medioambiente.html

46 http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_es.htm

las otras actividades propias del sistema comunitario europeo; es decir un bien jurídico primo entre sus pares.

Además, del contexto comunitario en varios países de la unión se ha constitucionalizado la protección ambiental como un derecho humano, un deber del Estado y de todas las personas y más aún en resguardo de las generaciones futuras; así pueden mencionarse por ejemplo, entre otras la Constitución de: Alemania.

“La Ley Fundamental de Bonn (Alemania), tampoco recogió inicialmente el derecho al medio ambiente aunque jurisdiccionalmente se aceptó el derecho a su protección. Posteriormente y con las enmiendas a dicha Ley Fundamental, se inserta el artículo 20 en el que se prescribe que en el marco del orden constitucional y teniendo en cuenta su responsabilidad para con las generaciones futuras, el Estado protege las condiciones naturales indispensables para la vida. La incorporación de este artículo a la Ley Fundamental alemana no estuvo falta de polémicas entre los distintos partidos políticos acerca de la naturaleza del derecho al medio ambiente así como su finalidad.”⁴⁷

España.

Artículo 45 de la Constitución (Cap. III, Tít. I): 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.⁴⁸

Grecia.

Artículo 24, numeral 1. “Constituye obligación del Estado la protección del ambiente natural y cultural. El Estado estará obligado a adoptar medidas especiales, preventivas o represivas, con vistas a la conservación de aquél. La ley regulará las modalidades de la protección de los bosques y de los espacios forestales en general. Queda prohibida la modificación del destino de los bosques y espacios demaniales forestales, salvo si su explotación agrícola tuviese más valor desde el punto de vista de la economía nacional o si cualquier otro uso resultara necesario con vistas al interés público”.⁴⁹

47 <http://www.eumed.net/rev/oidles/06/obhp.htm>.

48 <http://constitucion.rediris.es/legis/1978/ce1978.html>

49 <http://www.eft.com.ar/legislac/constit/grecia.htm>

Polonia.

Artículo 31, numeral 3.- Cualquier limitación en el ejercicio de las libertades constitucionales y los derechos sólo podrá imponerse por ley, y sólo cuando sea necesario en un Estado democrático para la protección de su seguridad o el orden público, o para proteger el medio ambiente, la salud o la moral pública, o las libertades y los derechos de otras personas. Estas limitaciones no violará la esencia de las libertades y derechos.

Artículo 74

- 1.- Las autoridades públicas deberán promover políticas adecuadas para la seguridad ecológica de las generaciones actuales y futuras.
2. La Protección del medio ambiente será el deber de los poderes públicos.
- 3.- Toda persona tiene derecho a ser informado de la calidad del medio ambiente y su protección.
- 4.- Las autoridades públicas deberán apoyar las actividades de los ciudadanos que protejan y mejoren la calidad del medio ambiente⁵⁰

y Portugal.

Artículo 66

1. Todos tienen derecho a un medio ambiente de vida humano, salubre y ecológicamente equilibrado, y el deber de defenderlo.
2. Para asegurar el derecho al medio ambiente, dentro del marco de un desarrollo sustentable, le corresponde al Estado, mediante organismos propios y con la implicación y la participación de los ciudadanos:

Prevenir y controlar la contaminación y sus efectos y las formas perjudiciales de erosión;

Ordenar y promover la ordenación del territorio, teniendo como objetivo una correcta localización de las actividades, un desarrollo socioeconómico equilibrado y la valoración del paisaje;

Crear y desarrollar reservas y parques naturales y de recreo, así como clasificar y proteger paisajes y lugares, de manera a que se garantice la conservación de la naturaleza y la preservación de valores culturales de interés histórico o artístico; Promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales, salvaguardando su capacidad de renovación y la estabilidad ecológica, respetando el principio de la solidaridad entre las generaciones;

Promover, en colaboración con las entidades locales, la calidad ambiental de las poblaciones y de la vida urbana, especialmente en el plan arquitectónico y en el de la protección de las zonas históricas;

Promover la integración de objetivos ambientales en las diversas políticas de ámbito sectorial;

50 www.poland.gov.pl/theconstitution,384.htm

Promover la educación ambiental y el respeto a los valores del medio ambiente y el respeto a los valores del medio ambiente.⁵¹

4.7.- CARTA AFRICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

También llamada carta de Banjul, reconoce el derecho a un medio ambiente sano en su artículo 24, afirmando: “todos los pueblos tienen el derecho a un satisfactorio medio ambiente favorable para el desarrollo”; en congruencia con los artículos 1 y 25 los cuales contemplan la obligación para los Estados Partes de velar por el respeto al medio ambiente; imponiéndose la obligación de educar a los pueblos africanos en la materia relativa al medio ambiente sano como un derecho protegido en dicha Carta.

4.8.- PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

Como desarrollo de la Convención Americana (Pacto de San José) en lo referido a los derechos económicos, sociales y culturales se proclamó el Protocolo de San Salvador (1988), en el mismo se establece en artículo el derecho a un ambiente sano en el entorno regional; previendo en su artículo 11, que:

- 1.- Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.
- 2.- Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Siendo impremitible para los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos legislar en torno a este derecho, para concretar su efectividad en el marco del artículo 2 que operativiza la norma.⁵²

La globalización, por sus cambios en las nociones de espacio, tiempo, soberanía y fronteras, implica entonces un cambio en el planteamiento teórico de las relaciones internacionales. Esto supone, en la integración de acuerdo a Casal (2006) “La incorporación de los derechos humanos dentro de estos procesos, con las consecuencias que entraña, propende a consolidar las integración, pues supone la introducción de un elemento ético-jurídico que proporciona legitimidad y que ofrece sólidas bases para la intensificación de la integración”. (p. 210).

Si bien es cierto que estas Cumbres han sido convocadas bajo la égida de la ONU un organismo multilateral, no es menos cierto que existen una relación estrecha para superar los avatares del cambio climático entre diferentes elementos como son: lo económico, la política, lo social, lo cultural e ideológico; por esta razón es menester analizar esta correspondencia

51 http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Constitution_of_Portugal#Constitution_of_1976

52 <http://www.analitica.com/va/internacionales/document/6765002.pdf>

4.9.- INTERRELACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA, SOCIAL, CULTURAL E IDEOLÓGICA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático y sus secuelas van unidas intrínsecamente con lo económico, lo político, lo cultural, lo social y hasta lo ideológico etc, no se puede visualizar desde una sola óptica una realidad compleja; pero sin embargo la economía y la política son aspectos relevantes en el tópico en cuestión y al respecto por ejemplo, Toharia indicó en su libro 'El clima', donde denuncia la importancia de la problemática causada por el cambio climático, además de pronunciarse acerca de otros conflictos como el terrorismo, el hambre o las cabezas nucleares que están desarrollando determinados países, el científico enfatiza sobre la necesidad de realizar cambios sustanciales en el modelo económico que sustenta el desarrollo y en la forma en la que se utiliza la energía y se consumen bienes y servicios que nunca podrán retornar; incluso propone desarrollar una innovación que florezca (...) "en un contexto que excluya todo el sustrato desarrollista a ultranza que nos ha venido caracterizando en los dos últimos siglos y que es típico de un sistema económico mundial regido por la ley del mercado capitalista"⁵³. En este sentido, el informe Stern⁵⁴ en sus conclusiones ha sido preciso y destacó en primer lugar, después de llevar a cabo un análisis minucioso sobre las consecuencias físicas que influyen por las actividades económicas, sobre la vida humana y sobre el medio ambiente. Que las temperaturas medias globales aumentarán en 2-3°C en los próximos cincuenta años, aproximadamente⁵⁵ y, si las emisiones siguen aumentando, la Tierra experimentará un aumento de varios grados más en la temperatura.

Este calentamiento tendrá múltiples y graves consecuencias, a menudo relacionadas con el agua, así se tiene que:

- Inicialmente, la fusión de los glaciares aumentará el peligro de inundaciones y, a continuación, el suministro de agua se verá considerablemente reducido. En su día, ello amenazará al 16,5% de la población mundial y, en particular, a la del subcontinente indio, ciertas partes de China y la región andina de Sudamérica.
- Como consecuencia de la reducción en el rendimiento de las cosechas, especialmente en África, cientos de millones de personas podrían quedar sin capacidad para producir o adquirir alimentos suficientes. Aunque es posible que, en latitudes medias y altas, el rendimiento de los cultivos se incremente con aumentos moderados de la temperatura (2-3°C), se verá reducido a temperaturas más altas. Con aumentos de 4°C en adelante, es probable que la producción alimenticia mundial se vea seriamente afectada.
- En las latitudes más altas, disminuirá el número de fallecimientos

53 http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/9830_manuel-toharia-denuncia-un-alarmismo.shtml

54 [http://calentamientoglobalclima.org/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/Informe Stern, encargado por el Gobierno Británico en 2006 a un equipo dirigido por el economista Nicholas Stern](http://calentamientoglobalclima.org/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/Informe%20Stern,%20encargado%20por%20el%20Gobierno%20Brit%C3%A1nico%20en%202006%20a%20un%20equipo%20dirigido%20por%20el%20economista%20Nicholas%20Stern)

55 Todos los cambios en la temperatura global media se expresan en relación con los niveles preindustriales (1750 - 1850).

debidos al frío, pero, al mismo tiempo, el cambio climático resultará en un aumento en el número mundial de muertes, como consecuencia de la desnutrición y del estrés térmico. Enfermedades transmitidas por vectores, tales como la malaria y el dengue, podrían hacerse más prevalentes, si no se cuenta con medidas eficaces de control.

- La elevación del mar hará que cada año haya entre decenas y cientos de millones más de personas afectadas por las inundaciones, si las temperaturas aumentan en 3 ó 4°C. Se producirán graves riesgos y aumentarán las presiones para la protección costera en el sureste asiático (Bangladesh y Vietnam), en las pequeñas islas del Caribe y del Pacífico y en las grandes ciudades costeras, tales como Tokio, New York, El Cairo y Londres. De acuerdo con una de las previsiones, para mediados de siglo, es posible que 200 millones de personas se vean permanentemente desplazadas como consecuencia del aumento experimentado en el nivel del mar, inundaciones más devastadoras y sequías más intensas.
- El cambio climático afectará, en particular, a los ecosistemas ya que, tras un calentamiento de 2°C solamente, entre el 15 y 40% de las especies se verán expuestas a posible extinción. Por otra parte, la acidificación de los océanos –consecuencia directa del aumento en los niveles de anhídrido carbónico– tendrá serias repercusiones para los ecosistemas marinos y posibles consecuencias nocivas sobre las poblaciones de peces.

A tenor de lo anterior, el mismo informe presenta alternativas ante las catástrofes inminentes que acechan a la humanidad, enunciando que aún a pesar de esta correlación histórica y de las proyecciones de un escenario BAU⁵⁶ el mundo no tiene que elegir entre evitar el cambio climático y promover el crecimiento y el desarrollo. Los cambios introducidos en las tecnologías energéticas y en la estructura de las economías han reducido la correlación entre emisiones y crecimiento de los ingresos, particularmente, en algunos de los países más ricos. Unido a las exhortaciones económicas van las políticas señalando el mencionado informe las siguientes:

a.- El primer elemento de política es la asignación de un precio al carbono. En términos económicos, los gases invernadero son una externalidad: quienes producen emisiones de gases invernadero están contribuyendo al cambio climático y, en consecuencia, imponiendo costes al mundo y a las futuras generaciones, sin que ellos tengan que hacer frente plenamente a las consecuencias de sus acciones.

La asignación de un precio apropiado al carbono (explícitamente), mediante impuestos al comercio, o (implícitamente) mediante reglamentación significa que la gente tiene que hacer frente al entero coste social de sus acciones.

b.- El segundo elemento de la política sobre el cambio climático es la política tecnológica. Que abarca el espectro entero, es decir, desde la investigación y el desarrollo, hasta la demostración y etapas iniciales de su aplicación. El desarrollo y aplicación de una amplia gama de tecnologías bajas en carbono es un factor esencial para lograr las importantes y necesarias reducciones en las emisiones

56 Escenario BAU o Business As Usual; escenario sin política de restricción en las emisiones

c.- El tercer elemento esencial (eliminación de las barreras al cambio de comportamiento). Es particularmente importante para el fomento de la aceptación de oportunidades de eficiencia energética la eliminación de barreras al cambio de conducta. Entre dichas barreras se cuentan la carencia de información segura. En relación a las medidas que las comunidades y países pueden adoptar por sí solos para hacer frente al cambio climático; se ha pronunciado Pineda (2007).

El Mercado de Carbono no evita los impactos del Cambio Climático ni suaviza los efectos, pero trata de equilibrar el compromiso de los países industrializados del Norte con los proveedores de las materias primas del Sur, mediante la compra de la capacidad de absorción de carbono con plantaciones forestales y la venta de emisiones de CO₂, incluyendo el desarrollo de energías alternas con especial énfasis en biocombustibles. Se busca utilizar los bosques como reservorios de carbono en compensación por la contaminación industrial, para esto se facilitan subsidios estatales, créditos de la banca multilateral, y ganancias directas en desarrollos ecológicos sustentables en los países del Sur. Con el protocolo de Kyoto, el mercado del carbono se ha intensificado, por la obligación de reducir emisiones de los estados miembros en un promedio de 5.2% con respecto a los niveles del año 1.990, mientras que los países en desarrollo pueden contribuir con actividades que reduzcan o absorban el Gas Efecto Invernadero. Como complemento a la reducción de emisiones del GEI, se establece el mercado global de comercialización de permisos y/o créditos de carbono con los Mecanismos para un Desarrollo Limpio, con beneficios reales y duraderos para el clima tanto por reducción como por absorción de emisiones de GEI. Este mecanismo de implementación permite reducir emisiones utilizando sumideros en países en desarrollo y comercio de derecho de emisiones para países y empresas que puedan intercambiar libremente dentro de los términos del Protocolo.⁵⁷

De hecho, son ya muchos los países, estados y compañías que han puesto manos a la obra. A pesar de ello, las emisiones de la mayor parte de los países individuales son bajas, en relación con el total mundial. El informe Stern se hace eco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el Protocolo de Kioto y de una serie de asociaciones y diálogos informales que proporcionan un marco en apoyo de la cooperación y los cimientos sobre los cuales se pueden levantar nuevas medidas colectivas⁵⁸.

El cambio climático afectará más tempranamente y con mayor intensidad a los países en desarrollo más pobres, a pesar de que son los que menos han contribuido a causar el problema. Sus bajos ingresos dificultan la financiación de la adaptación, por lo que la comunidad internacional tiene la obligación de prestar apoyo a su adaptación al cambio climático. Sin dicho apoyo, existe un grave peligro de que su desarrollo se vea socavado.

⁵⁷ Globovision.com: 28/12/2007

⁵⁸ Op.cit: La Conferencia de Estocolmo de 1972 centraba la atención internacional en

El fomento y mantenimiento de una acción colectiva se ha convertido en un reto urgente.

Entre los elementos clave de cualquier medida colectiva se cuentan:

- el desarrollo de un entendimiento compartido de los objetivos de la política climática a largo plazo,
- la creación de instituciones eficaces de cooperación,
- la demostración de liderazgo y los esfuerzos para fomentar la confianza en otros.

Aunque todavía pueden evitarse las peores consecuencias del cambio climático, se necesita urgentemente una firme acción colectiva. Cualquier retraso sería costoso y lleno de peligro; al respecto uno de los países que propende a la contaminación y por ende a incidir en el cambio climático muestra señales de acatar tomar conciencia, así:

El 26/07/2009 (...) “Los líderes de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes trataban de conseguir los últimos votos necesarios para aprobar una ley que, por primera vez, impone unos límites a la emisión de gases contaminantes a centrales energéticas, fábricas y refinerías, e incluye una cuantiosa financiación para fomentar el cambio de un parque empresarial y de transporte basado en el carbón y otros combustibles fósiles, a uno de energías alternativas. El objetivo es reducir las emisiones de CO₂ en un 17% para 2020 y en un 83% para 2050 con respecto a los niveles de 2005. Se trata de un objetivo muy ambicioso para el país más contaminante del mundo. No es Kioto, pero casi: supone volver a la contaminación de 1990 y requiere un esfuerzo similar al que se ha marcado Europa, del 20%, para 2020. La norma, que necesitaba del apoyo de 218 diputados, creará un sistema comercial similar al que existe en otras regiones de compraventa de bonos contaminantes.

temas medio ambientales, especialmente los relacionados con la degradación ambiental y la 'contaminación transfronteriza'. Este último concepto era muy importante, ya que señalaba el hecho de que la contaminación no reconoce los límites políticos o geográficos y afecta a los países, regiones y pueblos más allá de su punto de origen. Durante las décadas que siguieron a la Conferencia de Estocolmo, este concepto se amplió para abarcar temas medio ambientales que son de verdadero alcance transnacional y que requieren una acción conjunta de todos los países y regiones del mundo para enfrentarse a ellos de un modo efectivo. Estos problemas medio ambientales mundiales tan importantes incluyen, por ejemplo, todo tipo de contaminación, el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, el uso y administración de los océanos y los recursos de agua dulce, la deforestación excesiva, la desertificación y la degradación de la tierra, los vertidos peligrosos y la disminución de la diversidad biológica. En los años que siguieron, también se reconoció que los problemas medio ambientales regionales o locales, como la urbanización extensa, la deforestación, la desertificación, y la escasez general de recursos naturales, se pueden extender hasta el punto de tener graves repercusiones para la seguridad internacional. Por ejemplo, socavan la base económica y la estructura social de los países y pobres, generan o exacerban las tensiones y los conflictos sociales y estimulan un mayor movimiento de refugiados. De este modo, la degradación ambiental en diversas partes del mundo desarrollado y en desarrollo puede afectar a los intereses políticos, económicos y sociales del mundo en su conjunto.

Según el texto propuesto por los demócratas Henry Waxman y Edward Markey, de 1.200 páginas, EE UU debería obtener el 6% su electricidad de energías renovables en 2012. A la ley le queda aún un largo recorrido antes de llegar al despacho del presidente Barack Obama, que la abrazó como bandera medioambiental de su campaña. Ahora, debe ser sometida a votación en el Senado, donde se espera un difícil debate. “Europa se ha adelantado a EE UU en este asunto en los pasados años”, dijo ayer Obama. “Yo soy el primero en admitir que EE UU, en los años pasados, no ha estado donde necesitaba estar”⁵⁹.

Pareciera una descripción apocalíptica lo sucedido recientemente debido al fenómeno “El Niño” en el continente americano con nieve, inundaciones y olas de calor:

“Ventiscas en los Estados Unidos, una ola de calor en Brasil, inundaciones mortales en México, sequía en Ecuador: las anomalías climáticas que se sienten estos días en el continente americano se deben a El Niño. El fenómeno climático, que suele perturbar cada dos a siete años los sistemas atmosféricos de las Américas, ha creado tormentas en todo el continente que desembocaron en situaciones de emergencia en varios lugares. Así, los habitantes de Nueva York y Washington fueron tapados bajo aluviones de nieve que obligaron a cerrar las escuelas, las oficinas del gobierno federal y la sede de la ONU. Los vuelos hacia Nueva York también sufrieron disturbios, indicó AFP

Al mismo tiempo, a miles de kilómetros de allí, Río de Janeiro sudaba bajo su peor ola de calor en 50 años, con temperaturas superiores a las del desierto del Sahara, según los servicios meteorológicos brasileños. El martes de hecho, ninguna parte del planeta superó los 46,3 grados Celsius (115 grados Fahrenheit) registrados alta, según datos de la Organización mundial de meteorología. En Santos (sur de Brasil), 32 ancianos fallecieron entre lunes y martes por el calor, indicó a la AFP el servicio municipal de salud. Al mismo tiempo, inundaciones mortales se registraron en otras regiones del continente. Las lluvias que llevan dos meses cayendo en el estado brasileño de Sao Paulo, cerca de Río de Janeiro, ya mataron a más de 70 personas.

En México, donde inesperadas lluvias cayeron en la mitad oeste del país, 42 cadáveres fueron sacados de casas afectadas por inundaciones. La saturación temporaria del sistema de canalizaciones de la capital mexicana y el desborde de aguas residuales condujeron a las autoridades a tomar medidas de emergencia. Otras 10 personas murieron en Bolivia, donde un diluvio afectó a 22.000 familias y dañó grandes extensiones de campo. En Perú, las autoridades tuvieron que enfrentar graves inundaciones que aislaron sus famosas ruinas incaicas de Machu Picchu, obligando a evacuar por aire a 2.200 turistas bloqueados el

59 <http://www.elpais.com>. Washington - 27/06/2009

mes pasado. En Argentina, el estado de emergencia fue declarado en Buenos Aires por temor a que el río Paraná se desbordara. En Ecuador, al contrario, el problema fue la falta de agua, no el exceso, con la peor sequía en este país andino desde hace 40 años.

Semejantes bajos niveles de agua en la principal planta hidroeléctrica de Venezuela obligaron al gobierno de Caracas a declarar la “emergencia eléctrica” el lunes. El centro de estudios climáticos y previsión meteorológica de Brasil anunció que El Niño seguiría afectando a Venezuela hasta fines de marzo, manteniendo condiciones climáticas muy secas en el norte del país.⁶⁰

El desarrollo de un país no sólo se hace operativo y viable por su progreso económico, es necesaria la imbricación de políticas públicas y tomen que trasciendan y tomen en cuenta los límites que las investigaciones científicas van delineando; no por ser un país con gran poder económico se tiene derecho a imponer a los demás perjuicios (...) los proyectos para un desarrollo humano integral no pueden ignorar a las generaciones sucesivas, sino que han de caracterizarse por la solidaridad y la *justicia intergeneracional*, teniendo en cuenta múltiples aspectos, como el ecológico, el jurídico, el económico, el político y el cultural.⁶¹ Todos estos tópicos inciden sobre la naturaleza humana, la misma que conforma el eje central sobre la cual gira la protección de los derechos humanos.

En materia de derechos humanos de acuerdo a la Resolución 32/130 de fecha 16 de diciembre de 1977:

a) Todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; deberá prestarse la misma atención y urgente consideración a la aplicación, la promoción y la protección tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales;

b) La plena realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible; la consecución de un progreso duradero en la aplicación de los derechos humanos depende de unas buenas y eficaces políticas nacionales e internacionales de desarrollo económico y social; como se reconoce en la Proclamación de Teherán de 1968

c) Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona humana y de los pueblos son inalienables

d) En consecuencia, las cuestiones de derechos humanos deberá examinarse e forma global (...) y la necesidad de promover la dignidad plena de la persona humana y el desarrolla y el bienestar de la sociedad

f) La realización del nuevo orden económico internacional es un elemento esencial para el fomento efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y deberá dársele prioridad;

g) Es de primordial importancia para el fomento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que los Estados Miembros asuman obligaciones específicas mediante la ratificación de los instrumentos

60 http://www.eluniversal.com/2010/02/11/int_ava_fenomeno-el-nino-afe_11A3419097.shtml

61 Op. cit: 77

internacionales en esta esfera o la adhesión a los mismos; por consiguiente, deberá alentarse la labor para el establecimiento de normas en la esfera de los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas y la aceptación y aplicación universales de los instrumentos internacionales pertinentes.⁶² Más aún, en la Resolución 63/278 en su Sexagésimo tercer período de sesiones la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el 22 de abril Día Internacional de la Madre Tierra (...) “Reconociendo que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, y convencida de que para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra (...) lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos”⁶³

Deslindar unos derechos de otros no cabe en materia de derechos transgeneracionales, se requiere la protección de un cúmulo de derechos para poder realmente hacerlos factibles, los derechos humanos parten de un tronco común de concepción filosófica y jurídica y todos concurren en la protección de la persona humana. En este sentido, las decisiones judiciales amparadas en criterios de avanzada progresividad tienen las herramientas en los diferentes instrumentos para no dejar a un lado la salvaguarda de los

derechos de las futuras generaciones; correspondiendo analizar y determinar como puede efectuarse esta tutela.

62 <http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/32/ares32.htm>

63 <http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r63sp.shtml>

CONCLUSIONES

La biosfera durante miles de años ha albergado en su sistema las condiciones para que los seres vivos incluyendo al Hombre puedan vivir; pero esta criatura "Imago Dei", por su acción y mala interpretación del dominio dado naturalmente, sus potencias inteligencia y voluntad unidas a la memoria lo hacen "superior", sin embargo esta superioridad biológica, lo ha llevado a hacer un mal uso de esos atributos. El ambiente que le rodea y que es su fuente de vida se encuentra amenazado y no por ninguna otro ser, sino el "Hombre".

Se han reconocido paulatinamente los derechos humanos como producto de la sensibilidad de admitir que existe una naturaleza humana imperecedera, que es la misma en: América como en Asia, Europa, África o la Oceanía, pero no basta con declarar en sendos tratados, pactos, convenciones, documentos o instrumentos jurídicos vinculantes o no que el Hombre por el sólo hecho de ser tal es merecedor de una protección especial, contra el mismo Hombre; ahora la lucha no es sólo contra el monarca absoluto o contra condiciones sociales, económicas y culturales adversas; el deber de "ahora" es conservar la "Madre Tierra" el único hogar.

La Organización de las Naciones ha aprobado Resoluciones como la 60/1 correspondiente al Documento Final de la Cumbre Mundial del 2005 donde reconoce "que el cambio climático es un problema grave y a largo plazo que puede afectar a todo el mundo", al referirse "a todo el mundo", indubitablemente pareciera signar sin distingo de raza, credo o condición social; sin embargo también es palmario que los países ricos los cuales ejercen una hegemonía económica han sido los más reacios a deponer su poderío en procura de "todos"; el cambio climático producido mayormente por unos pocos afecta a muchos. Un problema antropogénico también requiere una respuesta antropogénica; el causante del daño debe resarcirlo, se impone una nueva ética en clave ambiental sin la factibilidad de mecanismos coercitivos que se impongan a quien contamine, a quien emita la mayor cantidad de dióxido de carbono; a quien propicie cualquier actividad que vaya en detrimento del ambiente y como consecuencia amenace la vida del planeta; debe sentir la efectividad previsiva y coercitiva de sus acciones perniciosas. Por ello, se propone que ante una posible reforma de la Organización de las Naciones Unidas el poder de decisión no puede seguir en cónclave de cinco. La misma dinámica evolutiva pauta directrices que no pueden pasar desapercibidas, el derretimiento de las capas de hielo, la desaparición de glaciares está aumentando el nivel del mar afectando los ecosistemas e incrementando los riesgos para el normal desarrollo de las actividades humanas, la desertización crece, los deslaves e inundaciones son

de gran magnitud. Entonces, las decisiones y medidas que tiendan a proteger la biodiversidad que garantiza la vida no resisten maniobras ni postergación de las providencias adecuadas.

Se requiere anuencia y concordancia en lograr:

- 1.- Una verdadera comunidad mundial de vida
- 2.- Lealtad ambiental
- 3.- Justicia social
- 4.- Economía sustentable
- 5.- Fomento de valores democráticos

.No es un anhelo vacuo ni fugaz que sin la voluntad política formal pueda cristalizar, fortaleciendo los sistemas existentes o en su defecto crear una instancia coordinadora con poder y efecto vinculante. Las generaciones futuras, si bien son una expectativa también merecen recibir un ambiente apto donde puedan realizar el “proyecto de vida” que tiene toda persona. Es una relación sistémica el derecho a la vida hoy conlleva a la protección ambiental, a fin de evitar la extinción del Hombre.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACNUR

Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul). XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, 27 de julio de 1981. En <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1297.pdf>

ALEXY, Robert

Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. 2001

AMBOS, Kai

Estudios de Derecho Penal Internacional. Caracas, Ucab. 2005

_____ Impunidad y derecho penal. Argentina Ad-Hoc, S.R.L. 1999

ARGIBAY, Andrés

Eclesiología del Vaticano II y la Opción Eclesiológica Latinoamericana en Medellín, Puebla y Santo Domingo. . Caracas .Publicaciones del ITER 2008

ARISTOTELES

La Política. Bogotá. Ediciones Universales

_____ “Ética”, (Obras Selectas), Madri. Edimat Libros, S.A. 2001

AREND, Hannah

Los orígenes del Totalitarismo. México, Taurus, 2006

ARAUJO, Orestes

Las doctrinas internacionalistas de Fray Francisco de Vitoria. Montevideo 1948

ARTEAGA, Alberto y otros

Sentencia 1942 vs. Libertad de expresión. Caracas. Comisión Andina de Juristas. 2003

ASAMBLEA NACIONAL

Textos Constitucionales, 1811-1999. Caracas. Servicio Autónomo de Información Legislativa. 2003

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE GACETA CONSTITUYENTE

Diario de debates. Octubre. Noviembre de 1999. Caracas. Imprenta del Congreso de la República.

AVILA HERNANDEZ, Flor María

La tutela de los intereses colectivos y difusos, en el derecho público a comienzos del siglo XXI. Tomo III. Madrid. Civitas Ediciones.. 2003

AYALA CORAO, Carlos

El estado constitucional y autonomía de los pueblos indígenas. Costa Rica. Estudios Básicos de derechos humanos. N° 2. IIDH. 1995.

BARBE, Esther

Relaciones internacionales. Madrid. Editotial Tecnos. 2005

BAZO CANELON, Abelardo

La tragedia de Vargas, apuntes de testigo. Caracas. Ediciones Centauro. 2002

BELTRÁN DE FELIPE, Miguel y González, Julio

Las Sentencias Básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Madrid. Boletín del Estado. 2006

BENEDICTO XVI

Caritas in veritate. Caracas. Ediciones Paulinas. 2009

BENTHAM, Jeremy

An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London. 1970

BELLO, Andrés

Principios de derecho internacional. Buenos Aires. Editorial Atalaya. 1946

BIBLIA DE JERUSALÉN

Bilbao. Desclée de Brouwer. 1975

BIDART CAMPOS, Germán J.

Teoría general de los derechos humanos. Buenos Aires, Astrea. 1991

_____ El derecho constitucional del siglo XXI: Diagnóstico y perspectivas. Buenos Aires. Sociedad Anónima Editora. 2000

_____ Derechos Humanos. Corte Interamericana. Opiniones Consultivas. Tomos I y II. Mendoza. Ediciones Jurídicas Cuyo.

BLANCO GONZALEZ, Antonio y otros

Filosofía del Derecho. Las concepciones jurídicas a través de la historia. Segunda Edición, Madrid, UNED. 1999

BOBBIO, Norberto

El futuro de la democracia. México. Fondo de Cultura Económica. 2005

_____ La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. México. Fondo de Cultura Económica. 2006

BOFF, Leonardo

Ética y Moral. Santander. Editorial Sal Terrae. 2004

BOLIVAR, Ligia

Derechos económicos, sociales y culturales: Derribar mitos, enfrentar retos, tender puentes. Una visión desde la (In) experiencia de América Latina.. Costa Rica. Estudios Básicos de derechos humanos. N° V IIDH. 1996

BUERGENTHAL, Thomas

Un niño afortunado. Barcelona. Plataforma editorial. 2008

CALDERA, Juan José

60 años de las Declaraciones Internacionales de los Derechos Humanos. Caracas. Universidad Monteavila. 2008

CANCADO TRINDADE, Antonio

Medio Ambiente y desarrollo: formulación e implementación del derecho al desarrollo como un derecho humano. Costa Rica. IIDH. 1993

_____ La protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudios Básicos de derechos humanos. N° I. Costa Rica. IIDH. 1994

CARRILLO, Juan Antonio

Soberanía de los Estados y derechos humanos en derecho internacional contemporáneo. Madrid. Editorial Tecno. 2004

CASAL, Jesús María

Los Derechos Humanos y su Protección. Caracas. UCAB, 2006

CICERON. Trad. Eustoquio Sánchez

El orador. Madrid. Alianza Editorial. 2008

_____ La República y las leyes. Madrid. Ediciones Akal, S.A.1989

CLAVERO, Bartolomé

Los derechos de los pueblos indígenas. Costa Rica. Estudios Básicos de derechos humanos. N° VII. IIDH. 1997

COLMENARES, Ricardo

Los derechos de los pueblos indígenas. Caracas. Editorial Jurídica venezolana.2001

CONCILIO VATICANO II

Constituciones pastorales. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos1966

CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA

Compendio de la doctrina social de la iglesia. Venezuela.2006

CONSTANT, Benjamín

Curso de política constitucional. Granada. Editorial Comares. 2006

CUADRA, Héctor

La proyección internacional de los derechos humanos. México. UNAM. 1970

DE VENANZI, Augusto.

Medio ambiente y sistema –Mundo: La degradación ecológica y el enverdecimiento de los negocios. Caracas, UCV. 2001

DWORKIN, Ronald

El imperio de la justicia. Barcelona. Editorial Gedisa.1992

DULITZKI, Ariel

Los pueblos indígenas: Jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Revista N° (julio-diciembre).Costa Rica. IIDH. 1997

EPICTETO

Enquiridión. Barcelona. Padma. 2007

EMBED IRUJO Antonio y otros

El derecho a un medio ambiente adecuado. Gobierno de Aragón –Instituto Aragonés del Agua. 2008

FAUNDEZ LEDESMA, Héctor

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. (Aspectos Institucionales y Procesales). San José de Costa Rica Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 1999

FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela

Protección constitucional del medio ambiente. Salamanca. 2006

FLANNERY, Tim

La amenaza del cambio climático. Madrid. Editorial Taurus. 2006

GABALDON, Arnoldo

Desarrollo sustentable. La salida de América Latina. Caracas. Editorial Melvin.2006

GACETA OFICIAL N° 662. Extraordinaria.

Constitución de la República de Venezuela. Caracas. 1961

GACETA OFICIAL N° 5.908. Extraordinaria.

Constitución de la República de Venezuela. Caracas. 1999

GACETA OFICIAL N° 5.859. Extraordinaria

Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

GEIGEL, Nelson

Derecho ambiental internacional. Caracas. USB. 1997

GETTEL, Raymond

Historia de las ideas políticas. Barcelona. Editorial Labor, S.A.1937

GIL FORTOUL, José

Historia Constitucional de Venezuela. Tomo Caracas. 1942

GILSON, Etienne

El espíritu de la filosofía medieval. Madrid. Ediciones Rialp. 2009

GOIG MARTINEZ, Juan Manuel y otros

El Sistema constitucional de derechos y libertades según la jurisprudencia del tribunal constitucional. Madrid. Editorial universitas.2006

GORBACHOV, Mijail

Carta a la tierra. Barcelona. Ediciones del Bronce. 2003

GROCIO, Hugo

Del Derecho de la Guerra y de la Paz (versión directa del original latino por Jaime Torrubiano Ripoll. Tomo I. Madrid, Editorial Reus, S.A. 1925

HABERMAS, Jürgen

La inclusión del otro. Barcelona. Editorial Paidós. 1999

HELLER, Hermann

Teoría del Estado. México. Fondo de Cultura Económica. 1981

HERLING, Ludwig

Historia de la iglesia. Barcelona. Editorial Herder.1996

HOBBS, Thomas

Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. México. Fondo de Cultura Económica. 2006

HUNTINGTON, Samuel P.

El Choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Barcelona. Paidos. 2006

HYNDESS, Barry

El poder de Hobbes a Foucault. Madrid. Ediciones Talasa. 1997

INSTITUTO IBEROAMERICANO

Tratado de Versalles de 1919 y sus antecedentes. Madrid. Editorial Reus. 1928

IGLESIAS, Enrique

Derechos humanos y desarrollo económico y social. Costa Rica. Revista N° 40 (Julio-diciembre). IIDH. 2004

ITURRALDE, Diego

Los pueblos indígenas y su derecho. Costa Rica. Revista N° 15 (Enero-junio). IIDH. 1992

JELLINEK, Georg

La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Granada. Editorial Comares. 2009

JIMENEZ DE ARECHAGA Justino

Teoría del gobierno. Tomo I. Uruguay. Fundación de Cultura Universitaria. 1974

JUAN PABLO II

Evangelio de la vida. Caracas. Ediciones Trípode. 1995

JUSTE RUIZ, José

Derecho internacional del medio ambiente. Madrid. Editorial Grillo. 1999

KANT, Enmanuel

Fundamentos de la metafísica de las costumbres, Crítica de la razón práctica, La paz perpetua. México. Editorial Porrúa. 1986

KARL, Marx y ENGELS, Friedrich

Manifiesto comunista. Madrid. Alianza Editorial. 2008

KELSEN, Hans

Teoría comunista del derecho y del Estado. Buenos Aires, Emecé Editores, S.A. 1957

_____ La paz por medio del derecho. Buenos Aires. Editorial Losada. 1946

_____ La idea del derecho natural y otros ensayos. México. Editora Nacional. 1927

KRAMER, Ludwig

Compendio de jurisprudencia de derecho comunitario del medio ambiente. España. Ministerio del Ambiente. 2007

KUNG, Hans

El cristianismo esencia e historia. Madrid. Editorial Trotta. 2006

LACHANCE, Louis

El Derecho y los Derechos del Hombre. Madrid. Ediciones. Rial, S.A. 1979

LAGUNA NAVAS, Rubén

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: su rol como máxima y última interprete de la Constitución. Caracas. UCV. 2005

LAUTERPACHT, H

International law and human rights. London. Steven & Son. 1950

LENIN, V.I

El Estado y la revolución. Madrid. Alianza Editorial. 2006

LINARES, Antonio

Curso de Derecho Internacional Público (Organizaciones Internacionales)
Tomo II. Caracas, UCV. 1972

LOCKE, Jhon

Carta sobre la tolerancia y otros escritos. Barcelona, Ediciones Grijalbo, S.A.
1975

LUCAS VERDU, Pablo

Teoría General de las articulaciones constitucionales. Madrid. Dykinson. 1998

MADISON, James y otros

El federalista. México. Fondo de Cultura económica.

MANIN, Bernard

Los principios del gobierno representativo Madrid. Editorial Alianza. 2006

MARCANO SALAZAR, Luis Manuel

Derecho Internacional Público, fundamentos teóricos y elementos históricos
para su comprensión y estudio. Caracas. Mobilibros. 2008

MARTIN SANTIVÁÑEZ, Rafael Domingo

Hacia un derecho global, reflexiones en torno al derecho y la globalización.
Navarra. Editorial Aranzadi, S.A. 2006

MARTÍNEZ, Joan

El ecologismo de los pobres. Madrid. Editorial Icaria.2005.

MASSINI, Carlos

El Derecho a la vida en la sistemática de los Derechos humanos. En: *Problemas Actuales sobre Derechos humanos. Una Propuesta filosófica*. Coord. Javier Saldaña. México. UNAM

MIAJA DE LA MUELA, Adolfo

Introducción al derecho internacional público. Madrid. Ediciones Atlas. 1960

MESSINEO, S. I

El derecho natural en Suárez. Roma. Revista "Civiltà Cattolica". 1949

MIRKINE-GUETZEVITCH, Boris

Derecho Constitucional Internacional. Madris. Editorial revista de derecho privado.1936

MONTESQUIEU

El espíritu de las leyes Barcelona. Edicomunicación. 2003

MOROS PUENTE, Carlos

La Constitución según la Sala Constitucional. Tomos I y II Caracas. Librería J. Rincón. 2066

NUÑEZ RIVERO, Cayetano

Derecho constitucional comparado y derecho político iberoamericano. Madrid. Editorial universitas. 2002

NIKKEN, Pedro

La protección internacional de los derechos humanos, su desarrollo progresivo. Madrid. Instituto Interamericano de Derechos Humanos- Editorial Civitas, S.A. 1987

_____ El concepto de derechos humanos. Costa Rica .Estudios Básicos, IIDH. 1994

NOGUEIRA ALCALA, Humberto

Justicia y tribunales constitucionales en América del Sur. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana. 2006

OCKHAM, Guillermo. Trad. Pedro Rodríguez

Sobre el gobierno tiránico del papa. Madrid. Editorial Tecnos. 2008

O'DONNEL, Daniel

Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2004

ORGANIZACIÓN DELAS NACIONES UNIDAS

Convención de Viena. Ediciones Liber

ORTIZ ALVAREZ, Luis y LEJARZA, Jacqueline

Constituciones Latinoamericanas. Caracas. Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y sociales. 1997

OLLARVES IRAZABAL, Jesús

Ius cogens en el derecho internacional contemporáneo. Caracas. Instituto de Derecho Público, UCV. 2005

PACHECO, Máximo

Los derechos fundamentales de la persona humana. Costa Rica Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Estudios Básicos de Derechos Humanos N° 02. 1995.

PAINE, Thomas. Trad. Fernando Santos

Derechos del hombre. Madrid. Alianza Editorial. 2008

PALOMARES LERMA, Gustavo.

Relaciones Internacionales en el siglo XXI, Madrid. Editorial Tecnos. 2004

PECES-BARBA, Gregorio

Curso de derechos fundamentales. Teoría General. Madrid. Universidad Carlos III. 1999

PLATON

Diálogos. Madrid. Editorial Libsa. 2001

_____ La República. Madrid. Instituto de Estudios Políticos. 1949

PEÑA CHACON, Mario

Daño ambiental y prescripción: Consultado en <http://www.ceda.org.ec/>

descargas/biblioteca/Derechos Humanos y Medio Ambiente Julio del 2010

PONTANA, Giuliano

Ética y generaciones futuras. Barcelona, editorial Ariel, S.A. 1996

PROVEA

Derecho a la vida. Serie aportes 11. Caracas

_____ El derecho a la salud una visión integral. Caracas.Unión Europea-embajada de Noruega. 2006

RAMIREZ, Alirio

Clase magistral dictada en la UCSAR. Noviembre 2010

RAMIREZ, Yesid

El derecho ambiental. Colombia. Ediciones jurídicas Gustavo Ibañez.1998

RAWLS, John

Teoría de la justicia. México. Fondo de Cultura Económica. 2000

REMIRO BROTONS, Antonio y otros

Derecho internacional. Madrid. McGraw Hill. 1997

ROSS, Alf

Sobre el derecho y la justicia. Buenos Aires. Editorial Eudeba. 1997

RODRIGUEZ BELTRAN, Juan José

Los derechos humanos y el medio ambiente. Colombia. Universidad de la sabana.2006

RODRÍGUEZ CEDEÑO, Víctor

Clase Magistral. Instituto Superior de Estudios Internacionales y Diplomáticos. 11 de febrero del 2005.

REVISTA DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Nº 1 septiembre-diciembre. Caracas. Editorial Sherwood. 1999

REY CANTOR, Ernesto

Celebración y jerarquía de los tratados de derechos humanos. Caracas. UCAB.2007

ROUSSEAU, JEAN JACQUES

Discurso sobre las ciencias y las artes, discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, el contrato social. Madrid. Editorial Libsa. 2002

SABINE, George

Historia de la Teoría Política. México. Fondo de Cultura Económica.2006

Sainz Borgo, Juan Carlos

Revista Politeia. V.30 N° 38. Caracas. UCV

SAMANIEGO, Luis

Estudio dogmático del derecho humano a disfrutar de un ambiente adecuado. Madrid. Plaza Valdés Editores.2006

SANCHEZ AGESTA, Luis

Lecciones de Derecho Político. Granada, Editorial y Librería Prieto. 1954

SALAZAR UGARTE, Pedro

La democracia constitucional, un radiografía teórica. México. Fondo de Cultura Económica.2008

SARTORI, Giovanni

¿Qué es la democracia?. Madrid. Taurus. 2007

SIEYES, Enmanuel Joseph

¿Qué es el Estado Llano?. Madrid. Instituto de Estudios Políticos.1950

SILVA GARCIA, Fernando

Derechos Humanos efectos de las sentencias internacionales. México. Editorial Porrúa.2007

SOFOCLES

Las Siete tragedias. México. Editorial Porrúa. 2007

STAVENHAGEN, Rodolfo

Los derechos indígenas algunos problemas conceptuales. Costa Rica. Revista N° 15 (Enero-junio). IIDH.1992

_____ Los derechos indígenas en e sistema internacional: Un sujeto en construcción. Costa Rica. Revista N° 26 (Julio-diciembre). IIDH.1997

STRAUSS, Leo y CROPSEY, Joseph (Compiladores)

Historia de la Filosofía Política. México, Fondo de Cultura Económica. 2006

TOCQUEVILLE, Alexis

La democracia en América. México. Fondo de Cultura Económica. 2002

TOYNBEE, Arnold

La Europa de Hitler. Madrid. Edición Sarpe. 1985

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Antejuicio de Mérito Mayo- Septiembre. Venezuela, 2004

_____ Ensayos de Derecho Constitucional Colección de Estudios Jurídicos N° 6. Caracas. 2002

_____ Proyecto de capacitación de jueces en derechos humanos. Caracas. 2004

TROCONIS PARILLI, Nelson

La paz, desarrollo y ambiente como derechos humanos. Triangulación y visión sistémica. Mérida. Ediciones Paredes 2. 2007

TRUYOL y SERRA, Antonio

Los derechos humanos. Madrid. Editorial Tecnos. 2000

URIOSTE, Fernando

La protección de los intereses colectivos; en acceso a la justicia. Caracas. IIDH-UCAB. 2006

VILLEGAS, Jose

La protección jurisdiccional de los intereses difusos y colectivos. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana – Universidad Católica del Táchira. 1999

WEBER, Max

El político y el científico. Madrid. Alianza Editorial. 2007

_____ Economía y sociedad. Bogotá. Fondo de Cultura Económica. 1944

XIFRA HERAS, Jorge

Curso de Derecho Constitucional. El Estado Moderno. Tomo II. Barcelona, Bosch, Casa Editorial.1962

ZAGREBELSKY, Gustavo

El derecho dúctil. Madrid. Editorial Trotta. 2007

MEDIOS ELECTRONICOS CONSULTADOS

<http://www.canalsocial.net/GER>

<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf>

<http://www2.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-hist-Virginia.html>

<http://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html>

<http://www.iepala.es/ddhh>

<http://biblioteca.universia.net/irARecurso.do?page=http%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F2027%2Fuc1.b4184989&id=49696021>

http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais

<http://www.cinu.org.mx/temas/dh/decvienapaccion.pdf5>

http://www.eluniversal.com/2010/02/11/int_ava_fenomeno-el-nino-afe_11A3419097.shtml

<http://www.globovision.com>

<http://www.lexjuris.com/lexuscon.htm>

http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ue/Trat_lisboa.pdf

http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/12/091201_tratado_lisboa_rg.shtml

<http://www.elpais.com>

http://europa.eu/institutions/index_es.htm

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

<http://www.der.uva.es/constitucional/>.

<http://constitucion.rediris.es/legis/legextr/ConstitucionAlemana.html#a25>.

<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/7/dtr/dtr2.pdf>

Derechos humanos. Teorías y doctrinas de Luis Manuel Marcano Salazar
se imprimió en la República Argentina en septiembre de 2018